

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 개별법 기본강의 1회

01. 공용수용의 요건에 대해 설명하고, 공공수용과 공공필요의 관계에 대해 설명하시오. (15점)

목차
I. 공용수용의 의의·취지 및 근거 II. 공용수용의 요건(헌법23조3항) 1. 공용수용의 당사자 2. 공용수용의 내용상 요건 3. 공용수용의 절차상 요건 III. 공용수용과 공공필요 1. 헌법23조 3항의 공공필요 2. 토지보상법 제4조 및 별표, 제4조의2 수용적격사업 3. 공공필요의 판단기준 4. 수용에 있어 공공필요의 확대 경향 IV. 최근 공용수용제도의 동향

I. 공용수용의 의의·취지 및 근거

①공용수용(公用收用)이란 특정한 공익사업을 위해 사업주체가 국가권력으로 타인의 재산권을 강제적으로 취득하는 것을 말한다. ②공용수용제도는 공익사업을 위해 관리자의 의사에 관계없이 토지소유권 등을 강제적으로 취득하는 길을 열어주기 위해 마련된 제도이다. ③현대북리국가의 공공복리 증진 등 이론적 근거로 헌법23조3항과 토지보상법 등 개별법에 근거를 둔다.

II. 공용수용의 요건(헌법23조3항)

1. 공용수용의 당사자
공용수용의 당사자는 공용수용 법률관계의 당사자로서, 수용권 주체인 수용권자와 수용 목적물에 대한 권리를 가진 피수용자이다.

2. 공용수용의 내용상 요건

헌법 제23조 제3항에 따라 공공필요가 있을 것, 재산권에 대한 공권적 침해일 것, 재산권 침해의 법적 근거가 있을 것, 특별한 희생이 발생할 것, 보상규정이 존재할 것이 그 요건이 된다.

3. 공용수용의 절차상 요건

공용수용에 따른 토지의 취득 및 보상에 관한 일반법적 지위에 있는 토지보상법은 사업인정 전 협의(제16조), 사업인정(제20조), 토지조서 및 물건조서의 작성(제26조), 협의(제26조), 수용재결(제34조)로 이어지는 일련의 공용수용의 절차를 규정하고 있다.

III. 공용수용과 공공필요

1. 헌법23조 3항의 공공필요

①공공필요는 대표적 불확정 개념으로 현대북리국가이념에 따라 확대화 경향이 있다. ②헌법 제23조 제3항에 따라 재산권에 대한 공권적 침해는 공공필요가 있을 때만 행해질 수 있으므로, 공공필요는 공용침해의 실질적 허용요건이자 본질적 제약요소이다.

2. 토지보상법 제4조 및 별표, 제4조의2 수용적격사업

토지보상법은 공공필요가 있는 사업을 수용적격사업으로 규정하고 있다(제4조 및 별표, 제4조의2). 사업의 공공성을 확보하기 위해 사업인정 발령 시 실질적 공공필요가 있는지 판단한다.

3. 공공필요의 판단기준

공공필요는 공용침해를 통하여 얻어지는 공익과 재산권자의 재산권 보유이익 간에 이익형량을 통해서 그 여부가 결정되고, 그 입증책임은 사업시행자에게 있다.

4. 수용에 있어 공공필요의 확대 경향

최근 민간의 이윤, 동기까지 포함하는 시설의 설치 등을 목적으로 하는 사업에 대하여

도 점차 공공필요를 인정하기에 이르고 있어 '공공의 이익'이란 관념은 확대현상을 보이고 있다.

IV. 최근 공용수용제도의 동향

①토지보상법 4조 및 동조 8조 규정으로 공익사업의 확대 현상을 반영하고, 동법 4조의3과 21조 등으로 보건데, 공익성 검증을 강화하였다. ②민자유치사업 확대 현상, 토지보상법상 사업주체 구분 없이 공익사업시행자에게 수용권을 부여하는 등 공공적 사용수용의 확대화 경향을 보인다. ③보상금에서 개발이익을 배제하는 제도적 장치가 일반화되고 있고, ④정당보상과 생활보상의 확대 경향을 보인다.

02. 사적(私的) 공용수용의 의의 및 요건에 대하여 설명하시오. (10점)

[기출 19회 3]

목차
I. 사적 공용수용의 의의·취지
II. 사적 공용수용의 요건(헌법23조3항)
III. 사적 공용수용 인정여부
1. 독일의 논의
2. 판례 및 검토
IV. 계속적 공익실현의 보장책

I. 사적 공용수용의 의의·취지

공공적 사용수용(사적 공용수용, 사용수용)이란 특정한 공익사업을 위하여 사적 주체가 타인의 특정 재산권을 법률의 힘에 의해 보상을 조건으로 강제적으로 취득하는 것이다. 민간활력의 도입, 사업의 확대 등에 취지가 있다.

II. 사적 공용수용의 요건(헌법23조3항)

① 공공적 사용수용은 공익사업의 목적에만 인정된다. ② 사적 주체로서 국가권력에 의해 수용권을 부여받는다. ③ 대상은 특정한 재산권이다. ④ 법률에 근거하여 타인의 재산권을 강제적으로 취득한다. 강제적 취득이란 권리자의 의사에 상관없이 일방적으로 재산권을 취득하는 것을 말한다. ⑤ 공공적 사용수용은 공용수용과 마찬가지로 재산권자에게 특별한 희생을 발생시키므로, 정당한 보상을 지급하여야 한다.

III. 사적 공용수용 인정여부

1. 독일의 논의

독일에서는 일반 사기업도 공익을 위해 수용이 허용된다고 보는 것이 일반적이다. 독일 법상의 사기업의 유형으로는 생존배려형 사기업과 경제적 사기업이 있다. 생존배려형 사기업은 공공재화 등의 공익사업을 수행하는 경우의 국민의 생존을 배려하는 급부행정 작용을 수행하는 사기업이고, 경제적 사기업은 공공성보다는 이윤추구를 우선적 목적으로 하는 사기업이다. 생존배려형 사기업의 공익사업은 국가적 과제이므로 사기업에게 수용권한을 부여하는 것은 당연하다. 그러나 경제적 사기업에 대해서는 엄격한 요건 아래에서 허용해야 한다는 주장이 있으나, 오늘날 경제적 사기업은 경제구조 개선·고용 증진·지역 발전 등이라는 공익이 합리적으로 요구될 때 공익사업을 수행하므로, 경제적 사기업의 재산권 침해는 공익적 요청에 의한 것이라면 정당화될 수 있다고 봄이 일반적 입장이다.

2. 판례 및 검토

<대법원>은 어떤 사업이 공익사업인가의 여부는 그 사업자체의 성질에 의하여 정할 것이고, 사업주체의 여하에 의하여 정할 것이 아니라고 판시한 바 있다. <헌법재판소>도 관광진흥법 위헌소원사건에서 재산권의 수용의 주체를 한정하지 않고 있는바 합헌 판결을 하였다. <검토>생각건대, 오늘날 현대복지국가의 실현을 위하여 공익사업이 증가함에 따라 사적주체에게 수용권을 부여할 필요성이 커지는바, 엄격한 요건 하에 사용·수용을 인정할 필요가 있다.

IV. 계속적 공익실현의 보장책

① 공공적 사용수용의 사적 주체는 이윤추구의 목적도 함께 가지고 있으므로 언제든지 사업을 중도에 포기할 가능성이 있어 보장책이 필요하다. ② 토지보상법상 환매권 및 사업인정의 실효제도나 ③ 개별법상 사업시행자에 대한 감독명령과 처분이나 행정쟁송, 위헌법률심판 등 입법·사법적 통제 등 여러 보장수단이 규정되어 있으나 추상적이고 제한적이어서 실효성 있는 수단으로 개괄적 규정이 마련되어야 할 것이다.

03. 사업시행자에 대해 설명하고, 국가 이외의 자가 수용권자인 경우 수용권의 주체를 논하시오. (10점)

목차
I. 사업시행자의 의의 II. 사업시행자의 법적 지위 1. 권리 2. 의무 III. 국가 이외의 자가 수용권자인 경우 수용권의 주체 논의 1. 문제점 2. 학설 3. 판례 4. 검토

I. 사업시행자의 의의(토지보상법 2조3호)

사업시행자란 공익사업을 수행하는 자를 말한다(제2조 제3호). 사업시행자는 국가·지방자치단체·법인 또는 사인에 관계없이 특정한 공익사업의 시행자를 말한다. 여기에서 공익사업이란 토지보상법 제4조 각 호 규정에 따른 사업을 말한다. 따라서 사업시행자는 수용적격사업에 관한 법률상 권한을 갖는 자이다.

II. 사업시행자의 법적 지위

1. 권리

사업시행자의 권리에는 ① 사업준비를 위한 타인 토지에의 출입권(제9조), ② 장애물 제거권(제12조), ③ 사업인정 신청권(제20조), ④ 토지 및 물건에 관한 조사권(제27조), ⑤ 재결신청권(제28조), ⑥ 협의성립확인 신청권(제29조), ⑦ 토지나 물건을 원시취득할 권리(제45조), ⑧ 토지나 물건의 인도 또는 이전이 없는 경우 대행신청권(제44조), ⑨ 재결에 불복하는 경우 행정쟁송권(제83조 및 제85조), ⑩ 의무 불이행 등에 대한 대집행신청권(제89조) 등이 있다.

2. 의무

사업시행자의 의무에는 ① 타인 토지에의 출입 등에 의한 측량·조사, 장애물 제거 등으로 인한 손실보상의무(제9조 제4항, 제12조 제4항), ② 협의의 불성립시 피수용자의 재결신청청구에 응할 의무(제30조 제2항), ③ 피수용자의 고의·과실 없이 수용목적물의 멸실·훼손으로 인한 손실부담의 이전(제46조), ④ 재결로 인한 토지 등 취득시 손실보상의무(제61조) 등이 있다.

III. 국가 이외의 자가 수용권자인 경우 수용권의 주체 논의

1. 문제점

국가가 사업시행자인 경우는 논란이 없으나, 국가 이외의 공공단체나 사인(공무수탁사인)이 사업시행자인 경우 수용권의 주체가 누구인지 견해가 대립한다.

2. 학설

① <국가수용권설> 수용권이란 수용의 효과를 야기할 수 있는 능력이므로 수용권자는 국가라고 한다. 사업시행자는 수용권의 발동을 국가에게 청구하는 권리를 갖는데 지나지 않는다고 한다. ②<사업시행자수용권설> 수용의 본질이 특정한 재산권을 취득하는데 있으므로, 수용권이란 수용의 효과를 누리는 능력이라고 한다. 따라서 수용권자는 사업시행자라고 한다. 이 설이 우리나라 다수설로 되어 있다. ③<국가위탁권설> 수용권은 국가에 귀속되는 국가적 공권이고, 국가는 사업인정(수용권 설정)을 통하여 이를 사업시행자에게 위탁한다고 한다.

3. 판례

대법원은 사업인정을 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정해 주는 설권적 형성처분이라 판시하여 사업시행자수용권설의 입장이다.

4. 검토

국가공권력의 개입이 수용의 효과를 야기한다 하더라도, 현행 공용수용제도는 공공단체는 물론 기업이나 사인에게도 수용권을 부여하고 있을 뿐 아니라, 수용에 관한 소송도 사업시행자를 당사자로 할 수 있기 때문에 타당한 논거가 되지 못한다. 비록 국가가 수용의 효과를 야기한다 하더라도 수용권은 수용의 효과를 누릴 수 있는 능력이라 볼 수 있으므로, 사업시행자수용권설을 취하는 것이 타당하다.

04. 丙이 소유하고 있는 토지(이하 '이 사건 C토지'라 한다)는 문화재보호법 상 보호구역으로 지정된 토지로서 이 사건 'X시립공원 공원사업(사업 인정 후 협의 불성립으로 수용재결 단계에 있다)'의 시행을 위한 사업구역 내에 위치하고 있다. 甲은 공물인 이 사건 C토지를 'X시립공원 공원사업'의 시행을 위하여 수용할 수 있는가? (15점)

[기출31회 1-3]

목차
I. 논점의 정리
II. 공물의 의의 및 취지
III. 토지보상법 19조2항
IV. 공물의 수용가능성
1. 학설
2. 판례
3. 검토
V. 특별한 필요의 판단
VI. 사안의 해결

I. 논점의 정리

토지보상법 19조 2항의 해석 및 공물의 수용가능성에 대한 학설, 판례를 검토한다.

II. 공물의 의의 및 취지

공물은 행정주체(국가·지자체)에 의하여 직접 행정목적에 공용된 개개 유체물로, 공익성 확보 취지가 있다.

III. 토지보상법 19조2항

토지보상법 19조2항은 “공익사업에 수용되거나 사용되고 있는 토지등은 특별히 필요한 경우가 아니면 다른 공익사업을 위하여 수용하거나 사용할 수 없다”고 규정하고 있어 용도폐지 없이 공물의 수용이 가능한지와 특별한 필요의 해석이 문제된다.

IV. 공물의 수용가능성

1. 학설

①<긍정설> 법19조2항에 따라 공익 상호간 비교형량을 통해 수용이 가능하다고 본다.
②<부정설> 법19조2항의 특별한 필요는 명문규정 있는 경우만 해당하며 이미 공적 목적에 제공되고 있어 별도로 용도폐지가 필요하다고 본다.

2. 판례

①토지보상법 19조 규정에 의한 제한 이외에 수용의 대상이 되는 토지에 관하여 아무런 제한을 하지 아니하고 있으므로 지방문화재로 지정된 토지등도 수용대상이 될 수 있다. ②국유림법에서 정하는 절차와 방법에 따르지 아니한 채, 토지보상법에 따른 재결을 통해 요존국유림의 소유권이나 사용권을 취득할 수 없다. ③헌법재판소는 공익 또는 수용권의 충돌문제를 해결하기 위한 규정으로 보다 더 중요한 공익사업을 위하여 특별한 필요가 있는 경우에 한하여 예외적으로 수용의 목적물이 될 수 있다고 판시하였다.

3. 검토

공물은 현재 공익 목적에 제공되고 있지만 보다 큰 공익 목적을 위해 다른 용도로 전환될 수 있어야 한다고 본다. 긍정설이 타당하다.

V. 특별한 필요의 판단

특별한 필요는 행정목적과 행정수단 사이 비례성이 인정되어야 한다는 비례의 원칙에 따라 판단한다. C토지는 문화재보호법상 보호구역으로 지정된 공물이지만, 이 사건 공원 사업의 공익성이 요구되는 점, 수용을 통하여 공원 사업을 진행할 수 있는 점, 공원 사업의 공익이 더 큰 점 등을 보았을 때, 이 사건 공원 조성사업 시행을 위한 적합성, 필요성, 상당성 원칙이 인정되는바, 특별한 필요가 있다.

VI. 사안의 해결

05. 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상의 확대보상을 설명하고, 확장수용청구가 거부된 경우 그 불복방법을 논급하시오. (20점) [기출10회 3]

목차
I. 확장수용의 의의·취지 II. 유형 1. 완전수용(토지보상법72조) 2. 잔여지 수용(동법74조) 3. 이전수용(동법75조) 4. 잔여건축물 수용(동법75조의2) III. 확장수용의 성질 1. 학설 2. 판례 3. 검토 IV. 확장수용재결의 불복 1. 문제점 2. 이의신청(동법83조) 3. 행정소송 형태(동법 85조2항 보상금증감청구소송)

I. 확장수용의 의의·취지

특정 공익사업을 위한 필요 범위를 넘어서는 재산권 수용으로 최소침해 원칙의 예외이나 피수용자 권리보호 및 사업의 원활한 시행을 위해 인정된다.

II. 유형

1. 완전수용(토지보상법72조)

완전수용이란 토지사용으로 인해 토지소유자가 받게 되는 현저한 장해에 갈음하여 수용보상을 가능하게 해 주는 제도이다. 완전수용은 '사용에 갈음하는 수용'이라고도 한다. 사업인정고시 후 ① 토지사용기간이 3년 이상인 경우, ② 토지사용으로 인하여 토지형질이 변경되는 경우, ③ 사용하려는 토지에 그 토지소유자의 건축물이 있는 경우 해당 토지소유자는 사업시행자에게 토지매수를 청구하거나 관할 토지수용위원회에 토지수용을 청구할 수 있다.

2. 잔여지 수용(동법74조)

①잔여지수용이란 동일한 토지소유자에게 속하는 수용 목적물인 일단의 토지 일부가 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란한 때 토지소유자의 청구에 의해 사업시행자가 해당 토지의 전부를 매수하거나 관할 토지수용위원회가 수용하는 것을 말한다. ②'사용하는 것이 현저히 곤란한 때'라 함은 사회적·경제적으로 사용하는 것이 곤란하게 된 경우도 포함하며 ③시행령 39조1항에 의하면 잔여지가 대지로서 면적이 너무 작거나 부정형(不定形) 등의 사유로 건축물을 건축할 수 없거나 건축물의 건축이 현저히 곤란한 경우, 농지로서 농기계 등의 진입과 회전이 곤란할 정도로 폭이 좁고 길게 남거나 부정형 등의 사유로 영농이 현저히 곤란한 경우, 공익사업의 시행으로 교통이 두절되어 사용이나 경작이 불가능하게 된 경우, 위 규정과 유사한 정도로 잔여지를 종래의 목적대로 사용하는 것이 현저히 곤란하다고 인정되는 경우로 규정한다.

3. 이전수용(동법75조)

이전비 보상이 원칙이나 ① 건축물 등을 이전하기 어렵거나, 그 이전으로 인하여 건축물 등을 종래의 목적으로 사용할 수 없게 된 경우, ② 건축물 등의 이전비가 그 물건의 가격을 넘는 경우, ③ 사업시행자가 공익사업에 직접 사용할 목적으로 취득하는 경우의 어느 하나에 해당하는 경우는 이전에 갈음하는 수용이 가능하다.

4. 잔여건축물 수용(동법75조의2)

동일한 소유자에 속하는 일단의 건축물의 일부가 편입됨으로 인해 잔여건축물을 종래의 목적대로 사용하는 것이 현저히 곤란할 때 건축물 소유자의 청구에 의해 사업시행자가 해당 건축물의 전부를 매수하거나 관할 토지수용위원회가 수용하는 것이다. 사업완료일까지 청구해야 한다.

Ⅲ. 확장수용의 성질

1. 학설

사업시행자와 피수용자의 임의적 합의라는 <사법상 매매설>, 필요 최소한도를 넘어서고 피수용자의 청구에 의해 이루어지는 <공법상특별행위설>, 본질이 일반 공용수용과 같다는 <공용수용설>이 대립한다.

2. 판례

대법원은 잔여지수용청구권은 요건 구비 시 피수용자 청구에 의해 수용의 효과 발생하는 형성권성질 갖는다 판시하여 <공용수용설> 입장이다.

3. 검토

권리발생 원인이 공익사업 수행이라는 공권적 침해에 기인하므로 <공용수용설>이 타당하다.

Ⅳ. 확장수용재결의 불복

1. 문제점

확장수용은 공용수용의 성질을 갖고, 확장수용청구권의 법적 성질은 공권으로서, 토지수용법 체계상 확장수용은 토지수용위원회의 재결에 의해 이루어진다. 따라서 확장수용 거부 시 이에 대한 불복은 토지보상법 83조 이의신청 및 85조 규정에 따르면 된다. 이때 항고소송을 제기하지 않고 보상금증감청구소송을 제기할 수 있는지 또 민사소송의 제기는 가능한지 문제된다.

2. 이의신청(동법83조)

법34조 재결에 이의 있는 자 재결서 정본 송달일로 30일내 청구가능하다.

3. 행정소송 형태(동법 85조2항 보상금증감청구소송)

①<학설> 보상금증감청구소송 심리범위는 보상금액에만 한정된다는 <항고소송설>, 잔여지수용도 궁극적으로는 보상액의 증감에 관한 것이라는 <보상금증감청구소송설>이 대립한다. ②<판례> 잔여지수용청구권은 <손실보상의 일환으로 형성권적 성질>을 가지므로, 잔여지수용청구를 받아들이지 아니한 토지수용위원회의 재결에 대하여 토지소유자가 불복하여 제기하는 소송은 토지보상법 85조 2항에 규정되어 있는 <보상금증감에 관한 소송>에 해당하여 <사업시행자를 피고>로 하여야 한다고 판시하였다. ③<검토>

잔여지수용청구권이 형성권인 점, 분쟁의 일회적 해결이라는 보상금증감청구소송 취지, 판례의 입장 종합 고려할 때 <보상금증감청구소송>로 다루는 것이 타당하다.

06. 토지보상법상 공익사업의 준비를 설명하고, 이로 인한 사업시행자와 토지소유자의 권리구제 방안을 설명하시오. (20점)

목차
I. 공익사업 준비의 의의·취지 및 근거 II. 타인토지 출입(토지보상법9조) 1. 의의 2. 법적성질 3. 요건 및 절차 4. 효과 III. 장애물의 제거 등(토지보상법12조) 1. 의의 2. 법적성질 3. 요건 및 절차 4. 효과 IV. 권리구제 1. 사업시행자 2. 토지소유자 1) 사전적 권리구제 2) 사후적 권리구제

I. 공익사업 준비의 의의·취지 및 근거

공익사업 준비란 공익사업을 위해 조사·측량 및 장애물의 제거 등을 하는 일련의 준비 행위로서 타인토지에 출입하여 조사·측량 및 장애물의 제거 등에 관한 일련의 행위를 말한다. 원활한 공익사업 준비에 취지가 있다. 공익사업의 준비는 헌법 23조3항, 37조2항과 토지보상법 9조 내지 13조에서 법적 근거를 구할 수 있다.

II. 타인토지 출입(토지보상법9조)

1. 의의

사업시행자는 공익사업을 준비하기 위하여 타인이 점유하는 토지에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다(제9조 제1항). 타인토지에 출입하여 측량·조사하는 행위는 그 지역이 해당 공익사업에 적합한 지역인지 판단하는 행정조사행위이다.

2. 법적성질

①출입의 허가는 공용사용권의 설정으로서 성질을 갖는 행정처분이다. 출입허가를 강학상 허가, 강학상 특허 또는 예외적 승인이라고 보는 견해가 대립하나, 타인의 토지에 출입할 수 있는 권리를 부여한다는 점에서 강학상 특허, 재량행위로 보아야 할 것이다. ②출입 측량·조사 행위 자체는 비권력적 사실행위이나, 토지보상법상 토지점유자의 인용의무(제11조)가 부과되므로, 사실행위와 수인하명이 결합된 합성행위로서 권력적 사실행위에 해당하고, 처분성이 인정된다.

3. 요건 및 절차

사업시행자는 타인토지에 출입, 측량·조사하려면 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받거나 통지하여야 한다(제9조 제2항). 특별자치도지사 등은 위 허가 또는 통지를 받은 때 해당 내용을 공고하고 이를 토지점유자에게 통지하여야 한다(제9조 제3항). 사업시행자는 출입하려는 날의 5일 전까지 그 일시 및 장소를 특별자치도지사 등에게 통지하여야 하고, 특별자치도지사 등은 그 토지점유자에게 통지하여야 한다. 일출 전 일몰 후에는 토지점유자 승낙 없이 토지에 출입할 수 없고, 출입 시 증표와 허가증을 지녀야 한다.

4. 효과

①사업시행자는 타인토지출입권, 손실보상 의무, 반환 및 원상회복의무(48)가 발생한다. ②피수용자는 손실보상청구권(안 날로부터 1년/발생한 날로부터 3년), 인용의무(11), 인용의무 위반 시 200만원 이하의 벌금(97)의 효과가 발생한다.

III. 장애물의 제거 등(토지보상법12조)

1. 의의

장애물 제거란 측량·조사 시 부득이하게 장애물을 제거하고 토지의 시굴·시추를 해야 하는 경우를 말한다(제12조 제1항).

2. 법적성질

①장해물 제거 등을 위한 허가는 공용사용권의 설정으로서 성질을 갖는 행정처분이다. 허가에 대하여 강학상 허가, 강학상 특허, 예외적 승인 등의 견해가 대립하나, 장해물 등을 제거할 수 있는 권리를 부여하는 강학상 특허, 재량행위로 봄이 타당하다. ②장해물 제거행위는 측량·조사의 원활함을 위한 것이므로, 정당하게 허가받고 제거하는 행위에 대하여는 명문 규정이 없다 하더라도, 타인토지 출입 시 인용의무를 준용함이 타당하다. 따라서 사실행위와 수인하명이 결합된 합성행위로서, 권력적 사실행위에 해당하고, 이는 처분성이 인정된다.

3. 요건 및 절차

사업시행자는 소유자 및 점유자의 동의를 얻어야 하고, 동의를 받지 못할 경우에는 사업시행자는 허가를 받아 장해물 제거 등을 할 수 있다(제12조 제1항). 특별자치도지사 등이 허가를 하거나 장해물 제거 등을 하려면 미리 그 소유자 및 점유자의 의견을 들어야 한다(제12조 제2항). 장해물 제거 등을 하려는 자는 장해물 제거 등을 하려는 날의 3일 전까지 그 소유자 및 점유자에게 통지하여야 한다(제12조 제3항). 장해물 제거 등을 하려는 자는 그 신분을 표시하는 증표와 허가증을 지녀야 하고(제13조 제1항), 이를 장해물의 소유자 및 점유자, 그 밖의 이해관계인에게 보여주어야 한다(제13조 제3항).

4. 효과

①사업시행자는 장해물제거권, 손실보상 의무, 반환·원상회복 의무(48)가 발생한다. ②피수용자는 손실보상청구권(안 날로부터 1년/발생한 날로부터 3년), 인용의무가 발생한다.

IV. 권리구제

1. 사업시행자

①허가신청 거부: 허가는 처분으로 공권력 행사이고, 공익사업 진행 관련 권리행사에 중대한 지장을 미치며, 토지보상법 9조 및 12조에 의해 신청권이 있는 것으로 해석되는바, 허가신청 거부는 처분으로서 대상적격이 있다. 기타 소송요건 충족 시 항고소송, 항고 심판 등 가능하다. ②허가신청 부작위: 사업시행자에게 토지보상법 제9조 및 제12조에 의해 신청권이 있는 것으로 해석되고, 특별자치도지사 등에게 일정한 처분을 할 법률상 의무가 있는바, 의무이행심판과 부작위위법확인소송을 제기할 수 있다.

2. 토지소유자

1) 사전적 권리구제

출입 측량·조사 시 통지, 장해물 제거 시 통지, 장해물 제거 허가 시 소유자 및 점유자의 의견청취 등이 토지보상법에 규정되어 있다. 측량·조사와 장해물 제거 행위는 권력적 사실행위로서, 처분성이 인정되고, 토지소유자 및 점유자에게는 침익적 행위인 바, 예방적 금지소송과 가처분이 권리구제방법으로 논의될 수 있으나, 현행법상 인정되지 않고 있다.

2) 사후적 권리구제

①손실보상(9조4항~7항): 사업시행자는 타인토지출입하여 측량·조사함으로써 발생한 손실을 보상하여야 한다. 손실이 있는 것을 안 날부터 1년 손실이 발생한 날부터 3년 이내 청구해야 한다. ②행정쟁송: 타인토지출입 측량·조사행위, 장해물 제거행위는 권력적 사실행위로 처분성 있어 행정소송 대상적격 인정되나 협의소익 없을 가능성 높다. 재결 전치 관련 견해대립이 있으나 판례는 재결절차를 거치지 않고 곧바로 사업시행자에게 손실보상을 청구할 수 없다고 하였다. 손실보상 재결에 대한 불복은 처분성 부정 시 공법상 당사자소송에 의할 것이나 처분성을 인정한다면 항고소송을 통한 구제가 가능하다. 토지보상법은 재결에 대한 불복규정을 두고 있는바 이의신청(83)과 행정소송(85)이 가능하다. ③위법한 조사와 사업인정: 위법한 행정조사에 기한 후속조치로 처분이 행해진 경우 적법절차 관점에서 행정조사의 위법을 이유로 후행처분의 취소를 구할 수 있다. ④손해배상 및 결과제거 청구권: 위법한 행정조사는 국가배상법에 의해 손해배상청구가 가능하며 위법한 행정조사 결과로 위법한 상태가 계속되는 경우 결과제거청구권 행사가 가능하다.

07. 공익사업의 준비과정에서 토지소유자가 토지출입을 거부하는 경우 담당 공무원이 실력으로 토지에 들어가 필요한 조사를 할 수 있는지를 논하고, 위법한 측량조사에 따른 사업인정의 효력에 대해 논하시오. (10점)

목차
I. 논점의 정리 II. 실력행사의 가부 1. 학설 2. 검토 III. 위법한 측량조사에 따른 사업인정의 효력 1. 학설 2. 판례 3. 검토

I. 논점의 정리

①타인토지출입 측량조사와 같은 권력적 행정조사 중, 상대방이 조사를 거부하는 경우 벌칙규정은 존재하지만, 실력행사에 관한 명문 규정이 없는 경우 직접 실력행사를 통해 필요한 출입 측량·조사를 할 수 있는지 문제된다. ②측량·조사가 절차를 위반한 경우 그 측량·조사에 의해 수립된 정보에 기초하여 내려진 사업인정이 위법한 것으로 되는지 문제된다.

II. 실력행사의 가부

1. 학설

① <긍정설> 제재규정을 둔 것은 피조사자의 수인의무 위반을 위법으로 보아 비례의 원칙 안에서 실력을 가할 수 있는 규정으로 볼 수 있다고 한다. ② <부정설> 토지보상

법상 벌칙 규정만을 둔 취지는 조사의 실효성을 간접적으로 확보하려는 것으로서 실력행사는 허용되지 않는다고 한다.

2. 검토

국민의 신체나 재산에 대한 실력행사는 명문의 근거가 있어야 하므로 부정설이 타당하다.

III. 위법한 측량조사에 따른 사업인정의 효력

1. 학설

① <적극설> 절차의 적법성 보장 원칙에 비추어 행정조사가 위법한 경우 당해 조사를 기초로 한 행정행위는 위법하다. ② <소극설> 행정조사는 법령에서 특히 행정행위의 전제조건으로 규정되어 있는 경우를 제외하고는 일응 별개의 제도로 볼 수 있어 조사의 위법이 바로 행정행위를 위법하게 하지는 않는다. ③ <절충설> 행정조사와 행정처분은 하나의 과정을 구성하므로 적정절차 관점에서 행정조사에 중대한 위법사유가 있으면 그에 기초한 행정행위도 위법한 것으로 볼 수 있다.

2. 판례

판례는 위법한 세무조사에 기초한 부가가치세 부과처분은 위법하다고 하여 적극설을 취하고 있다. 다만, 행정조사 절차하자가 경미한 경우에는 위법사유가 되지 않는 것으로 본다.

3. 검토

사업인정에 필요한 정보를 수집하기 위해 행해진 측량·조사가 위법한 경우 당해 행정행위의 절차하자가 있는 것으로 볼 수 있다. 따라서 이 경우 사업인정의 효력은 절차하자의 문제가 될 것이다.

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 개별법 기본강의 2회

01. 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)상 천재지변 시의 토지의 사용(법 38조)과 시급한 토지 사용에 대한 허가(법 39조)를 비교하시오. (10점)

목차
I. 개설 II. 공통점 1. 규정 취지 2. 요건 3. 사용기간 및 효과 4. 보상의 특징 III. 차이점 1. 허가권자 2. 담보물 제공 여부 3. 보상금 지급절차 4. 손실보상액에 대한 불복

I. 개설

공용수용은 특정한 사유재산권의 강제적 취득을 바탕으로 하므로, 엄격한 절차에 의해 진행되어야 하나, 특별한 사유가 있는 경우는 절차 중 일부를 생략할 필요가 있다. 이에 토지보상법 38조 천재지변 시의 토지의 사용과 동법 39조 시급한 토지 사용에 대한 허가를 규정하고 있다.

II. 공통점

1. 규정 취지

천재지변이나 그 밖의 사변으로 공공의 안전을 유지하기 위한 공익사업을 긴급히 시행할 필요가 있을 때나, 공익사업이 진행되는 동안 재결이 지연됨으로써 재해를 방지할 수 없거나 공공의 이익에 현저한 지장을 줄 우려가 있다고 인정되는 경우에는 일반적인 공익사업과는 달리 보통절차를 거칠 여유가 없는바, 원활한 사업진행을 도모하기 위해 약식절차를 규정한다.

2. 요건

양자 모두 관련 행정청으로부터 허가를 받고, 토지소유자 및 점유자에게 통지를 하여야 한다. 또한 공용사용의 경우만 허용한다.

3. 사용기간 및 효과

①양자 모두 보통절차를 거치는 경우보다 재산권 침해의 정도가 커 그 기간을 6개월 미만으로 한정하여 재산권 침해를 최소화하고 있다. ②그 효과로 사업시행자의 공용사용권의 취득, 반환 및 원상회복의무, 대항·대집행정구권 및 토지소유자의 권리행사의 제한, 목적물의 인도·이전의무, 손실보상청구권 등의 효과가 발생한다.

4. 보상의 특징

토지보상법 62조 사전보상 원칙에 대한 예외로 사후보상의 성격을 갖는다.

III. 차이점

1. 허가권자

천재지변 시 토지 사용(38조)의 경우 허가권자는 특별자치도지사 및 시군구청장이나 시급한 토지 사용(39조)의 경우 사업인정 후 재결신청을 전제로 관할 토지수용위원회의 허가를 받아야 한다.

2. 담보물 제공 여부

천재지변 시의 토지의 사용(38조)의 경우 담보를 제공하지 않으나, 시급한 토지 사용(39조)의 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 담보를 제공하게 한 후 해당 토지의 사용을 허가받을 수 있다.

3. 보상금 지급절차

전자는 토지보상법 9조 5항 내지 7항을 준용하여, 그 손실에 대한 보상은 사업시행자와 손실을 입은 자가 협의하여 결정하며 협의 불성립 시 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다. 반면 후자는 동법 9조 5항~7항의 준용 규정이 없고 41조에 별도 보상규정이 있다. 즉, 토지소유자의 보상청구가 있을 때 사업시행자가 산정한 보상액을 지급하며 보상시기까지 지급하지 않은 경우 토지소유자 등은 담보물을 취득할 수 있다.

4. 손실보상액에 대한 불복

전자의 경우 손실보상액에 대한 불복의 별도 규정이 없이 토지보상법 9조 5항 내지 7항 준용규정이 있다. 보상재결의 처분성 논의에 따라 처분성 인정 시 토지보상법 83조 이의신청 및 85조 행정소송 제기가 가능하나, 처분성 부정 시 민사소송이나 당사자소송으로 불복할 수 있다. 후자의 경우 토지보상법 41조 별도 규정이 있으며 재결 전엔 사업시행자를 상대로 보상금 증액을 구하는 공법상 당사자 소송을 제기할 수 있고, 재결 후엔 재결의 불복절차를 적용할 수 있다.

02. 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상 토지사용기간 만료시의 법률관계를 설명하라. (10점) [기출8회 4]

목차
I. 개설 II. 토지사용 절차 1. 보통사용절차 2. 약식사용절차 III. 반환 및 원상회복의무(토지보상법 48조)

I. 개설

수용(收用)이란 공익사업을 위해 특정한 자가 소유하고 있는 토지 등에 관한 권리를 사업시행자가 강제적으로 취득하고 권리를 소멸시키는 것을 말한다. 사용(使用)이란 공익

사업을 위해 특정인의 토지 등에 관한 권리를 사업시행자가 일시적 또는 영속적으로 점유(占有)하여 지배하고, 그 목적에 따라 이용하는 것을 말한다. 토지사용 기간이 만료되면 토지보상법은 원상회복 반환을 원칙으로 규정하고 있다.

II. 토지사용 절차

1. 보통사용절차

보통사용절차는 보통수용절차와 동일하다. 즉, 사업인정을 받고, 토지조서 및 물건조서를 작성하여 피수용자와 협의하고, 협의 불성립 시 관할 토지수용위원회에 사용재결을 신청하여 사용재결에 따라 보상금을 지급하고 토지를 사용하면 된다. 토지사용기간은 재결에서 정한 기간이 된다.

2. 약식사용절차

약식절차란 토지의 수용 또는 사용에 관한 보통절차 가운데 그 일부를 생략하고 행하는 절차를 말한다. 토지보상법 38조 천재·지변 시의 토지사용과 39조 시급을 요하는 토지의 사용을 규정하고 있다.

III. 반환 및 원상회복의무(토지보상법 48조)

사업시행자는 토지나 물건의 사용기간이 끝났을 때나 사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 사용할 필요가 없게 되었을 때에는 지체 없이 그 토지나 물건을 그 토지나 물건의 소유자 또는 그 승계인에게 반환하여야 한다. 사업시행자는 토지소유자가 원상회복을 청구하면 미리 그 손실을 보상한 경우를 제외하고는 그 토지를 원상으로 회복하여 반환하여야 한다.

03. 사업인정 전 협의 취득 절차에 대해 설명하시오. (10점)

목차
I. 개설
II. 토지조서 및 물건조서의 작성(토지보상법 14조)
III. 보상계획의 공고 및 열람(토지보상법 15조)
IV. 보상액의 산정(토지보상법 68조)
V. 협의와 계약체결(토지보상법 16조, 17조)

I. 개설

협의를 위한 취득의 절차는 토지·물건조서의 작성(제14조), 보상계획의 공고·열람 등(제15조), 보상액의 산정(제68조), 협의(제16조), 보상계약의 체결(제17조) 단계로 이루어져 있다.

II. 토지조서 및 물건조서의 작성(토지보상법 14조)

①토지조서 및 물건조서란 공익사업을 위해 취득 또는 사용할 토지와 그 토지상의 물건 내용을 사업시행자가 일정한 절차를 거쳐 작성하는 문서이다. 조서작성은 당사자 간 분쟁 소지를 미리 예방하고, 원활한 공익사업 시행에 취지가 있다. ②사업시행자는 토지조서와 물건조서를 작성하여 서명 또는 날인을 하고 토지소유자와 관계인의 서명 또는 날인을 받아야 하나 일정한 사유로 받을 수 없는 경우 그 사유를 적어야 한다.

III. 보상계획의 공고 및 열람(토지보상법 15조)

사업시행자는 토지조서와 물건조서를 작성하였을 때에는 일정한 내용이 포함된 보상계획을 전국을 보급지역으로 하는 일간신문에 공고하고, 토지소유자 및 관계인에게 각각

통지하여야 하며, 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장에게도 통지하여야 한다. 이때 그 내용을 14일 이상 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 토지물건조서 내용에 이의가 있는 토지소유자 등은 열람기간 내에 사업시행자에게 서면으로 이의를 제기할 수 있다.

IV. 보상액의 산정(토지보상법 68조)

①사업시행자는 보상액을 산정하려는 경우 감정평가법인등 3인(감정평가법인등을 추천하지 아니하는 경우에는 2인)을 선정하여 토지 등의 평가를 의뢰하여야 한다. ②사업시행자는 보상평가서를 검토한 결과 그 평가가 관계법령에 위반하여 평가되었거나 합리적 근거 없이 비교 대상이 되는 표준지의 공시지가와 현저하게 차이가 나는 등 부당하게 평가되었다고 인정하는 경우에는 당해 감정평가법인등에게 그 사유를 명시하여 다시 평가할 것을 요구하여야 한다.

V. 협의와 계약체결(토지보상법 16조, 17조)

①협의란 공익사업에 필요한 토지 등의 권리 취득 및 소멸 등을 위해 행하는 사업시행자와 피수용자 간의 임의적 합의를 말한다(제16조). ②법적성질 관해 견해대립이 있으나 판례는 손실보상의 협의는 공공기관이 사경제주체로서 행하는 사법상 계약의 실질을 가지는 것으로 본다. ③토지 등의 구체적 대상, 범위, 보상의 시기·방법·절차 및 금액 등이 협의의 내용이 되고(령 제8조 제1항), 계약의 내용에는 계약의 해지 또는 변경에 관한 사항과 이에 따르는 보상액의 환수 및 원상복구 등에 관한 사항이 포함되어야 한다(령 제8조 제4항). ④협의 성립 시 협의의 내용에 따른 사법상 계약의 효과가 발생한다. ⑤협의 불성립 시 사업시행자는 협의경위서를 작성하여 토지소유자 등의 서명 또는 날인을 받아야 하며 받을 수 없는 경우 그 사유를 기재하여야 한다. 사업시행자는 공익사업의 진행을 위해 국토교통부장관에게 사업인정을 신청할 수 있다.

04. 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상 사업인정 전 협의와 사업인정 후 협의를 비교하라. (10점) [기출 8회 4]

목차
I. 개설 II. 공통점 1. 제도적 취지 2. 협의의 내용(토지보상법 50조) III. 차이점 1. 법적성질 및 권리구제 차이 2. 필수적 전치 여부 및 확인제도 유무 3. 효과상 차이 IV. 양자의 관계

I. 개설

협의란 공익사업에 필요한 토지 등의 권리 취득 및 소멸 등을 위해 행하는 사업시행자와 피수용자 간의 임의적 합의를 말한다. 토지보상법상 사업인정 전 협의 취득(16조)과 사업인정 후 협의 취득(26조)을 규정한다. 이하 양자를 비교한다.

II. 공통점

1. 제도적 취지

협이는 임의적 합의를 바탕으로 하여 최소 침해의 원칙을 구현하고, 토지소유자 및 관계인에게 해당 사업의 취지를 이해시켜 신속하게 사업을 수행하고자 함에 그 취지가 있다.

2. 협의의 내용(토지보상법 50조)

협의를 내용은 토지·물건조서의 작성범위 내이고, 구체적 내용으로는 토지보상법 50조의 수용 또는 사용할 토지의 구역 및 사용방법, 손실보상, 수용 또는 사용의 개시일과 기간, 그 밖에 이법 및 다른 법률에서 규정한 사항 등이 있다.

III. 차이점

1. 법적성질 및 권리구제 차이

사업인정 전후 협의의 법적성질 관련 논의가 있으나 ①사업인정 전 협의는 다수설과 판례는 <사법상 계약>으로 보고, 사업인정 전 협의에 대해 다툼이 있는 경우 <민사소송>에 의한다. 반면, ②사업인정 후 협의에 대해 판례는 <사법상 계약>으로 보나, 다수설은 수용권 실행 방법의 하나로 <공법상 계약>으로 이해하고 있다. 다수설에 의할 경우 사업인정 후 협의에 대해 다툼이 있는 경우 <공법상 당사자소송>에 의하게 된다.

2. 필수적 전치 여부 및 확인제도 유무

사업인정 전 협의는 임의적 절차이나, 사업인정 후 협의는 필수적 절차이다. 토지보상법은 사업인정 전 협의는 사업시행자의 성신탁의무만을 규정하고 있지만, 사업인정 후 협의는 반드시 거칠 것을 의무로 규정하고 있다. 단지 절차의 중복을 피하기 위하여 사업인정 후 협의를 일정한 경우 하지 않을 수 있는 규정을 두고 있을 따름이다.

3. 효과상 차이

①사업인정 전 협의는 협의성립확인 제도가 없으며, 사업인정 후 협의는 협의성립확인을 받으면 재결로 간주되는 규정이 있다. 이에 ②사업인정 전 협의 성립 시 승계취득으로 보며, 사업인정 후 협의 성립 시 협의성립확인 받기 전엔 승계취득, 협의성립확인 후엔 재결로 간주하는바, 원시취득으로 본다. ③사업인정 전 협의 불성립 시 사업인정 신청을 시작으로 강제수용 절차를 진행할 수 있고, 사업인정 후 협의 불성립 시 사업시행자는 재결 신청을, 피수용자는 재결신청청구를 할 수 있다.

IV. 양자의 관계

①<선후관계> 양 협의 간에는 사업인정 이전인지 이후인지에 따른 기본적인 선후관계가 존재한다. 그러나 구속력이 있는 것은 아니다. ②<생략 가능성> 사업인정 후 협의는 원칙상 필수절차이지만 일정요건을 충족하면 생략할 수 있다.

05. 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상 사업인정 전 협의와 사업인정 후 협의의 차이점에 대하여 설명하시오. (10점)

[기출25회 4]

목차
I. 협의의 의의, 근거, 취지
II. 법적성질의 차이
1. 사업인정 전 협의
2. 사업인정 후 협의
III. 필수적 절차 여부 차이
IV. 협의 성립 시 효과의 차이
V. 협의 불성립 시 효과의 차이
VI. 권리구제의 차이

I. 협의의 의의, 근거, 취지

협의란 공익사업에 필요한 토지 등의 권리 취득 및 소멸 등을 위해 행하는 사업시행자와 피수용자 간의 임의적 합의를 말한다(제16조, 26조). 협의는 수용에 의한 강제적 취득 전에 최소 침해 원칙을 실현하는 제도적 취지가 있다.

II. 법적성질의 차이

1. 사업인정 전 협의

①사법상 계약설과 공법상 계약설로 견해 대립이 있으나 ②판례는 손실보상의 협의는 공공기관이 사경제주체로서 행하는 사법상 계약의 실질을 가지는 것으로 본다. ③협의가 토지소유자의 의사에 의해 좌우되고, 협력을 바탕으로 하기 때문에 그 실질에 있어

서 사법상 계약이 타당하다.

2. 사업인정 후 협의

①국가수용권설 입장에서 수용자와 피수용자 간 대등한 지위에서 행하는 임의적 합의로 보는 <사법상 계약설>과 사업시행자수용권설에서 사업시행자가 수용권 주체로서 수용권을 실행하는 방법의 하나로 보는 <공법상 계약설>이 대립하며 <공법상 계약설>이 다수설이다. ②판례는 사법상 법률행위로 보나 최근 판시에서 <사법상 계약>으로 보면서 협의취득 과정에서 공익적 특성을 고려해야 한다고 판시하였다. ③협이는 사업시행자가 수용권의 주체로서 수용권을 실행하는 하나의 방법으로서, 협의가 성립하면 확인의 절차를 거쳐 수용의 효과가 발생하게 되므로 공법상 계약으로 보는 것이 타당하다.

III. 필수적 절차 여부 차이

사업인정 전 협의는 임의적 절차이나, 사업인정 후 협의는 필수적 절차이다. 토지보상법은 사업인정 전 협의는 사업시행자의 성실협의를무만을 규정하고 있지만, 사업인정 후 협의는 반드시 거칠 것을 의무로 규정하고 있다. 단지 절차의 중복을 피하기 위하여 사업인정 후 협의를 일정한 경우 하지 않을 수 있는 규정을 두고 있을 따름이다.

IV. 협의 성립 시 효과의 차이

①사업인정 전 협의는 협의성립확인 제도가 없으며, 사업인정 후 협의는 협의성립확인을 받으면 재결로 간주되는 규정이 있다. 이에 ②사업인정 전 협의 성립 시 승계취득으로 보며, 사업인정 후 협의 성립 시 협의성립확인 받기 전엔 승계취득, 협의성립확인 후엔 재결로 간주하는바, 원시취득으로 본다.

V. 협의 불성립 시 효과의 차이

사업인정 전 협의 불성립 시 사업인정 신청을 시작으로 강제수용 절차를 진행할 수 있고, 사업인정 후 협의 불성립 시 사업시행자는 재결 신청을, 피수용자는 재결신청청구를 할 수 있다.

VI. 권리구제의 차이

다수설, 판례에 의하면 사업인정 전 협의 불복 시 민사소송으로 다투나, 사업인정 후 협의 불복 시 다수설에 의하면 공법상 당사자소송, 판례에 의하면 민사소송으로 다툰다.

06. 토지보상법상의 사업인정과 사업인정고시의 법적 성질에 관하여 설명하시오. (10점)[기출34회 1-1]

목차
I. 사업인정(토지보상법 20조) 1. 의의 및 취지, 근거 2. 법적성질 1) 행정쟁송법상 처분 2) 설권적 형성행위(특허) 3) 재량행위 4) 제3자효 행정행위 II. 사업인정고시(토지보상법 22조) 1. 의의 2. 법적성질 1) 사업인정의 효력발생요건 2) 설권적 형성행위(특허) 여부 3. 사업인정고시의 효과

I. 사업인정(토지보상법 20조)

1. 의의 및 취지, 근거

사업인정이란 공익사업을 토지 등을 수용하거나 사용할 사업으로 결정하는 것을 말한다(제2조 제7호). 사업인정은 당해 사업이 토지보상법 제4조에 해당함을 인정하고, 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정하는 행위이다(제20조). 사업인정은 당해 사업이 공공성이 있는가를 개별·구체적으로 판단하여 피수용자의 권리를 보호하고, 이에 의해 수용 가능여부가 결정되는 수용절차의 제1단계로서, 수용행정의 적정화, 사전적 권리구제장치로서의 역할을 한다.

2. 법적성질

1) 행정쟁송법상 처분

사업인정은 행정청이 구체적 사실에 대한 법 집행으로서 외부에 대하여 직접적 법적 효과를 발생시키는 권력적 행위인 공법행위이다. 사업인정이 있으면 수용할 목적물임 범위가 확정되는 등 토지소유자 등에게 일정한 구체적 법적 효과가 발생하므로, 강학상 행정행위이자, 행정쟁송법상 처분이다.

2) 설권적 형성행위(특허)

①사업시행자수용권설에 의거하여 사업시행자에게 토지를 수용할 수 있는 공익사업자의 법적 지위를 설정하여 주는 행위로 보는 <설권적 형성행위설>과 국가수용권설에 의거하여 단순히 특정 사업이 공용수용을 할 수 있는 사업에 해당하는 것을 확인하는 행위라는 <확인행위설>이 대립한다. ②판례는 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정하는 형성행위라 판시한 바 있다. ③사업인정은 특정 사업의 공익성 여부를 모든 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여 수용권을 설정해주는 것으로 설권적 형성행위로 보는 것이 타당하다.

3) 재량행위

①<설권적 형성행위설>은 재량행위로 보고, <확인행위설>은 기속행위로 본다. ②<판례>는 사업의 공익성 여부는 모든 사정을 참작하여 구체적으로 판단해야 하므로 행정청의 재량에 속한다고 판시한 바 있다. ③<검토>토지보상법 20조 규정상 불분명하나 국토교통부장관이 사업인정 시 이해관계인의 의견청취를 거치고 중앙토지수용위원회의 공익성 검토를 거치는 바 재량행위로 봄이 타당하다.

4) 제3자효 행정행위

사업시행자에게는 수익적 효과를 제3자인 피수용자에게는 침익적 효과를 발생시키는 바 제3자효 행정행위이다.

II. 사업인정고시(토지보상법 22조)

1. 의의

사업인정고시란 사업인정 효과가 미치는 범위를 누구에게나 확인할 수 있도록 나타내는 절차이다.

2. 법적성질

1) 사업인정의 효력발생요건

국토교통부장관은 사업인정을 하였을 때에는 지체 없이 그 뜻을 사업시행자, 토지소유자 및 관계인, 관계 시·도지사에게 통지하고 사업시행자의 성명이나 명칭, 사업의 종류, 사업지역 및 수용하거나 사용할 토지의 세목을 관보에 고시하여야 한다(제22조 제1항). 사업인정의 사실을 통지받은 시·도지사(특별자치도지사를 제외함)는 관계 시장·군수 및 구청장에게 이를 통지하여야 한다(제22조 제2항). 사업인정은 고시한 날부터 그 효력이 발생한다(제22조 제3항). 사업인정은 통지가 있었다 하더라도 고시가 없으면 효력이 발생되지 아니한다.

2) 설권적 형성행위(특허) 여부

①사업인정고시는 특정한 사실을 알리는 행위로서 사업인정과는 분리하여 준법률행위적 행정행위 중 통지로 보는 견해, ②사업인정과 사업인정고시를 통일적으로 파악하여 특허로 보는 견해가 있다. ③해당 논의는 불복과 관련하여 실익이 있는바 사업인정고시는 사업인정의 효력발생요건으로 사업인정과 사업인정고시를 통일적으로 특허로 봄이 타당하다.

3. 사업인정고시의 효과

①사업시행자: <토지수용권의 발생>사업인정이 고시됨으로써 사업시행자는 자기가 시행하는 공익사업을 위하여 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 목적물을 수용할 수 있는 권한이 부여된다. ②목적물: <수용목적물의 확정>사업인정이 고시되면 수용 또는 사용할 토지의 범위가 특정된다. ③관계인: <관계인의 범위확정>사업인정 고시가 있는 후 권리를 취득한 자는 기존 권리를 승계한 자를 제외하고는 관계인에 포함되지 아니한다. ④피수용자의 토지 등의 보전 의무(25조): 사업인정고시가 된 후에는 누구든지 고시된 토지에 대하여 사업에 지장을 줄 우려가 있는 형질의 변경이나 제3조에 규정된 물건을 손괴하거나 수거하는 행위를 하지 못한다. ⑤사업시행자의 토지 및 물건조작권(27조): 사업인정고시 후 사업시행자 또는 감정평가를 의뢰받는 감정평가법인등은 조서작성이나 감정평가를 위하여 필요한 경우 허가 없이도 해당 토지나 물건에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다.

07. 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률상 사업인정고시의 효과에 대해 설명하시오. (10점) [기출23회4]

목차
I. 사업인정고시(토지보상법 22조) II. 사업인정고시의 효과 1. 토지수용권의 발생 2. 수용목적물의 확정 3. 관계인의 범위 제한 4. 토지 등의 보전의무 5. 토지·물건조사권의 발생

I. 사업인정고시(토지보상법 22조)

사업인정고시란 사업인정 효과가 미치는 범위를 누구에게나 확인할 수 있도록 나타내는 절차이다. 사업인정은 통지가 있었다 하더라도 고시가 없으면 효력이 발생되지 아니한다.

II. 사업인정고시의 효과

1. 토지수용권의 발생

사업인정이 고시됨으로써 사업시행자는 자기가 시행하는 공익사업을 위하여 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 목적물을 수용할 수 있는 권한이 부여된다.

2. 수용목적물의 확정

사업인정이 고시되면 수용 또는 사용할 토지의 범위가 특정된다. 사업시행자는 수용 또는 사용할 토지의 위치와 예정 면적의 범위가 정해지면 그 범위 내에서 공익사업의 시행에 따른 권리를 행사할 수 있고 현재 또는 장래의 권리자에게 대항할 수 있다.

3. 관계인의 범위 제한

사업인정 고시가 있는 후 권리를 취득한 자는 기존 권리를 승계한 자를 제외하고는 관계인에 포함되지 아니한다(제2조 제5호). 사업인정고시가 있는 후 새로이 권리를 취득한 자는 관계인으로 인정되지 않기 때문에 보상금을 받을 수 없다. 관계인의 범위를 한정하는 것은 수용절차에 참여하는 자를 제한함으로써 절차를 간소하게 하는 데 이바지한다.

4. 토지 등의 보전의무

사업인정고시가 된 후에는 누구든지 고시된 토지에 대하여 사업에 지장을 줄 우려가 있는 형질의 변경이나, 제3조에 규정된 물건을 손괴하거나 수거하는 행위를 하지 못한다(제25조 제1항). 사업인정고시가 된 후에 고시된 토지에 건축물의 건축·대수선, 공작물의 설치 또는 물건의 부가(附加)·증치(增置)를 하려는 자는 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다. 이 경우 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장은 미리 사업시행자의 의견을 들어야 한다(제25조 제2항). 이 규정을 위반하여 건축물의 건축·대수선, 공작물의 설치 또는 물건의 부가·증치를 한 토지소유자 또는 관계인은 해당 건축물·공작물 또는 물건을 원상으로 회복하여야 하며 이에 관한 손실의 보상을 청구할 수 없다(제25조 제3항).

5. 토지·물건조사권의 발생

사업인정고시 후 사업시행자 또는 감정평가를 의뢰받은 감정평가법인등은 조서작성이나 감정평가를 위하여 필요한 경우 허가 없이도 해당 토지나 물건에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다. 이 경우 출입의 통지(제10조), 토지점유자의 인용의무(제11조) 및 증표 등의 휴대 규정(제13조) 규정을 준용한다(제27조 제1항).

08. 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률상 사업인정의 법적 성질과 권리구제에 대해 논하시오.(10점)[기출12회3][기출1회 1변형]

목차
I. 사업인정의 의의, 취지, 근거(토지보상법 20조) II. 사업인정의 법적성질 III. 사업인정의 권리구제 1. 피수용자 1) 사전적 권리구제 2) 사후적 권리구제 2. 사업시행자 1) 사업인정 거부 2) 사업인정 부작위

I. 사업인정의 의의, 취지, 근거(토지보상법 20조)

사업인정이란 공익사업을 토지등을 수용하거나 사용할 사업으로 결정하는 것을 말한다. 공익사업을 통한 공공복리의 증진 및 사전적 권리구제장치로서 그 취지가 있다.

II. 사업인정의 법적성질

①행정쟁송법상 처분: 사업인정은 행정청이 구체적 사실에 대한 법집행으로서 외부에 대하여 직접적 법적 효과를 발생시키는 권력적 행위인 공법행위이다. ②형성적 행정행위(설권적 형성행위): 학설은 <설권적 형성행위설>과 <확인행위설>이 대립하나, 판례는 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정하는 형성행위라 판시한 바 있다. 생각건대, 사업인정은 특정 사업의 공익성 여부를 모든 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여 수용권을 설정해주는 것으로 설권적 형성행위로 보는 것이 타당하다. ③재량행위: 토지보상법 20조 규정상 불분명하나 국토교통부장관이 사업인정 시 이해관계인의 의견

청취를 거치고 중앙토지수용위원회의 공익성 검토를 거치는 바 재량행위로 봄이 타당하다. ④제3자효 행정행위: 사업시행자에게는 수익적 효과를 제3자인 피수용자에게는 침익적 효과를 발생시키는 바 제3자효 행정행위이다.

III. 사업인정의 권리구제

1. 피수용자

1) 사전적 권리구제

법21조 이해관계인 의견청취절차 규정이 있다. 예방적금지소송과 가처분을 고려해볼 수 있으나 판례는 부정하며 현행법상 인정되기 어려울 것이다.

2) 사후적 권리구제

①<위법한 사업인정> 행정쟁송에 관해 토지보상법에 규정이 없는 바 행정심판법과 행정소송법이 적용된다. 국가배상과 집행정지 및 결과제거청구권을 고려해볼 수 있다. ②<적법한 사업인정> 보상규정 있으면 손실보상을, 보상규정 없으면 나머지 손실보상요건 충족 시 헌법23조 효력논의(보상규정 흠결)를 통한 손실보상을 고려해볼 수 있다.

2. 사업시행자

1) 사업인정 거부

<행정심판>에서는 의무이행심판과 거부처분취소심판이 가능할 것으로 보인다. <행정소송>거부가 처분이 되기 위한 요건을 갖출 경우 거부처분취소소송이 가능할 것으로 보인다. 요건 충족 시 국가배상청구도 가능할 것이다. 의무이행소송과 가구제도 고려해볼 수 있으나 판례는 부정하며 현행법상 인정되기 어려울 것으로 보인다.

2) 사업인정 부작위

<행정심판>에서는 의무이행심판을, <행정소송>에서는 부작위위법확인소송이 가능하며 요건 충족 시 국가배상도 가능할 것이다. 의무이행소송이나 가구제는 어려울 것이다.

09. 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 의한 실효 제도를 설명하고, 이로 인하여 불이익을 받게 되는 피수용자에게 손실보 상청구권이 있는지 설명하시오. (10점)[기출6회1 변형]

목차
I. 토지보상법상 실효제도(23조, 24조, 42조) II. 사업인정의 실효 1. 사업인정의 의의 및 효과(법20조) 2. 재결신청 해태로 인한 실효(법23조) 3. 사업의 폐지·변경으로 인한 실효(법24조) III. 재결의 실효 1. 재결(법34조) 2. 재결의 실효 사유(법42) IV. 실효의 효과와 피수용자의 손실보상청구권 1. 사업인정 실효로 인한 손실보상(법9조5항~7항준용) 2. 재결 실효로 인한 손실보상(법9조5항~7항 준용)

I. 토지보상법상 실효제도(23조, 24조, 42조)

실효란 유효하게 성립한 행정행위가 객관적 사실의 발생으로 그 효력이 당연히 상실되는 것이다. 토지보상법상 실효제도는 크게 사업인정의 실효와 재결의 실효로 볼 수 있다.

II. 사업인정의 실효

1. 사업인정의 의의 및 효과(법20조)
사업인정이란 공익사업을 토지 등을 수용하거나 사용할 사업으로 결정하는 것이다.

2. 재결신청 해태로 인한 실효(법23조)

사업시행자가 22조1항에 따른 사업인정의 고시가 된 날부터 1년 이내에 28조 1항에 따른 재결신청을 하지 아니한 경우에는 사업인정고시가 된 날부터 1년이 되는 날의 다음 날에 사업인정은 그 효력을 상실한다.

3. 사업의 폐지·변경으로 인한 실효(법24조)

사업인정고시가 된 후 사업의 전부 또는 일부를 폐지하거나 변경함으로 인하여 토지 등의 전부 또는 일부를 수용하거나 사용할 필요가 없게 되었을 때 사업시행자의 신고 또는 시도지사의 판단에 따른 고시로, 고시가 된 날부터 그 내용에 따라 사업인정의 전부 또는 일부는 효력을 상실한다.

III. 재결의 실효

1. 재결(법34조)

수용재결이란 사업시행자에게 부여된 수용권의 구체적 내용을 결정하고, 그 실행을 완성시키는 공용수용·사용의 종국적 절차이다.

2. 재결의 실효 사유(법42)

①사업시행자가 수용 또는 사용의 개시일까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급하거나 공탁하지 아니하였을 때에는 해당 토지수용위원회의 재결은 효력을 상실한다. ②재결 이후 수용·사용 개시일 전인 경우 사업인정의 취소 혹은 변경 시 그 고시 결과에 따라 재결의 효력은 상실된다. 그러나 보상금의 지급 또는 공탁이 있는 후에는 이미 수용의 효과가 발생하므로 재결의 효력에는 영향이 없다.

IV. 실효의 효과와 피수용자의 손실보상청구권

1. 사업인정 실효로 인한 손실보상(법9조5항~7항 준용)

사업인정의 효력이 상실되며 사업시행자는 사업인정이 실효됨으로 인하여 토지소유자나 관계인이 입은 손실을 보상하여야 한다(법23조2, 3항, 법24조 7, 8항). 손실의 보상은 사업시행자와 피수용자가 협의하여 결정하며 협의 불성립 시 사업시행자나 피수용자는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다. 즉, 피수용자에게 손실보상청구권이 있으며 이는 손실이 있음을 안 날부터 1년, 발생한 날부터 3년 이내 청구해야 한다.

2. 재결 실효로 인한 손실보상(법9조5항~7항 준용)

재결의 효력이 상실되며 사업시행자는 이로 인하여 토지소유자 또는 관계인이 입은 손실을 보상하여야 한다. 손실의 보상은 사업시행자와 피수용자가 협의하여 결정하며 협의 불성립 시 사업시행자나 피수용자는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다. 즉, 피수용자에게 손실보상청구권이 있으며 이는 손실이 있음을 안 날부터 1년, 발생한 날부터 3년 이내 청구해야 한다.

10. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제26조는 수용 재결 신청 전에 사업시행자로 하여금 수용대상 토지에 관하여 권리를 취득하거나 소멸시키기 위하여 토지소유자 및 관계인과 교섭하도록 하는 협의제도를 규정하고 있다. 이에 따른 협의가 수용재결 신청 전의 필요적 전치절차인지 여부와 관할 토지수용위원회에 의한 협의성립의 확인의 법적 효과를 설명하시오. (10점) [기출30회 4]

목차
I. 논점의 정리 II. 협의가 수용재결 신청 전의 필요적 전치절차인지 1. 협의의 개념 및 법적 성질(법 16조 및 법26조) 2. 필요적 전치절차 여부 III. 협의성립확인 의 법적 효과 1. 의의 및 성질(법29조; 재결로 간주(원시취득)) 2. 법적효과(재결효, 차단효, 불가변력) 3. 확인의 실효 여부

I. 논점의 정리

협의가 수용재결 신청 전의 필요적 전치절차인지 여부와 관할 토지수용위원회에 의한 협의 성립의 확인의 법적 효과를 토지보상법 규정을 중심으로 설명한다.

II. 협의가 수용재결 신청 전의 필요적 전치절차인지

1. 협의의 개념 및 법적 성질(법 16조 및 법26조)

협의란 양 당사자 간의 의사합치로 최소 침해 원칙의 구현에 취지가 있다. 판례는 사경 제주체로서 행하는 사법상 계약의 실질을 가지는 것으로 사법상계약으로 본다. 토지보상법에서는 사업인정 전 협의(법 16조)와 사업인정 후 협의(법26조)로 일련의 절차를 두

고 있으며, 협의가 성립하는 경우 목적물의 승계취득 및 계약의 구속성 등의 효과가 발생한다.

2. 필요적 전치절차 여부

사업인정 전 협의(법16조)는 임의적 절차이나, 사업인정 후 협의인 토지보상법 26조는 16조를 준용하여 사업시행자가 피수용자와 성실하게 협의하여야 한다고 규정하면서, 사업인정 이전에 협의절차를 거쳤으나, 협의가 성립되지 아니하여 사업인정을 받은 사업으로서 토지조서 및 물건조서의 내용에 변동이 없을 때에는 협의절차를 거치지 아니할 수 있다고 하여, 원칙상 필수절차이나, 예외적으로 생략할 수 있도록 하였다. 그러나 생략 가능한 경우라 하더라도 사업시행자나 토지소유자 및 관계인이 협의를 요구할 때에는 협의를 거쳐야 한다.

III. 협의성립확인 의 법적 효과

1. 의의 및 성질(법29조; 재결로 간주(원시취득))

① 협의성립확인이란 사업인정 후 협의 성립 시 사업시행자가 피수용자의 동의를 받거나 또는 공증을 받아 관할 토지수용위원회에 협의성립확인을 받는 제도이다. ② 수용의 목적을 달성하고, 계약 불이행에 따른 분쟁 예방, 공익사업의 원활한 진행을 기함에 취지가 있다. ③ 법적성질 관련 견해대립이 있으나 법규정상 협의성립확인 은 재결로 보며, 확인 시 협의의 성립이나 내용을 다룰 수 없다는 확정력이 부여되므로 재결과 같은 형성적 행정행위로 봄이 타당하다.

2. 법적효과(재결효, 차단효, 불가변력)

① <재결효> 확인은 이 법에 따른 재결로 보며, 사업시행자, 토지소유자 및 관계인은 그 확인된 협의의 성립이나 내용을 다룰 수 없다(제29조 제4항). 확인은 재결로 보므로 재결의 효과와 같은 효과가 발생한다. ② <차단효> 확인된 협의의 성립이나 내용을 다룰 수 없으므로, 협의에 대하여 불가변력, 즉 확정력이 발생한다

3. 확인의 실효 여부

확인 은 재결로 간주되므로, 협의에서 정한 보상의 시기까지 보상을 하지 않으면 재결실 효규정이 적용되어 확인의 효력은 상실된다고 볼 것이다. 이 때 협의의 효력도 상실되는지 논란이 있으나, 협의는 계약이므로 계약불이행의 문제가 발생되고, 곧바로 협의의 효력이 상실된다고 볼 수는 없다.

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 개별법 기본강의 3회

<재결신청청구권>

02. 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률상 토지소유자 및 관계인에게 인정되는 재결신청청구권에 대해 설명하시오. (10점)

목차
I. 의의, 취지, 근거, 법적성질
II. 요건 및 내용·형식
III. 청구기간의 예외
IV. 청구의 효과
V. 권리구제

I. 의의, 취지, 근거, 법적성질(토지보상법 30조)

①재결신청청구권은 사업인정 후 협의가 성립되지 않을 경우 피수용자가 사업시행자에게 서면으로 재결신청을 조속히 할 것을 청구하는 권리이다. ②수용의 법률관계의 조속한 확정을 통한 피수용자의 권익보호와 수용당사자간 공평의 원칙에 그 취지가 있다. ③재결 보상금에 부수하여 (구)공익사업법상 인정되는 공법상 청구권의 성질을 지닌다.

II. 요건 및 내용·형식

사업인정 후 협의 불성립 시, 협의기간 만료일 이후 사업인정고시일부터 1년 이내(재결신청기간 만료일)에 청구하여야 한다. 청구권자는 피수용자로 사업시행자에게 서면으로 청구한다.

III. 청구기간의 예외

①협의 불성립·불능 시, ②사업인정 후 상당 기간이 지나도록 사업시행자의 협의 통지가 없는 경우, ③협의 불성립이 명백한 경우에 협의기간 종료 전이라도 재결신청청구가 가능(판례)하다. 단, 60일 기산점은 당초 협의기간 만료일이다.

IV. 청구의 효과

①사업시행자의 재결신청의무(법30조2항): 사업시행자는 재결신청청구 받은 날로 60일 내 관할 토지수용위원회에 재결을 신청하여야 한다. 판례는 협의 불성립이 명백한 경우 협의 기간 만료일부터 60일을 기산한다.
 ②사업시행자의 자연가산금 지급의무(법30조3항): <자연가산금지급> 청구 받은 날로 60일 초과하여 재결신청 시, 토지수용위원회의 재결보상금에, 지연된 기간에 대해 법정이율을 적용한 금액(지연가산금)을 가산하여 지급하여야 한다. <협의불성립이 명백한 경우>는 협의기간 만료일이 자연가산금 기산일이다. <협의기간 종료 전 협의기간 연장된 경우>는 당초의 협의기간 만료일부터 기산하여야 한다.

V. 권리구제

①사업시행자가 재결신청청구를 거부 또는 부작위하는 경우 판례 태도에 비추어 볼 때 공법상 당사자소송이나 민사소송으로 다투기 어렵다. 토지보상법 30조 신청권이 있고, 권리의무에 직접 영향을 미치며, 재결신청청구 거부 시 실질적 재결의 거부로 볼 수 있는 점, 사업인정이 실효되지 않는 한 피수용자에게 다른 구제방법이 없는 점 등을 고려할 때 공권력행사로 볼 수 있기 때문에 사업시행자가 재결신청청구를 거부 또는 부작위하는 경우 항고소송으로 다툴 수 있다. 판례도 취소소송 또는 부작위위법확인소송의 방법으로 다툴 수 있다고 본다. ②판례는 자연가산금을 수용보상금에 대한 법정 지연손해금의 성격을 가진다고 하였고, 자연가산금에 대한 다툼은 85조2항 보상금증감청구소송에 의한다고 판시하였다. 토지보상법 83조 이의신청으로 자연가산금에 대한 다툼이 가능하다.

03. 국토부장관은 2013. 11. 18. 사업시행자를 'A공사'로, 사업시행지를 'X시 일대 8,958,000㎡'로, 사업시행기간을 '2013. 11.부터 2017. 12. 까지'로 하는 '◇◇공구사업'에 대해서「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 사업인정을 고시하였고, 사업시행기간은 이후 '2020. 12.까지'로 연장되었다. 사업시행지 내 피수용자 甲과 A공사는 사업시행지 내의 토지에 대해「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)」에 따른 협의 매수를 하기 위한 협의를 시작하였으나 협의 과정에서 일부 지장물에 관하여 협의가 이루어지지 않아 甲이 A공사에게 재결신청을 청구했으나 A공사가 재결신청을 하지 않는 경우, 甲의 불복 방법에 관하여 검토하시오. (15점) [기출32회 1-1]

목차

I. 논점의 정리

II. A공사의 부작위

1. 부작위의 의의 및 성립요건(행정소송법 2조1항2호)
2. A공사의 재결신청 할 법률상 의무 존재
3. 甲의 법규상 조리상 신청권
4. 기타 부작위 성립요건

III. 부작위위법확인소송(행정소송법 38조2항 등)

IV. 의무이행심판 (행정심판법 5조3호)

V. 의무이행소송 등 가능성

VI. 관련판례(거부처분취소소송이나 부작위위법확인소송)

I. 논점의 정리

A공사의 재결신청을 하지 않은 것이 부작위에 해당하는지 검토 후 불복방법으로 의무이행심판, 부작위위법확인소송, 의무이행소송 등을 검토한다.

II. A공사의 부작위

1. 부작위의 의의 및 성립요건(행정소송법 2조1항2호)

부작위는 행정청이 당사자의 신청에 대해 상당한 기간 내 일정한 처분을 해야 할 할 법률상 의무가 있음에도 이를 하지 않는 것을 의미한다. 당사자의 신청, 상당한 기간, 일정한 처분을 할 법률상 의무, 무응답의 존재가 필요하다.

2. A공사의 재결신청 할 법률상 의무 존재

재결신청은 사업시행자의 공법행위로서 사실행위이나, 재결신청이 있어야 수용재결이 이루어지고, 수용재결이 토지수용위원회의 공권력행사이므로, 재결신청청구 거부 시 재결의 거부와 같은 결과를 가져올 수 있는 점, 사업인정이 실효되지 않는 한 피수용자에게 다른 구제방법이 없는 점 등을 고려하여 공권력행사로 봄이 타당하다. 따라서 사업시행자는 재결신청 청구를 받은 날로부터 60일 내 재결신청을 할 의무가 있으며, 이러한 의무는 토지보상법 제30조에 따른 일정한 처분을 할 법률상 의무에 해당한다.

3. 甲의 법규상 조리상 신청권

위 신청권 요부에 대해 견해가 대립하나, 판례는 일반적 추상적 응답신청권으로 보아 필요하다고 본다. 판례의 태도가 타당하며, 甲에게는 토지보상법 30조1항의 신청권이 있다.

4. 기타 부작위 성립요건

나머지 당사자 신청, 상당한 기간, 일정한 처분을 할 법률상의 의무, 무응답의 존재가 충족되므로, 사안의 A공사의 부작위는 행정소송법 2조1항2호에 해당한다.

III. 부작위위법확인소송(행정소송법 38조2항 등)

부작위위법확인소송은 행정청의 부작위가 위법하다는 것을 확인하는 소송으로 행정청이 신청에 따른 일정 처분을 하여야 함에도 아무런 응답을 하지 않는 것이 위법하다는 확인을 구하는 소송이다. 대상적격 및 원고적격 등 소송요건을 갖춘 것으로 보이며, 소송

의 심리범위에 관하여, 판례는 그 부작위가 위법하다는 것을 확인함으로써 행정청의 응답을 신속하게 하여 부작위 또는 무응답이라는 소극적인 위법상태를 제거하는 것을 목적으로 한다고 하여 절차적 심리설을 취하므로, 甲은 부작위위법확인소송으로 권리구제가 가능하다.

IV. 의무이행심판 (행정심판법 5조3호)

의무이행심판이란 당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대해 일정한 처분을 하도록 하는 행정심판을 의미한다. A공사는 재결신청할 법률상 의무가 있으므로, 甲은 의무이행심판을 불복방법으로 고려할 수 있다.

V. 의무이행소송 등 가능성

법원의 판결에 의해 행정청으로 하여금 그 거부나 방치된 행정행위를 하여 줄 것을 구하는 내용의 행정소송으로 인정여부에 대해 부정설, 긍정설, 제한적 긍정설이 대립하나, 판례는 검사에게 압수물 환부를 이행하라는 청구는 행정소송법상 허용되지 아니한다고 하여 부정설의 입장이다. 생각건대, 현행 행정소송법 규정 아래에서는 의미이행소송은 인정된다고 보기 어려워 현실적인 불복방법으로 보기 어려우며, 장기적으로 입법으로 해결할 필요가 있다. 판례는 민사상 가처분 제도를 행정소소에 준용하지 않으므로, 위 제도 역시 현실적인 불복방법으로 보기 어렵다.

VI. 관련판례(거부처분취소소송이나 부작위위법확인소송)

판례는 토지소유자나 관계인의 재결신청 청구에도 불구하고 사업시행자가 재결신청을 하지 않을 때 토지소유자나 관계인은 사업시행자를 상대로 거부처분 취소소송 또는 부작위 위법확인소송의 방법으로 다투어야 한다고 판시한 바 있다. 사안의 재결신청을 하지 않은 것을 묵시적 거부처분으로 볼 경우, 취소소송의 방법으로 불복할 수 있다.

<재결신청권 및 재결신청청구권>

04. 사업인정 후 당사자 간 협의가 불성립한 경우 사업시행자와 피수용자가 할 수 있는 행위로, 토지보상법상 인정되는 절차를 설명하시오. (10점)

목차
I. 개설 II. 사업시행자의 재결신청권(토지보상법 28조) 1. 의의 및 근거 2. 요건 및 절차 3. 사업시행자에게만 재결신청권을 인정하는 이유 III. 피수용자의 재결신청청구권(토지보상법 30조) 1. 의의 2. 요건 3. 절차

I. 개설

토지보상법은 사업인정 후 협의 불성립 또는 불능 시 사업시행자에게는 재결신청권을, 토지소유자와 관계인에게는 재결신청청구권을 인정하고 있다.

II. 사업시행자의 재결신청권(토지보상법 28조)

1. 의의 및 근거

재결신청은 협의 불성립 시 사업시행자가 토지수용위원회에게 수용 또는 사용의 재결을 구하는 절차 행위이다. 토지보상법 제28조에 근거를 둔다.

2. 요건 및 절차

① <재결신청권자> 재결신청권자는 오직 사업시행자 뿐이다. ② 재결은 협의 불성립 시 관할 토지수용위원회에 하며, 토지보상법상 사업인정고시일로부터 1년 이내에 할 수 있다. 재결신청의무는 반드시 해야 하는 의무는 아니다. 재결신청기간이 경과하면 사업인정의 효력도 상실되므로 재결신청의 근거도 없어진다. 다른 개별법에서 재결신청기간이 특별히 규정되어 있다면 그 기간을 따르면 된다. 사업시행자의 재결신청을 기각하는 재결이 확정되었다 하더라도 재결신청기간의 제한규정에 저촉되지 않는 한 다시 재결신청을 할 수 있고, 토지수용위원회는 이에 근거하여 다시 수용재결을 할 수 있다.

3. 사업시행자에게만 재결신청권을 인정하는 이유

① 토지보상법 구조상 피수용자에게 재결신청권을 인정할 수 없고, ② 피수용자에게 재결신청권 부여 시 공익사업 계획에 지장이 생길 우려가 있으며, ③ 목적물 취득권과 보상 의무는 사업시행자에게 있는 점, ④ 형평차원에서 피수용자에게 재결신청청구권(토지보상법 제30조)이 인정되는 점 등을 고려할 때, 사업시행자에게만 재결신청권을 인정함이 타당하다.

III. 피수용자의 재결신청청구권(토지보상법 30조)

1. 의의

①재결신청청구권은 사업인정 후 협의가 성립되지 않을 경우 피수용자가 사업시행자에게 서면으로 재결신청을 조속히 할 것을 청구하는 권리이다. ②수용의 법률관계의 조속한 확정을 통한 피수용자의 권익보호와 수용당사자간 공평의 원칙에 그 취지가 있다. ③재결 보상금에 부수하여 (구)공익사업법상 인정되는 공법상 청구권의 성질을 지닌다.

2. 요건 및 절차

사업인정 후 협의 불성립 시, 협의기간 만료일 이후 사업인정고시일부터 1년 이내(재결신청기간 만료일)에 청구하여야 한다. 청구권자는 피수용자로 사업시행자에게 서면으로 청구한다.

3. 청구기간의 예외

①협의 불성립·불능 시, ②사업인정 후 상당 기간이 지나도록 사업시행자의 협의 통지가 없는 경우, ③협의 불성립이 명백한 경우에 협의기간 종료 전이라도 재결신청청구가 가능(판례)하다. 단, 60일 기산점은 당초 협의기간 만료일이다.

<수용재결>

05. 토지보상법 34조 수용재결의 법적성질을 설명하시오. (10점)

목차
I. 의의 및 취지, 근거
II. 형성적 행정행위
1. 학설
2. 판례 및 검토
III. 기속행위
IV. 재량행위
V. 제3자효 행정행위
VI. 기타의 법적성질

I. 의의 및 취지, 근거(토지보상법 34조, 50조)

수용재결은 사업인정고시 후 협의불성립·불능의 경우 사업시행자의 재결신청에 의해 관할 토지수용위원회가 행하는 수용 또는 사용결정의 최종적 판단절차이다(제34조, 제50조). 강제적 권력행사를 통해 공익을 실현하고, 엄격한 절차와 형식을 통해 공익과 사익을 조절하기 위한 제도로서 취지가 있다.

II. 형성적 행정행위

1. 학설

① <국가수용권설> 수용권의 주체는 국가이므로, 수용재결은 국가가 수용권을 행사하여 피수용자의 권리를 박탈하여 사업시행자에게 이전해 주는 행위로 본다. ② <사업시

행자수용권설> 수용권의 주체는 사업시행자이므로, 수용재결은 사업시행자에게 부여된 수용권의 구체적 내용을 확정하고, 사업시행자와 피수용자간의 권리 취득 및 상실을 결정하는 형성적 행정행위라고 한다. 이 견해가 다수설이다.

2. 판례 및 검토

대법원은 수용재결은 일정한 법적 효과를 가져오는 처분으로서 행정행위의 성질을 갖는다고 하였다. 생각건대 사업시행자수용권설의 입장이 타당한 바, 수용재결은 수용권의 구체적 내용을 결정하고 권리취득 및 상실을 결정하는 형성적 행정행위로 봄이 타당하다.

III. 기속행위

사업시행자가 재결신청을 하면 관할 토지수용위원회는 형식적 요건이 미비되지 않는 한 재결을 해야 한다. 토지수용절차의 이분화, 사업인정의 성격 등에 비추어 토지수용위원회는 사업인정 자체를 무의미하게 하는, 즉 사업의 시행이 불가능하게 되는 것과 같은 재결을 행할 수 없는 점에서 재결의 발령 자체는 기속행위로 볼 수 있다.

IV. 재량행위

토지보상법 제50조 제2항 단서에 따르면 손실보상금에 관하여 증액재결을 할 수 있는 바, 위 부분은 재량권이 인정된다.

V. 제3자효 행정행위

수용재결은 사업시행자에게는 재산권 취득의 수익적 효과를 피수용자에게는 재산권 박탈의 침익적 효과를 부여하므로, 제3자효 행정행위이다.

VI. 기타의 법적성질

토지수용위원회가 독립적 판단작용을 하므로, 준사법작용과 유사한 당사자심판의 성격, 시시적 쟁송의 성질을 갖고, 수용권자와 피수용권자를 대신하여 수용재결의 사항을 판단하므로 공법상 대리의 성격도 갖고 있다.

06. 甲은 A시의 관할구역 내 X토지를 소유하고 있다. 국토교통부장관은 A시를 국제관광특구로 발전시킬 목적으로 기업도시개발특별법이 정하는 바에 따라 X토지가 포함된 일단의 토지를 기업도시개발구역으로 지정하고, 개발사업시행자인 乙이 작성한 기업도시개발계획(동법 제24조 제2항에 따른 X토지 그 밖의 수용 대상이 되는 토지의 세부목록 포함. 이하 같다)을 승인·고시하였다. 乙은 협의취득에 관한 제반 절차를 준수하여 X토지에 대한 협의취득을 시도하였으나 甲이 응하지 않았다. 이에 乙은 X토지에 대한 수용재결을 신청하였고 중앙토지수용위원회는 그 신청에 따른 수용재결을 하였다. 甲은 수용재결 취소소송을 제기하면서, 乙이 기업도시개발계획승인 이후에 재정상황이 악화되어 수용재결 당시에 이르러 기업도시개발사업을 수행할 능력을 상실한 상태가 되었음에도 불구하고 수용재결을 한 위법이 있다고 주장한다. 甲의 소송상 청구가 인용될 수 있는 가능성에 관하여 설명하시오. (단, 소송요건은 충족된 것으로 본다.) (10점)

목차
I. 논점의 정리 II. 수용재결의 요건 1. 주체(법49조) 및 형식(34조1항), 절차 2. 내용 1) 재결서 기재내용(50조) 2) 사업인정 요건이 수용재결 내용상 요건인지(판례) III. 판례 IV. 사안해결(청구 인용가능성)

I. 논점의 정리

사업시행자의 사업수행능력이 수용재결의 내용상 요건인지 판례 중심으로 검토하여 소

송상 청구 인용가능성을 검토한다.

II. 수용재결의 요건

1. 주체(법49조) 및 형식(34조1항), 절차

토지등의 수용과 사용에 관한 재결을 하기 위하여 국토교통부에 중앙토지수용위원회를 두고, 특별시·광역시·도·특별자치도(이하 "시·도"라 한다)에 지방토지수용위원회를 둔다. 토지수용위원회는 독립된 합의제 행정청이다. 사업인정 후 협의(법26조) 후 협의불성립 혹은 불능 시 사업시행자의 재결신청(법28조), 열람(31조), 심리(32조) 등 일련의 절차를 거친다.

2. 내용

1) 재결서 기재내용(50조)

토지수용위원회의 재결사항은 <수용사용할 토지의 구역 및 사용방법><손실의 보상><수용사용의 개시일과 기간><그 밖에 이 법 및 다른 법률에서 정한 사항>이다.

2) 사업인정 요건이 수용재결 내용상 요건인지(판례)

판례의 견해에 의할 때 사업의 공익성, 사업시행자의 사업수행의 의사나 능력, 관련 이익 등의 형량내용 등을 판단하여 수용권을 행사하여야 한다.

III. 판례

공용수용은 헌법상의 재산권 보장의 요청상 불가피한 최소한에 그쳐야 한다는 헌법 23조 근본취지에 비추어 볼 때 사업시행자가 사업인정을 받은 후 그 사업이 공용수용을 할 만한 공익성을 상실하거나 사업인정에 관련된 자들의 이익이 현저히 비례의 원칙에 어긋나게 된 경우 또는 사업시행자가 해당 공익사업을 수행할 의사나 능력을 상실하였음에도 여전히 그 사업인정에 기하여 수용권을 행사하는 것은 수용권의 공익 목적에 반하는 수용권의 남용에 해당하여 허용되지 않는다.

IV. 사안해결(청구 인용가능성)

사안에서 사업시행자의 사업수행능력 상실에도 불구하고 수용권을 행사한 것은 수용권 남용에 해당하며, 통설판례인 중대명백설에 따를 때 내용상하자는 중대하나, 일견 명백하지 않으나, 취소사유에 해당한다. 수용재결은 위법하여 청구는 인용가능하다.

07. 토지수용의 효과를 논하시오. (50점) [기출 5회 1]

목차
I. 개설 II. 토지수용의 개관 1. 토지수용의 개념 및 제도적 의의 2. 토지수용의 절차 3. 토지수용효과의 발생시기 III. 수용재결일 기준 1. 피수용자에 대한 토지수용의 효과 1) 손실보상청구권(법40조) 2) 수용목적물의 인도 및 이전의무(43조) 2. 사업시행자에 대한 토지수용의 효과 1) 보상금 지급 또는 공탁의무(법40조) 2) 물상대위권(법47조) 3) 위험부담 이전의 효과(법46조) IV. 수용개시일 기준 1. 피수용자에 대한 토지수용의 효과(환매권; 법91조) 2. 사업시행자에 대한 토지수용의 효과 1) 목적물의 원시취득(법45조) 2) 대행(법44조) 3) 대집행(법89조) V. 토지수용재결에 대한 권리구제 1. 이의신청(법83조) 2. 행정소송(법85조) 1) 취소소송

- 2) 무효확인소송
- 3) 보상금증감청구소송

VI. 결

I. 개설

공용수용의 가장 기본이 되는 효과는 사업시행자가 공익사업에 필요한 목적물을 취득하고, 그 목적물에 대한 권리자인 토지소유자와 관계인은 그 권리를 상실하게 되는 권리 변동이 생기는 것이다. 사업시행자가 목적물을 취득하는 것은 손실보상금을 수용의 개시일까지 권리자에게 지급하거나 공탁하는 것을 조건으로 그 효력이 발생한다.

II. 토지수용의 개관

1. 토지수용의 개념 및 제도적 의의
토지수용이란 공익사업을 위해 특정한 자가 소유하고 있는 토지에 관한 권리를 사업시행자가 강제적으로 취득하고 권리를 소멸시키는 것을 말한다. 수용자와 피수용자 간의 이해관계 조정에 제도적 의의를 갖는다.

2. 토지수용의 절차
토지수용절차는 소정의 절차를 모두 거치는 <보통절차>와 특별한 경우 절차의 일부를 생략하는 <약식절차>로 구분한다. 토지보상법상 토지수용의 보통절차는 사업인정, 조서 작성, 협의, 토지수용위원회의 수용재결로 이루어진다.

3. 토지수용효과의 발생 시기
수용의 절차는 협의의 성립, 재결, 협의성립확인, 화해조서작성으로 완성되며, 토지수용의 효과는 수용재결일 기준 손실보상청구권, 물상대위권, 인도이전의무, 위험부담 이전의 효과가 발생하고, 수용개시일 기준 목적물의 원시취득, 대행대집행, 환매권이 발생한다.

III. 수용재결일 기준

1. 피수용자에 대한 토지수용의 효과
1) 손실보상청구권
공용수용은 공익사업을 위한 재산권의 강제적 취득이고, 피수용자에게는 특별한 희생이

므로 정당한 보상이 주어져야 한다. 토지보상법상 명문의 규정은 없으나, 재결이 행해지면 피수용자는 사업시행자에 대한 손실보상청구권이 발생하고, 수용의 시기에 사업시행자의 손실보상과 함께 피수용자의 목적물의 인도이전이 이루어지면 수용의 효과가 와선된다.

2) 수용목적물의 인도 및 이전의무(43조)

토지소유자 및 관계인과 그 밖에 토지소유자나 관계인에 포함되지 아니하는 자로서 수용하거나 사용할 토지나 그 토지에 있는 물건에 관한 권리를 가진 자는 수용 또는 사용의 개시일까지 그 토지나 물건을 사업시행자에게 인도하거나 이전하여야 한다.

2. 사업시행자에 대한 토지수용의 효과

1) 보상금 지급 또는 공탁의무(법40조)

사업시행자는 제38조 또는 제39조에 따른 사용의 경우를 제외하고는 수용 또는 사용의 개시일까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급하여야 한다. 다만, 토지보상법 40조2항의 공탁사유에 해당하는 때에는 수용 또는 사용의 개시일까지 보상금을 공탁할 수 있다.

2) 물상대위권(법47조)

담보물권의 목적물이 수용되거나 사용된 경우 그 담보물권은 그 목적물의 수용 또는 사용으로 인하여 채무자가 받을 보상금에 대하여 행사할 수 있다. 다만, 그 보상금이 채무자에게 지급되기 전에 압류하여야 한다.

3) 위험부담 이전의 효과(법46조)

토지수용위원회의 재결이 있는 후 수용하거나 사용할 토지나 물건이 토지소유자 또는 관계인의 고의나 과실 없이 멸실되거나 훼손된 경우 그로 인한 손실은 사업시행자가 부담한다.

IV. 수용개시일 기준

1. 피수용자에 대한 토지수용의 효과(환매권; 법91조)

토지보상법상 환매권이란 공익사업을 위해 취득된 토지가 해당 사업에 필요 없게 되거나 일정기간 동안 해당 사업에 이용되지 않는 경우에 원 소유자가 일정한 요건하에 해당 토지의 소유권을 회복할 수 있는 권리를 말한다. 이는 재산권 존속보장 및 토지소유자의 소유권에 대한 감정준중을 도모하고 공평의 원칙에 취지가 인정된다.

2. 사업시행자에 대한 토지수용의 효과

1) 목적물의 원시취득(법45조)

① 사업시행자는 수용의 개시일에 토지나 물건의 소유권을 취득하며, 그 토지나 물건에 관한 다른 권리는 이와 동시에 소멸한다. ② 사업시행자는 사용의 개시일에 토지나 물건의 사용권을 취득하며, 그 토지나 물건에 관한 다른 권리는 사용 기간 중에는 행사하지 못한다. ③ 토지수용위원회의 재결로 인정된 권리는 제1항 및 제2항에도 불구하고 소멸되거나 그 행사가 정지되지 아니한다.

2) 대행(법44조)

특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장은 토지나 물건을 인도하거나 이전하여야 할 자가 고의나 과실 없이 그 의무를 이행할 수 없을 때나, 사업시행자가 과실 없이 토지나 물건을 인도하거나 이전하여야 할 의무가 있는 자를 알 수 없을 때에는 사업시행자의 청구에 의하여 토지나 물건의 인도 또는 이전을 대행하여야 한다.

3) 대집행(법89조)

이 법 또는 이 법에 따른 처분으로 인한 의무를 이행하여야 할 자가 그 정하여진 기간 이내에 의무를 이행하지 아니하거나 완료하기 어려운 경우 또는 그로 하여금 그 의무를 이행하게 하는 것이 현저히 공익을 해친다고 인정되는 사유가 있는 경우에는 사업시행자는 시·도지사나 시장·군수 또는 구청장에게 「행정대집행법」에서 정하는 바에 따라 대집행을 신청할 수 있다. 이 경우 신청을 받은 시·도지사나 시장·군수 또는 구청장은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

V. 토지수용재결에 대한 권리구제

1. 이의신청(법83조)

중앙토지수용위원회의 제34조에 따른 재결에 이의가 있는 자는 중앙토지수용위원회에 이의를 신청할 수 있다. 지방토지수용위원회의 제34조에 따른 재결에 이의가 있는 자는 해당 지방토지수용위원회를 거쳐 중앙토지수용위원회에 이의를 신청할 수 있다. 이의의 신청은 재결서의 정본을 받은 날부터 30일 이내에 하여야 한다.

2. 행정소송(법85조)

1) 취소소송

2) 무효확인소송

3) 보상금증감청구소송

08. 토지보상법상 공탁제도에 대해 설명하고, 토지소유자가 이의신청 및 행정소송 제기 후 이의유보 없이 공탁금을 수령한 경우 묵시적 이의유보로 볼 수 있는지 논하시오. (20점)

목차
I. 논점의 정리 II. 토지보상법상 공탁제도(법40조) 1. 의의 및 취지 2. 법적성질 3. 요건(법40조2항) 4. 공탁의 효과 5. 공탁금 수령의 효과 III. 행정쟁송을 묵시적 이의유보로 볼 수 있는지 1. 학설 2. 판례 3. 검토 IV. 사안의 해결

I. 논점의 정리

공탁제도를 설명하고, 행정소송 제기 후 이의유보 없이 수령한 경우 행정소송을 묵시적 이의유보로 볼 수 있는지 판례를 중심으로 검토한다.

II. 토지보상법상 공탁제도(법40조)

1. 의의 및 취지

보상금의 공탁이란 일정한 사유가 있을 때 사업시행자가 보상금을 공탁함으로써 보상금 지급에 갈음하는 제도이다. 사전보상원칙의 관철 및 재결실효방지에 취지가 있다.

2. 법적성질

견해대립 있으나 근본 목적은 채무 이행으로 변제공탁으로 볼 수 있을 것이다. 다만, 사업시행자가 재결에 불복하여 보상금 차액을 공탁한 경우 일종의 담보공탁이라고 할 수 있다.

3. 요건(법40조2항)

①보상금 받을 자가 그 수령을 거부하거나 보상금을 수령할 수 없을 때 ②사업시행자의 과실 없이 보상금을 받을 자를 알 수 없을 때 ③관할 토지수용위원회가 재결한 보상금에 대하여 사업시행자가 불복할 때 ④압류나 가압류에 의하여 보상금의 지급이 금지되었을 때 사업시행자는 수용 또는 사용의 개시일까지 수용하거나 사용하려는 토지등의 소재지의 공탁소에 보상금을 공탁(供託)할 수 있다.

4. 공탁의 효과

①적법한 공탁은 사업시행자의 보상금지급의무가 소멸되고, 목적물 원시취득 등 공용수용의 효과가 발생한다. ②미공탁은 수용의 개시일까지 손실보상의무를 행하지 아니한 것으로 되어 재결은 실효된다(42조). 단, 이의재결에 의해 증액된 보상금은 공탁하지 않아도 이의재결은 실효되지 않는다. ③하자있는 공탁은 공탁요건에 해당하지 아니하는 공탁, 보상금 일부의 공탁, 조건부 공탁 등이 있는데, <법40조 2항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않은 경우> 보상금 지급 효력이 발생하지 않는다. <보상금 일부 공탁>은 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고 보상금 지급 효력 발생하지 않는다. <조건부 공탁>은 토지소유자 등이 그 조건을 수락하지 않는 한 공탁 전체가 무효로 된다. 수용개시일까지 공탁의 하자 미치유 시 수용재결은 실효된다(42조). ④공탁 하자의 치유는 보상금 일부 공탁이나 조건부 공탁은 무효가 되지만 그 공탁금을 토지소유자 또는 관계인 등 채권자가 수령하면 채권자가 일부 공탁이나 조건을 수락한 것이 되어 그 공탁은 공탁일에 소급하여 유효한 것으로 된다. 따라서 사업시행자가 조건을 붙여 공탁한 보상금이라도 이의 유보 없이 이를 수령하면 그 공탁은 유효하다(81누254).

5. 공탁금 수령의 효과

①적법한 공탁의 경우 판례는 이의유보 없이 공탁금 수령 시 재결에 승복한 것으로 보고 그 재결에 대한 이의는 부적법한 것으로 본다. 한편, 공탁금을 수령하면서 이의를 유보한 경우 수용사용개시일이 도과하더라도 수용법률관계는 종결되지 않는다. 판례는 이 경우에만 이의신청이 유효하다 본다. ②하자있는 공탁은 이의유보 없이 수령 시 보상금

수령거부 의사 철회로 하자치유 인정되어 공탁의 효력은 유효하게 된다. 이의유보 후 수령 시 하자치유 인정되지 않아 공탁의 효력은 발생하지 못한다. 이 경우 토지소유자 또는 관계인이 토지수용위원회의 재결에 승복하지 않은 것이 된다. 판례는 묵시적 이의 유보도 가능하다고 본다.

Ⅲ. 행정쟁송을 묵시적 이의유보로 볼 수 있는지

1. 학설

토지소유자가 쟁송제기 등 공탁취지의 승인과 양립할 수 없는 태도를 취하고 있다는 점에서 묵시적 이의유보로 보자는 견해 <긍정설>과 행정쟁송과 이의유보는 별개의 것이라는 <부정설>이 있다.

2. 판례

<중전 판례>행정소송이 계속 중이라는 사실만으로 묵시적 이의유보로 볼 수 없다[90누 6125]고 하였으나 <최근 판례>는 개별적 사실관계를 종합 고려하여 묵시적 이의유보로 본 바 있다.

3. 검토

재결된 보상금의 공탁을 변제공탁으로 보는 한 공탁금의 수령을 재결에 대한 승복으로 보아야 할 것이다. 그러나 공탁에 하자가 있는 경우 토지소유자 등은 이의신청이나 행정소송의 제기 자체를 이의의 유보를 한 것으로 볼 수 있으므로, 피수용자의 권리보호를 위하여 공탁금 수령 시 불복여부에 관한 사항을 확인하는 절차를 마련하여 불이익을 방지할 필요가 있다.

Ⅳ. 사안의 해결

토지소유자 등이 이의신청이나 행정소송의 제기한 것은 묵시적 이의의 유보로 보아 재결에 승복하지 않은 것으로 하는 것이 피수용자의 권리보호 측면에서 타당하다.

09. A시는 시가지 철도시설사업을 시행하기 위하여 토지보상법 제16조에 따라 주택용지를 협의취득하면서 그에 따른 일체의 보상금을 B에게 지급하였고, B는 해당 주택을 자진철거하겠다고 약정하였다. 토지보상법89조 및 행정대집행법2조의 대집행 요건을 설명하고, B가 자진철거를 하지 않을 경우 B의 주택에 대하여 대집행을 할 수 있는지 판단하시오. (20점)
[기출22회 3 변형]

목차
I. 논점의 정리 II. 토지보상법 89조 및 대집행법 2조의 대집행 요건 1. 토지보상법 89조 요건 2. 행정대집행법 2조 요건 3. 양 법의 관계 III. 공법상 의무 불이행 요건 충족 여부 1. 사업인정 전 협의취득의 법적성질 1) 학설 2) 판례 및 검토 2. 사안의 경우 IV. 이 법 또는 이 법에 따른 처분으로 인한 의무 불이행인지 V. 사안의 해결

I. 논점의 정리

B의 자진철거의무 불이행에 대한 대집행 가능성과 관련하여, 토지보상법 89조 및 행정대집행법 2조의 대집행 요건 충족여부가 문제된다.

II. 토지보상법 89조 및 대집행법 2조의 대집행 요건

1. 토지보상법 89조 요건

이 법 또는 이 법에 따른 처분으로 인한 의무를 이행하여야 할 자가 정해진 기간 내 의무를 이행하지 않거나 완료하기 어려운 경우 또는 그로 하여금 그 의무를 이행하게 하는 것이 현저히 공익을 해친다고 인정되는 사유가 있는 경우 사업시행자는 시장 등에게 행정대집행법이 정하는 바에 따라 대집행을 신청할 수 있다.

2. 행정대집행법 2조 요건

공법상의 대체적 작위의무의 불이행, 다른 수단으로써 그 이행확보가 곤란하고, 불이행 방치가 심히 공익을 해칠 것의 요건을 둔다.

3. 양 법의 관계

토지보상법 제89조는 행정대집행법이 정하는 바에 따른다고 규정하는바, 행정대집행의 요건을 충족하여야 대집행이 가능하다고 본다. 일부 견해는 토지보상법 제89조가 수용 토지나 건물의 인도 의무를 위한 특별 규정으로 보나, 판례는 대체적 작위의무에 해당하지 않는다고 보아 부정한다.

III. 공법상 의무 불이행 요건 충족 여부

1. 사업인정 전 협의취득의 법적성질

1) 학설

사경제 주체로서 행하는 사법상 계약과 같다는 견해, 협의 불성립 시 공용수용 절차가 예정되어 있는 점에서 공법상 계약으로 보는 견해가 있다.

2) 판례 및 검토

판례는 사법상 매매행위에 지나지 않는다고 본다. 생각건대, 공용수용의 보통절차 시작 이전에 이루어진 사법상 계약으로 봄이 타당하다.

2. 사안의 경우

협의취득 및 자진철거 약정은 사법상 계약이므로, 공법상 의무 불이행 요건을 충족하지 않는다. 판례는 협의취득 시 건물고유자가 매매대상 건물에 대한 철거의무를 부담하겠다는 취지의 약정을 하였다고 하더라도 이러한 철거의무는 공법상의 의무가 될 수 없고, 이 경우에도 행정대집행법을 준용하여 대집행을 허용하는 별도의 규정이 없는 한 위와 같은 철거의무는 행정대집행법에 의한 대집행의 대상이 되지 않는다고 보았다.

IV. 이 법 또는 이 법에 따른 처분으로 인한 의무 불이행인지

토지보상법에는 사업인정 전 협의취득에 자진철거의무규정을 두지 않으므로, 위 요건도 충족하지 못한다. 다만, 철거는 타인이 대신할 수 있어 대체적 작위의무로 볼 수 있다.

V. 사안의 해결

공법상 의무 불이행 요건을 충족하지 못하므로, 대집행을 할 수 없다.

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 개별법 기본강의 4회

01. 甲은 2015. 3. 16. 乙로부터 A광역시 B구 소재 도로로 사용되고 있는 토지 200㎡(이하 '이 사건 토지'라 함)를 매수한 후 자신의 명의로 소유권 이전등기를 하였다. 한편, 甲은 A광역시지방법토지수용위원회에 "사업시행자인 B구청장이 도로 개설공사를 시행하면서 사업인정고시가 된 2010. 4. 6. 이후 3년 이상 이 사건 토지를 사용하였다"고 주장하면서 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '토지보상법'이라 함) 제72조제1호를 근거로 이 사건 토지의 수용을 청구하였다. 이에 대해 A광역시지방법토지수용위원회는 "사업인정고시가 된 날부터 1년 이내에 B구청장이 재결신청을 하지 아니하여 사업인정은 그 효력을 상실하였으므로 甲은 토지보상법 제72조제1호를 근거로 이 사건 토지의 수용을 청구할 수 없다"며 甲의 수용청구를 각하하는 재결을 하였다. A광역시지방법토지수용위원회의 각하재결에 대하여 행정소송을 제기하기 전에 강구할 수 있는 甲의 권리구제수단에 관하여 설명하시오. (10점) [기출27회2-1]

목차

I. 논점의 정리

II. 이의신청의 의의 및 취지

III. 이의신청의 법적성질(특별행정심판)

IV. 제기요건 및 효력

I. 논점의 정리

토지보상법 83조의 이의신청제도를 검토한다.

II. 이의신청의 의의 및 취지

이의신청이란 관할 토지수용위원회의 위법·부당한 재결에 불복이 있는 토지소유자 및 사업시행자가 중앙토지수용위원회에 그 취소 또는 변경을 구하는 절차이다. 간편한 절차·방법에 의한 피수용자 권익보호에 취지가 있다. 토지보상법 83조에서 “~할 수 있다”고 규정하여 임의적 절차로 규정하고 있다.

III. 이의신청의 법적성질(특별행정심판)

①강학상 이의신청은 별도의 행정심판을 거칠 수 있으나 특별행정심판으로 볼 경우 행정심판법51조에서 재심판청구를 금지하는바 별도행정심판 제기가 불가능하다는 점에 구별실익이 있다. ②강학상 이의신청이라는 견해가 있으나, 헌법107조3항에서 행정심판의 사법절차 준용을 규정하고 있고, 상급기관인 중앙토지수용위원회에 불복하는 점, 법 85조에서 이의신청 재결에 대해 행정소송을 제기할 수 있다는 점에서 <특별행정심판>으로 보는 것이 타당하다. 판례도 특별행정심판으로 본다. 따라서 토지보상법에 없는 규정은 행정심판법을 따른다.

IV. 제기요건 및 효력

재결에 이의가 있는 자는 재결서의 정본을 받은 날로부터 30일 이내에 문서로써 처분청을 경유하여 중앙토지수용위원회에 이의신청할 수 있다. 이의신청을 받은 중앙토지수용위원회는 재결의 전부 또는 일부를 취소하거나 보상액을 변경할 수 있다. 재결 확정 시 민사소송 법상 확정판결이 있는 것으로 보며, 집행력 있는 판결의 정본과 동일한 효력을 갖는다.

02. A대도시의 시장은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 도시관리계획으로 관할구역 내 oo동 일대 90,000㎡ 토지에 공영주차장과 자동차정류장을 설치하는 도시계획시설사업결정을 한 후 지방공기업법에 따른 A대도시 X지방공사(이하 'X공사'라 함)를 도시계획시설사업의 시행자로 지정하고, X공사가 작성한 실시계획에 대해 실시계획인가를 하고 이를 고시하였다. 이에 따라 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 '토지보상법'이라 함)에 의해 사업인정 및 고시가 이루어졌다. 한편, X공사는 사업대상구역 내에 위치한 20,000㎡ 토지를 소유한 甲과 토지수용을 위한 협의를 진행하였으나 협의가 성립되지 아니하여 관할 지방토지수용위원회에 토지수용의 재결을 신청하였다. 甲은 수용 자체가 위법이라고 주장하면서 관할 지방토지수용위원회의 수용재결과 중앙토지수용위원회의 이의재결을 거친 후 취소소송을 제기하였다. 취소소송의 대상적격과 피고적격에 관하여 설명하시오. (20점) [기출34회1-2]

목차
I. 논점의 정리
II. 관련 행정작용의 법적성질
III. 원처분주의와 재결주의
IV. 토지보상법 85조 1항이 원처분주의를 취하는지
V. 대상적격
VI. 피고적격
1. 피고적격 의의 및 근거
2. 사안의 경우

I. 논점의 정리

이의재결이 특별법상 행정심판의 성질을 가지는지 검토하고, 이를 거친 경우 취소소송의 대상이 무엇인지 관련하여 토지보상법 85조1항이 원처분주의를 취하는지 검토하여 대상적격과 피고적격을 설명한다.

II. 관련 행정작용의 법적성질

①재결은 사업인정고시 후 협의불성립·불능의 경우 사업시행자의 재결신청에 의해 관할 토지수용위원회가 행하는 수용·사용결정의 최종적 판단절차이다(법34,50조). 재결은 처분으로, 형성적 행정행위에 해당하며, 형식적 요건이 미비되지 않는 한 재결을 해야 하는 점에서 기속행위의 성질을 가진다고 볼 수 있다. 판례도 수용재결의 처분성을 인정한다. ①이의재결은 수용재결의 위법, 부당을 이유로 그 시정을 구하는 절차이며, 판례는 특별법상 행정심판의 성격을 가진다고 보았다.

III. 원처분주의와 재결주의

원처분주의란 원처분과 재결을 모두 소송대상으로 하되, 원칙적으로 원처분에 대해서만 소송을 제기할 수 있고, 재결은 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에 한해 소송을 제기할 수 있는 주의를 말하며, 이에 반해 재결주의란 재결에 대해서만 취소소송을 제기할 수 있도록 한 주의를 말한다. 이를 선택하는 것은 입법의 문제이며 행정소송법 19조는 원처분주의를 취한다.

IV. 토지보상법 85조 1항이 원처분주의를 취하는지

토지보상법 85조 1항은 '34조에 따른 재결(수용재결)에 불복할 때'라고 하여 취소소송의 대상을 수용재결로 분명히 하였다. 대법원 또한 원처분주의를 취한다고 보았다.

V. 대상적격

이의재결을 거쳐 취소소송을 제기한 점에서, 이의재결은 기각재결로 보이고, 판례에 따르면 기각재결은 재결에 고유한 위법이 없으므로, 토지보상법 85조 1항에 의거, 원처분인 수용재결이 취소소송의 대상이 된다. 만약, 이의재결에 고유한 위법이 있다면, 이의재결은 취소소송 대상이 될 수 있다.

VI. 피고적격

1. 피고적격 의의 및 근거

피고적격은 구체적인 소송에서 피고로서 소송을 수행하여 본안판결을 받을 수 있는 자격을 의미한다. 행정소송법 13조에 근거를 두고 있다. 이에 따르면, 취소소송은 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다.

2. 판례

법83, 85가 이의신청을 임의절차로 규정한 점, 행정소송법 19조 단서가 행정심판에 대한 재결은 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한하여 취소소송의 대상이라 한 점 종합고려 시 수용재결에 불복하여 취소소송을 제기하는 때에는 이의신청을 거친 경우에도 수용재결을 한 중앙토지수용위원회 또는 지방토지수용위원회를 피고로 하고 이의신청에 대한 재결 자체에 고유한 위법이 있을 때 이의재결을 한 중앙토지수용위원회를 피고로 한다.

3. 사안의 경우

취소소송의 대상인 수용재결을 행한 관할 지방토지수용위원회가 피고적격을 가진다. 만약, 이의재결에 고유한 위법이 있는 경우라면 중앙토지수용위원회가 피고적격을 가질 수 있다.

03. A군에 사는 甲은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따라 지정된 개발제한 구역 내에 과수원을 경영하고 있다. 甲은 영농의 편의를 위해 동 과수원 토지 내에 작은 소로(小路)를 개설하고, 종종 이웃 주민의 통행에도 제공해 왔다. A군은 甲의 과수원 부지가 속한 일단의 토지에 폐기물처리장을 건설하고자 하는 乙을 폐기물관리법에 따라 폐기물처리장 건설사업자로 지정하면서 동 처리장건설사업 실시계획을 승인하였다. 甲과 乙간에 甲 토지에 대한 협의매수가 성립되지 않아 乙은 甲 토지에 대한 수용재결을 신청하고, 관할 지방토지수용위원회의 수용재결을 받았다. 동 수용재결에서는 “사실상 사도(私道)의 부지는 인근 토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내로 평가한다.”고 규정하고 있는 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙(이하 ‘토지보상법 시행규칙’) 제26조 제1항 제2호의 규정에 따라, 甲의 토지를 인근 토지가에 비하여 3분의 1의 가격으로 평가하였다. 이 수용재결에 대하여 이의가 있는 甲은 적절한 권리구제 수단을 강구하고자 한다. 토지보상액에 대해 불복하고자 하는 甲의 행정쟁송상 권리구제수단을 설명하시오. (20점) [기출22회1-1]

목차

I. 논점의 정리

II. 관련 행정작용의 법적성질

III. 토지보상법 83조에 의한 이의신청

1. 이의신청의 의의, 취지
2. 이의신청의 법적성질
3. 개별법상 필요적 전치절차인지
4. 이의신청에 대한 재결의 효력

IV. 보상금증액청구소송

1. 보상금증감청구소송의 의의, 취지 및 근거
2. 법적성질

3. 원처분주의 논의가 적용되는지
4. 피고적격
5. 입증책임
6. 보상항목간 유용 및 심판범위
7. 심리범위

I. 논점의 정리

토지보상법 83조 1항의 이의신청 및 85조 2항의 보상금증액청구소송을 검토한다.

II. 관련 행정작용의 법적성질

A군의 사업실시계획 승인은, 폐기물관리법에 따라 토지보상법상 사업인정으로 의제된다. 乙의 협의 이후 수용재결 신청에 의하여 토지보상법 시행규칙 26조1항2호를 적용할 수용재결이 이루어졌으며, 이는 토지보상법 34조, 59조에 근거한 것으로 공용수용의 종국적인 절차로 형성적 처분이며 원시취득의 효과가 발생한다.

III. 토지보상법 83조에 의한 이의신청

1. 이의신청의 의의, 취지

이의신청은 관할 토지수용위원회의 위법, 부당한 수용재결에 의해 권익을 침해당한 자가 중앙토지수용위원회에 그 취소 또는 변경을 구하는 절차로 토지보상법 83조에 근거를 둔다. 간편한 절차와 방법에 의한 피수용자의 권익보호에 취지가 있다.

2. 이의신청의 법적성질

①쟁송을 제기한 자의 권리이익을 직접 목적으로 하는 주관적 쟁송이다. ②재결처분의 위법 또는 부당을 이유로 그 시정을 구하는 절차로서, 특별행정심판이다. ③토지수용위원회의 재결처분의 위법 또는 부당함을 이유로 그 효력을 다투는 것이므로 복심적 쟁송이다.

3. 개별법상 필요적 전치절차인지

구 토지수용법에서는 이의신청을 필수적 절차로 규정하였으나 토지보상법에서는 임의적 절차로 규정하고 있다.

4. 이의신청에 대한 재결의 효력

이의신청이 제기되면 중앙토지수용위원회는 이의신청에 대하여 심리·재결해야 할 의무를 지며, 위법부당하다고 인정될 경우 보상액을 변경할 수 있다. 한편 이의신청 제기는 사업의 진행 및 토지의 수용 또는 사용을 정지시키지 아니하며(88조), 재결이 확정된 때 민사소송법상의 확정판결이 있는 것으로 본다.

IV. 보상금증액청구소송

1. 보상금증감청구소송의 의의, 취지 및 근거

보상금증감청구소송은 토지보상법 85조에 근거하여 재결에서 결정된 손실보상금의 증감을 구하는 행정소송을 의미한다. 권리구제의 신속성, 일회적 해결 등에 취지가 있다.

2. 법적성질

①판례는 손실보상금의 지급을 구하는 소송을 공권으로 보며, 강제수용이라는 공법적 원인과 효과에 관한 것으로 공권으로 보는 것이 타당하다. ②보상금증감청구소송은 행정청의 처분, 재결 등이 원인이 되어 형성된 법률관계에 다툼이 있는 경우 그 원인이 되는 재결의 효력을 직접 다투지 않고 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하여 제기하는 형식적 당사자 소송에 해당한다. ③보상금과 관련된 권리를 형성한다는 형성소송이라는 견해가 있다. 그러나 실질적으로 보상액을 확인하고 부족액의 지급을 명한다는 점에서 <확인급부소송>으로 봄이 타당하다 판단되며 판례의 태도도 동일하다

3. 원처분주의 논의가 적용되는지

이의재결을 거친 경우 소송의 대상에 대해 견해가 대립하나, 보상금에 관한 법률관계를 그 소송의 대상으로 보아 원처분주의 재결주의로 해석하는 것은 타당하지 않다.

4. 피고적격

토지소유자, 관계인은 법률관계인 직접 상대방인 사업시행자를 피고로 하여야 한다. 보상금감액소송은 그 반대가 된다.

5. 입증책임

민사소송법상 입증책임 분배에 따라 나뉘며, 정당한 손실보상금이 재결금액보다 많다는 점에 대한 입증책임은 원고에게 있다. 단, 불법형질변경토지의 경우 불법형질변경에 대한 입증책임은 피고에게 있다.

6. 보상항목간 유용 및 심판범위

판례는 보상항목간 유용을 허용한다. 정당보상액을 확인하여 재결금액과의 차액에 해당하는 부분만의 취소로 봄이 타당하다.

7. 심리범위

재결신청청구(30조)에 따른 지연가산금도 심리 범위이며, 판례는 잔여지수용청구에 대한 기각도 형성권인 점을 감안하여 보상금증감청구소송으로 다투어야 한다고 본다.

04. 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '공익사업법'이라 한다)에 따라 도로확장건설을 위해 사업인정을 받은 A는 해당 지역에 위치한 甲의 토지를 수용하고자 甲과 협의를 시도하였다. A는 甲과 보상액에 관한 협의가 이루어지지 않자 공익사업법상의 절차에 따라 관할 토지수용위원회에 재결을 신청하였다. 그런데 관할 토지수용위원회는「감정평가에 관한 규칙(국토교통부령)」에 따른 '감정평가 실무기준(국토교통부 고시)'과는 다르게 용도지역별 지가변동률이 아닌 이용상황별 지가변동률을 적용한 감정평가사의 감정결과를 채택하여 보상액을 결정하였다. 그 이유로 해당 토지는 이용상황이 지가변동률에 더 큰 영향을 미친다는 것을 들었다. 다음 물음에 답하시오. (40점) [기출26회1]

1) 甲은 보상액 결정이 '감정평가 실무기준(국토교통부 고시)'을 따르지 않았으므로 위법이라고 주장한다. 甲의 주장은 타당한가? (20점)

2) 甲은 위 토지수용위원회의 재결에 불복하여 공익사업법에 따라 보상금의 증액을 구하는 소송을 제기하고자 한다. 이 소송의 의의와 그 특수성을 설명하시오. (20점)

목차
<물음1> I. 논점의 정리 II. 감정평가 실무기준의 법적성질 1. 학설 2. 판례 3. 검토 III. 보상액 결정의 위법성 검토 1. 법규명령에 따르지 않은 처분의 위법성 2. 이용상황별 지가변동률이 적용 가능한 경우

3. 관련 판례

IV. 사안의 경우

<물음2>

I. 논점의 정리

II. 보상금증액청구소송의 의의, 법적근거, 취지

III. 보상금증액청구소송의 특수성

1. 형식적 당사자소송
2. 확인급부소송
3. 원처분주의 논의가 적용되는지
4. 제소기간의 특칙
5. 심리범위

<물음1>

I. 논점의 정리

감정평가실무기준은. 법령보충적 행정규칙으로, 법적성질과 이에 위반한 보상액 결정의 위법여부를 검토한다.

II. 감정평가 실무기준의 법적성질

1. 학설

형식에 따라 행정규칙이라는 견해, 규범구체화 영역의 경우 행정청에게 시원적 입법권을 인정하여 구속력을 인정하는 견해, 상위법과 결합하여 법규명령의 효력을 가진다는 견해, 실질에 따라 법규명령이라는 견해, 수권여부에 따라 개별적으로 판단하는 견해가 대립한다.

2. 판례

대법원 위와 같은 행정입법의 경우 상위 법률과 결합하여 법규명령의 효력을 가진다고 판시하며, 감정평가 실무기준의 경우 규율 내용에 있어 감정평가의 구체적 기준을 정하

고 있고, 수범자에 있어 감정평가법인등을 대상으로 하며, 목적에 있어 감정평가의 공정성과 신뢰성을 추구한다고 하여 대외적 구속력을 부정한다.

3. 검토

감정평가 실무기준은 그 형식은 국토교통부 고시이지만 부동산공시법3조 3항 및 감정평가에 관한 규칙 28조와 결합하여 대외적 구속력을 가진다고 봄이 타당하다.

III. 보상액 결정의 위법성 검토

1. 법규명령에 따르지 않은 처분의 위법성

행정청의 행정작용은 행정의 법률적합성 원칙에 의해 법규명령에 위반하는 경우 위법하다. 이는 행정작용의 내용상 하자에 해당하며 하자의 정도는 중대·명백설에 의해 판단하게 된다.

2. 이용상황별 지가변동률이 적용 가능한 경우

감정평가 실무기준에 따르면 원칙적으로 지가변동률은 용도지역을 기준으로 하되, 용도지역별 지가변동률이 조사발표되지 아니한 경우, 비교표준지가 도시지역의 개발제한구역 안에 있는 경우로서 녹지지역의 지가변동률이 조사발표되지 아니한 경우, 97.01.01. 이전을 공시기준일로 하는 표준지가 개발제한구역 안에 있는 경우에는 예외적으로 이용상황별 지가변동률을 적용할 수 있다.

3. 관련 판례

판례는 감정평가 실무기준의 법규성을 부정하여 이용상황별 지가변동률을 적용한 감정결과를 채택하였다.

IV. 사안의 경우

감정평가 실무기준은 대외적 구속력이 인정되므로 관할 토지수용위원회는 이에 따라서 지가변동률을 적용하여야 한다. 이용상황이 지가변동률에 더큰 영향을 미친다는 사유는 감정평가 실무기준의 이용상황별 지가변동률을 적용할 수 있는 경우에 해당하지 않아 관할 토지수용위원회의 이용상황별 지가변동률 적용은 위법하다. 따라서 甲의 주장은 타당하다.

<물음2>

I. 논점의 정리

토지보상법85조2항 보상금증액청구소송을 검토한다.

II. 보상금증액청구소송의 의의, 법적근거, 취지

보상금증액청구소송은 토지보상법 85조에 근거하여 재결에서 결정된 손실보상금의 증감을 구하는 행정소송을 의미한다. 권리구제의 신속성, 일회적 해결 등에 취지가 있다.

III. 보상금증액청구소송의 특수성

1. 형식적 당사자소송

보상금증액청구소송은 행정청의 처분, 재결 등이 원인이 되어 형성된 법률관계에 다툼이 있는 경우 그 원인이 되는 재결의 효력을 직접 다투지 않고 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하여 제기하는 형식적 당사자 소송에 해당한다.

2. 확인급부소송

보상금과 관련된 권리를 형성한다는 형성소송이라는 견해가 있으나 실질적으로 보상액을 확인하고 부족액의 지급을 명한다는 점에서 <확인급부소송>으로 봄이 타당하다 판단되며 판례의 태도도 동일하다.

3. 원처분주의 논의가 적용되는지

이의재결을 거친 경우 소송의 대상에 대해 견해가 대립하나, 보상금에 관한 법률관계를 그 소송의 대상으로 보아 원처분주의 재결주의로 해석하는 것은 타당하지 않다.

4. 제소기간의 특칙

당사자소송은 공법상 권리의무의 존속기간 내에서 소송을 제기할 수 있는 것이 원칙이다. 다만 토지보상법 85조2항 및 1항에서 34조 및 83조의 재결의 경우 재결서 정본을 송달받은 날부터 각각 60일, 30일 제소기간의 특칙을 규정하고 있다. 대법원은 토지수용위원회에서 재결이 있었다는 사실을 알리지 않는 경우 행정소송법 및 행정심판법의 일반규정이 적용된다고 한다.

5. 심리범위

①손실보상금의 지급방법 ②적정손실보상액의 범위 및 보상관련 보상면적 ③지연손해금 ④잔여지수용 여부 ⑤개인별 보상으로서 과대·과소항목간 유용 등 심리한다.

05. 甲은 2015. 3. 16. 乙로부터 A광역시 B구 소재 도로로 사용되고 있는 토지 200㎡(이하 '이 사건 토지'라 함)를 매수한 후 자신의 명의로 소유권 이전등기를 하였다. 한편, 甲은 A광역시지방법토지수용위원회에 "사업시행자인 B구청장이 도로 개설공사를 시행하면서 사업인정고시가 된 2010. 4. 6. 이후 3년 이상 이 사건 토지를 사용하였다"고 주장하면서 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '토지보상법'이라 함) 제72조제1호를 근거로 이 사건 토지의 수용을 청구하였다. 이에 대해 A광역시지방법토지수용위원회는 "사업인정고시가 된 날부터 1년 이내에 B구청장이 재결신청을 하지 아니하여 사업인정은 그 효력을 상실하였으므로 甲은 토지수용법 제72조제1호를 근거로 이 사건 토지의 수용을 청구할 수 없다"며 甲의 수용청구를 각하하는 재결을 하였다. 甲이 A광역시지방법토지수용위원회의 각하재결에 대하여 행정소송을 제기하려 한다. ①확장수용의 법적성질을 설명하고 ②甲이 제기하기 적합한 소송의 형태와 피고적격을 관하여 설명하시오. (20점) [기출27회2-2 변형]

목차

I. 논점의 정리

II. 확장수용의 법적성질

1. 확장수용과 완전수용
2. 확장수용의 법적성질
3. 검토

III. 소송의 형태

1. 학설
2. 판례
3. 검토

IV. 피고적격

I. 논점의 정리

확장수용의 법적성질과 이와 관련한 소송의 형태 및 피고적격을 검토한다.

II. 확장수용의 법적성질

1. 확장수용과 완전수용

확장수용은 공익사업을 위한 목적물의 필요최소한의 범위를 넘어 수용하는 것이다. 피수용자 권리구제 등을 위해 법률의 규정이 있을 때 예외적으로 인정되는 제도이다. 완전수용은 토지사용으로 인해 토지소유자가 받게 되는 손실에 갈음하여 수용을 가능하게 해주는 확장수용의 한 예이다.

2. 확장수용의 법적성질

확장수용 청구를 사법상 매매의 청약으로 보는 견해가 있으나, 피수용자의 청구를 요건으로 하는 일방적 권리취득이므로 그 본질이 공용수용과 같다고 보는 견해가 타당하다. 판례도 확장수용에 대한 다툼을 행정소송에 의하여야 한다고 본다.

III. 소송의 형태

1. 학설

취소소송설은 확장수용은 보상범위에 관련되는 문제라고 보며, 보상금증감청구소송설은 보상금액과 보상범위는 밀접한 관련이 있고, 피수용자의 일회적 권리구제를 근거로 한다.

2. 판례

판례는 수용청구권은 토지보상법 74조 1항이 정한 잔여지 수용청구권과 같이 손실보상의 일환으로 토지소유자에게 부여되는 권리로서 그 청구에 의하여 수용효과가 생기는 형성권의 성질을 지니므로, 토지소유자의 토지수용청구를 받아들이지 아니한 재결에 대하여 불복하여 제기하는 소송은 토지보상법 85조2항에 규정되어 있는 보상금의 증감에 관한 소송에 해당한다고 보았다.

3. 검토

분쟁의 일회적 해결이라는 보상금증감청구소송의 취지를 고려할 때, 판례 입장이 타당하다.

IV. 피고적격

피고적격은 소송에서 피고가 될 자격이 있는자를 말하며 행정소송법 13조에 근거를 둔다.

수용재결을 행한 처분청은 토지수용위원회이지만, 토지보상법 85조 2항에서는 소송을 제기하는 자가 토지소유자 등일 때에는 사업시행자를 피고로 한다고 하여, 피고적격에 대해 특별히 규정하고 있다. 따라서 사안에서는 사업시행자인 B구청장에게 피고적격이 있다.

<보상금증감청구소송 기출문제 모음>

☆甲은 골프장을 보유·운영해왔는데, 그 전체 부지 1,000,000㎡ 중 100,000㎡가 도로건설 사업부지로 편입되었고, 골프장은 계속 운영되고 있다. 위 사업부지로 편입된 부지 위에는 오수처리시설이 있었는데, 수용재결에서는 그 이전에 필요한 비용으로 1억 원의 보상금을 산정하였다.甲은 골프장 잔여시설의 지가 및 건물가격 하락분에 대하여 보상을 청구하려고 한다. 이때 甲이 제기할 수 있는 소송에 관하여 설명하시오. (20점)[기출30회 2-2]

☆A시 시장 甲은 1990년에 자연공원법 에 의하여 A 시내 산지 일대 5 km²를 'X시립공원'으로 지정·고시한 다음, 1992년에 X시립공원 구역을 구분하여 용도지구를 지정하는 내용의 'X시립공원 기본계획'을 결정·공고하였다.甲은 2017년에 X시립공원 구역 내 10,000㎡ 부분에 다목적광장 및 휴양관(이하 '이 사건 시설'이라 한다)을 설치하는 내용의 'X시립공원 공원계획'을 결정·고시한 다음, 2018년에 甲이 사업시행자가 되어 이 사건 시설에 잔디광장, 휴양관, 도로, 주차장을 설치하는 내용의 'X시립공원 공원사업'(이하 '이 사건 시설 조성사업'이라 한다) 시행계획을 결정·고시하였다. 甲은 이 사건 시설 조성사업의 시행을 위하여 그 사업구역 내에 위치한 토지(이하 '이 사건 B토지'라 한다)를 소유한 乙과 손실보상에 관한 협의를 진행하였으나 협의가 성립하지 않자 수용재결을 신청하였다. 관할 지방토지수용위원회의 수용재결 및 중앙토지수용위원회의 이의재결에서 모두 이 사건 B토지의 손실보상금은 1990년의 X시립공원 지정 및 1992년의 X시립공원 용도지구 지정에 따른 계획제한을 받는 상태대로 감정평가한 금액을 기초로 산정되었다. 乙은 위 중앙토지수용위원회의 이의재결이 감정평가에 관한 법리를 오해함으로써 잘못된 내용의 재결을 한 경우에 해당한다고 판단하고 있다. 乙이 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따라 제기할 수 있는 소송의 의의와 그 특수성을 설명하시오. (15점)[기출31회1-1]

☆A대도시의 시장은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 도시관리계획으로 관할구역 내 〇〇동 일대 90,000㎡ 토지에 공영주차장과 자동차정류장을 설치하는 도시계획시설사업결정을 한 후 지방공기업법에 따른 A대도시 X지방공사(이하 'X공사'라 함)를 도시계획시설사업의 시행자로 지정하고, X공사가 작성한 실시계획에 대해 실시계획인가를 하고 이를 고시하였다. 이에 따라 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 '토지보상법'이라 함)에 의해 사업인정 및 고시가 이루어졌다. 한편, X공사는 사업대상구역 내에 위치한 20,000㎡ 토지를 소유한 甲과 토지수용을 위한 협의를 진행하였으나 협의가 성립되지 아니하여 관할 지방토지수용위원회에 토지수용의 재결을 신청하였다. 甲은 자신의 토지에 대한 보상금이 적으며, 일부 지장물이 손실보상 대상에서 제외되었다는 이유로 관할 지방토지수용위원회의 수용재결에 불복하여 중앙토지수용위원회에 이의신청을 거쳤으나 기각재결을 받았다. 甲이 이에 대하여 불복하는 경우 적합한 소송 형태를 쓰고 이에 관하여 설명하시오. (10점)[기출34회1-3]

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 개별법 기본강의 5회

01. 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상 환매권의 목적물과 그 행사요건을 설명하시오. (20점) [기출13회 2]

목차
I. 의의 및 근거(토지보상법 91조) II. 법적성질 1. 형성권 2. 공권 3. 채권적 효력설 III. 환매 목적물 등 IV. 환매권 행사요건 1. 개요 2. 토지보상법 91조1항 요건 3. 토지보상법 91조2항 요건 4. 91조 1항과 2항의 관계

I. 의의 및 근거(토지보상법 91조)

토지보상법상 환매권이란 공익사업에 필요하여 취득한 토지가 필요없게 되거나 이용되지 않는 경우에 원래의 토지 소유자가 일정한 요건 하에 원래의 토지를 취득할 수 있는 권리이다. 피수용자의 감정 존중과 재산권 존속보장에 그 취지가 있다. ①이론적 근거는 피수용자의 감정 존중, 재산권 존속보장 등을 들 수 있다. 대법원은 환매권을 공평의 원칙상 인정되는 권리로 보면서도 헌법상 재산권의 범주에 속한다고 한다. ②법적 근거는 헌법23조3항 및 토지보상법91조를 들 수 있다.

II. 법적성질

1. 형성권

형성권이란 요건충족 시 일방적 의사표시로 형성적 효력이 발생하는 권리를 말하며 청구권과 달리 상대방이 동시이행 항변권을 주장하지 못하는 권리이다. 대법원은 환매권은 일종의 형성권으로서 재판상이든 재판외이든 그 기간 내에 행사하면 이로써 매매의 효력이 발생한다고 한다고 하여 일관되게 형성권으로 보고 있다.

2. 공권

①사업인정 전 협의취득의 경우는 사법상 권리로 보는 데 문제가 없으나, 사업인정 후 취득의 경우는 공권설과 사권설이 대립되고 있다. 쟁송의 형태, 적용법률 등에 논의의 실익이 있다. ②대법원과 헌법재판소는 환매권의 법적 성질을 사법상 권리로 보고, 사업시행자의 환매권 행사를 거부하는 의사표시는 공권력의 행사가 아니라고 판시한 바 있다. ③이론상으로 볼 때 사업시행자라는 공권력 주체에 대해 사인이 가지는 공법으로서 토지보상법 권리이므로 <공권>으로 봄이 타당하다.

3. 채권적 효력설

토지를 환매할 수 있단 의미에 대해 견해대립 있으나 소유권은 환매권자의 의사표시에 의해 소유권 이전이라는 물권적 효력을 발생한다고 보기 어려운바 소유권이전 등기 청구권이라는 채권적 효력이 발생한다는 <채권적 효력설>이 타당하다. 판례도 같은 입장이며 이때 소송은 소유권이전등기청구소송 형태 취한다.

III. 환매 목적물

①환매권자는 취득일 당시의 토지소유자 또는 그 포괄승계인이다. ②상대방은 사업시행자 또는 (토지가 제3자에게 매각됐을 경우) 제3자인 현재의 소유자이다. ③환매목적물은 토지소유권에 한하며, 환매 요건에 해당하는 토지가 있을 경우 그 요건에 해당하는 토지 전부에 대하여 환매권을 행사하여야 하며 그 중 일부만 선택적으로 행사할 수 없다. 잔여지를 수용한 경우 그 잔여지에 대해 잔여지에 접한 일단의 토지가 필요 없게 된 경우만 가능하지 원래의 수용토지를 제외하고 잔여지만 환매할 수는 없다. ④환매금액은 환매권자가 지급받은 보상금 상당액이다.

IV. 환매권 행사요건

1. 개요

환매권은 취득의 완성과 동시에 법률상 당연히 성립한바 그 성립시기는 수용의 개시일이며 법91조1항2항은 <행사요건>으로 보는 견해가 타당하다 판단된다.

2. 토지보상법 91조1항 요건

①공익사업의 폐지·변경·그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 때, 환매권자는, 공익사업의 폐지·변경의 경우 사업의 폐지·변경 고시가 있는 날부터 10년 내에, 그 밖의 사유의 경우 사업완료일부터 10년 이내에 그 토지에 대하여 받은 보상금 상당액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다. ②<해당사업>이란 토지 취득 목적이 된 구체적인 특정 공익사업을 의미한다. <사업의 폐지변경>이란 해당 사업을 폐지하는 것뿐 아니라 다른 사업으로 전환하는 것도 포함한다. <그 밖의 사유>란 관계법에 의하여 사업의 폐지변경 또는 그에 갈음하는 행위로 더 이상 목적사업에 제공할 필요가 없게 된 객관적 사유를 뜻한다. <필요없게 되었는지>는 사업자의 주관적 의사를 표준으로 할 것이 아니라, 당해 사업의 목적과 내용, 협의취득의 경위와 범위, 당해 토지와 사업의 관계, 용도 등 제반사정에 비추어 객관적·합리적으로 판단한다.

3. 토지보상법 91조2항 요건

①취득일부터 5년 이내에 취득한 토지의 전부를 해당 사업에 이용하지 아니하였을 때 취득일부터 6년 이내 환매권을 행사하여야 한다. ②특정 환매권자의 해당 필지를 기준으로 판단해서는 안되고, 사업시행자가 취득한 토지 전부를 기준해야 한다. ③사업에 이용할 필요가 없게 된 것이 아니라, 단지 사실상 사업에 제공되지 않은 경우를 말한다.

4. 91조 1항과 2항의 관계

서로 독립적으로 성립한다. 따라서 어느 한쪽의 요건에 해당된다고 하더라도 다른 쪽의 요건을 주장할 수 있고, 제2항의 규정에 의한 제척기간이 도과하였어도, 제1항의 규정에 의한 환매권 행사가 가능하다.

<환매권-공익사업 변환>

02. 서울특별시장은 도시관리계획결정에서 정해진 바에 따라 근린공원을 조성하기 위하여 그 사업에 필요한 토지들을 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률의 규정에 의거하여 협의를 거쳐 취득하고자 하였으나 협의가 성립되지 않아 중앙토지수용위원회에 재결을 신청하였다. 중앙토지수용위원회의 **수용재결(수용의 개시일 : 2005. 6. 30.)**에 따라 서울특별시는 보상금을 지급하고 필요한 토지에 대한 **소유권이전등기를 마쳤다**. 서울특별시장은 토지를 취득한 후, 6개월 간의 공사 끝에 공원을 조성하였다. **공원조성공사가 완료된 후 2년이 지난 뒤**에 위 토지를 포함한 그 일대의 토지들이 **택지개발예정지구로 지정되었다(고시일 : 2008. 6. 30.)** 국토교통부장관에 의하여 택지개발사업의 **시행자로** 지정된 **대한주택공사**는 **택지개발사업실시계획의 승인**을 얻어 공원시설을 철거하고, 그 지상에 **임대주택을 건설하는 공사**를 시행하고 있다. 이에 공원조성사업을 위해 수용된 토지의 소유자 **甲**은 **2008. 8. 30. 서울특별시에 환매의 의사표시**를 하였으나, 서울특별시는 **甲**에게 환매권이 없다고 하여 수용된 토지를 되돌려 주지 않았다.

①환매권의 법적성질(5점)을 논하고, ②甲이 환매권 행사요건을 충족여부(15점) 및 ③환매권 행사 제한 사유 해당여부(15점)를 설명하여 ④甲이 소유권 회복을 위해 제기할 수 있는 소송수단 및 그 인용가능성(5점)에 대하여 검토하시오. (40점) [기출19회 1변형]

목차

I. 논점의 정리

II. 환매권의 법적성질

1. 환매권의 의의 및 근거
2. 환매권의 법적성질
 - 1) 공권
 - 2) 형성권
 - 3) 채권적 효력

III. 甲이 환매권 행사요건을 충족 여부

1. 법91조1항 요건
2. 법91조2항 요건
3. 91조 1항과 2항의 관계
4. 사안의 경우

IV. 환매권 행사제한 여부(공익사업 변환)

1. 공익사업변환의 의의, 근거, 취지
2. 공익사업변환 요건
3. 사업시행자 변경 시 변환규정의 적용여부
 - 1) 학설
 - 2) 판례
 - 3) 검토
4. 사안의 경우

V. 甲의 소송수단 및 그 인용가능성

1. 소송수단 및 환매방법
2. 대항력(토지보상법91조5항)
3. 소유권이전등기청구소송(민사소송)과 인용가능성

I. 논점의 정리

환매권의 법적성질, 토지보상법 91조가 환매권 행사요건인지, 환매권 행사요건 충족 여부, 공익사업 변환요건, 소송수단 및 인용가능성을 검토한다.

II. 환매권의 법적성질

1. 환매권의 의의 및 근거

토지보상법상 환매권이란 공익사업에 필요하여 취득한 토지가 필요없게 되거나 이용되지 않는 경우에 원래의 토지 소유자가 일정한 요건 하에 원래의 토지를 취득할 수 있는 권리이다. 피수용자의 감정 존중과 재산권 존속보장에 그 취지가 있다. ①이론적 근거는 피수용자의 감정 존중, 재산권 존속보장 등을 들 수 있다. 대법원은 환매권을 공평의 원

척상 인정되는 권리로 보면서도 헌법상 재산권의 범주에 속한다고 한다. ②법적 근거는 헌법23조3항 및 토지보상법91조를 들 수 있다.

2. 환매권의 법적성질

1) 공권

사용해제 요구권으로 보는 공권설, 개인의 이익을 위한 사권설 견해대립이 있으나, 대법원은 사권으로 보며, 환매금액 증감에 관한 소송을 민사소송으로 판시한 바 있다. 생각건대 환매권은 개인의 이익을 위한 것으로 사권설이 타당하다.

2) 형성권

형성권이란 요건충족 시 일방적 의사표시로 형성적 효력이 발생하는 권리를 말하며 청구권과 달리 상대방이 동시이행 항변권을 주장하지 못하는 권리이다. 대법원은 환매권은 일종의 형성권으로서 재판상이든 재판외이든 그 기간 내에 행사하면 이로써 매매의 효력이 발생한다고 한다고 하여 일관되게 형성권으로 보고 있다.

3) 채권적 효력

토지를 환매할 수 있던 의미에 대해 견해대립 있으나 소유권은 환매권자의 의사표시에 의해 소유권 이전이라는 물권적 효력을 발생한다고 보기 어려운바 소유권이전 등기 청구권이라는 채권적 효력이 발생한다는 <채권적 효력설>이 타당하다. 판례도 같은 입장이며 이때 소송은 소유권이전등기청구소송 형태 취한다.

III. 甲의 환매권 행사요건 충족 여부

1. 법91조1항 요건

①공익사업의 폐지·변경·그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 때, 환매권자는, 공익사업의 폐지·변경의 경우 사업의 폐지·변경 고시가 있는 날부터 10년 내에, 그 밖의 사유의 경우 사업완료일부터 10년 이내에 그 토지에 대하여 받은 보상금 상당액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다. ②<해당사업>이란 토지 취득 목적이 된 구체적인 특정 공익사업을 의미한다. <사업의 폐지·변경>이란 해당 사업을 폐지하는 것뿐 아니라 다른 사업으로 전환하는 것도 포함한다. <그 밖의 사유>란 관계법에 의하여 사업의 폐지·변경 또는 그에 갈음하는 행위로 더 이상 목적사업에 제공할 필요가 없게 된 객관적 사유를 뜻한다. <필요없게 되었는지>는 사업자의 주관적 의사를 표준으로 할 것이 아니라, 당해 사업의 목적과 내용, 협의취득의 경위와 범

위, 당해 토지와 사업의 관계, 용도 등 제반사정에 비추어 객관적·합리적으로 판단한다.

2. 법91조2항 요건

①취득일부터 5년 이내에 취득한 토지의 전부를 해당 사업에 이용하지 아니하였을 때 취득일부터 6년 이내 환매권을 행사하여야 한다. ②특정 환매권자의 해당 필지를 기준으로 판단해서는 안되고, 사업시행자가 취득한 토지 전부를 기준해야 한다. ③사업에 이용할 필요가 없게 된 것이 아니라, 단지 사실상 사업에 제공되지 않은 경우를 말한다.

3. 91조 1항과 2항의 관계

서로 독립적으로 성립한다. 따라서 어느 한쪽의 요건에 해당된다고 하더라도 다른 쪽의 요건을 주장할 수 있고, 제2항의 규정에 의한 제척기간이 도과하였어도, 제1항의 규정에 의한 환매권 행사가 가능하다.

4. 사안의 경우

근린공원사업은 토지보상법 4조3호의 공원사업에 해당하고 취득일은 2005.6.30.이다. 근린공원으로 조성공사 완료하여 이용하다가 사후 택지개발예정지구지정으로 불필요하게 된 경우이고, 필요 없게 된 때에는 택지개발예정지구지정고시일인 2008.6.30.로 판단하여 취득일부터 10년 이내이다. 사안은 행사기간 충족한다.

IV. 환매권 행사제한 여부(공익사업 변환)

1. 공익사업변환의 의의, 근거, 취지

공익사업 변환은 공익사업이 다른 공익사업으로 변경된 경우 별도의 절차 없이 당해 토지를 변경된 공익사업에 이용하도록 하는 제도이다. 재취득하는 무용한 절차의 반복을 방지하기 위한 제도이다(토지보상법 제91조 6항). 토지 재취득의 무용한 절차반복 방지에 취지가 있다.

2. 공익사업변환 요건

①<사업시행자 요건> 사업인정을 받은 사업시행자가 국가, 지방자치단체 또는 공공기관이어야 한다. ②<대상사업 요건> 변경 전 공익사업은 사업인정을 받아야 하고, 변경 후 공익사업은 토지보상법 4조 1호부터 5호까지의 공익사업이어야 한다. ③새로운 공익사업은 사업인정을 받거나 받은 것으로 의제되어야 한다. 판례도 동지이다. ④변경된 사업시행자 아닌 제3자에게 처분되지 않았어야 한다.

3. 사업시행자 변경 시 변환규정의 적용여부

1) 학설

①공익성이 높은 사업으로 변경되는바, 사업시행자 변경 시에도 적용된다는 견해, ②변경 시 사업시행자가 토지가액 변동의 차액을 얻게 되는 불합리함이 있어 적용될 수 없다는 견해가 있다.

2) 판례

대법원은 관계 법령 규정이나 입법이유 등으로 미루어 볼 때, 공익사업 변환이 사업시행자가 동일한 경우에만 허용되는 것은 아니라 한다.

3) 검토

공익사업변환제도는 공공필요의 소멸이라는 수용본질의 한계 상 인정되는 것이므로, 이 취지에 반하는 예외규정은 좁게 해석함이 국민의 권리구제에 유리하다. 따라서 사업시행자 변경 시에는 동 규정은 적용되지 않는 것으로 봄이 타당한바, 사안은 공익사업 변환제도가 적용되지 않는다.

4. 사안의 경우

이전 사업은 사업인정이 있었고, 사업시행자가 지방자치단체에 해당한다. 변경 후 사업은 토지보상법 4조 5호에 해당하는 사업이고, 사업인정의제가 있었다. 다만, 사업시행자가 서울특별시에서 대한주택공사로 변경된바, 공익사업 변환을 인정하기 어려울 것이다.

V. 甲의 소송수단 및 그 인용가능성

1. 소송수단 및 환매방법

甲은 보상금 상당액을 미리 지급하고 환매의사표시를 표시하면 되고, 사업시행자가 이를 거부 시 민사소송으로 소유권이전등기청구소송을 제기하여야 한다. 다만, 환매권을 공권으로 보는 입장에서는 공법상 당사자소송을 제기하여 소유권을 회복할 수 있다.

2. 대항력(토지보상법91조5항)

환매권은 부동산등기법이 정하는 바에 따라 공익사업에 필요한 토지의 협의취득 또는 수용의 등기가 되었을 때에는 제3자에게 대항할 수 있다. 제3자에게 대항할 수 있다는 것은 권리 주장을 할 수 있다는 것이다.

3. 소유권이전등기청구소송(민사소송)과 인용가능성

甲은 환매권 요건을 충족하고 공익사업변환이 적용되지 않으며, 토지보상법은 환매권자가 제3자에게 대항할 수 있다고 규정하므로, 甲은 소유권이전등기청구소송이라는 민사소송을 제기할 수 있고 인용가능성이 있다. 다만, 사업시행자 변경 시 공익사업변환제도가 적용된다는 판례에 따를 때 인용가능성은 없다.

03. A지방자치단체는 도로사업 부지를 취득하기 위하여 甲의 토지를 협의취득하여 공공용지의 협의취득을 원인으로 하는 소유권이전등기를 하였고, 乙의 토지에 대하여는 수용재결에 의하여 소유권을 취득한 후 소유권이전등기를 마쳤다. 그러나 甲과 乙의 토지(이하 '이 사건 토지라 함)가 관내의 택지개발예정지구에 포함되자 A지방자치단체는 이 사건 토지가 도로사업에 더 이상 제공될 수 없는 상황에서 도로사업의 목적 달성이 불가능하다고 판단하여, 당초 협의취득 및 수용의 목적이 된 해당 도로사업을 폐지하였다. 이에 따라 甲과 乙에게 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 환매권이 발생하였다. 甲은 협의취득 당시에 수령한 보상금 상당 금액을 공탁한 후, A지방자치단체에게 환매의 의사표시를 하고 소유권이전등기청구소송을 제기하였다. 한편, 乙이 환매권을 행사할 무렵 환매금액에 관한 A지방자치단체와 乙의 협의가 성립되지 아니하여, A지방자치단체는 환매 대상 토지의 현재 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 상승하였음을 들어 환매대금의 증액을 구하는 소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. [기출 35회 1-1, 1-2]

물음 1) 乙의 환매권 및 乙에 대한 환매대금증액청구소송의 법적 성질을 각각 설명하시오.(15점)

물음 2) 甲의 소유권이전등기청구소송에서, A지방자치단체는 환매 대상 토지 가격의 상승에 따른 환매대금증액청구권을 내세워 증액된 환매대금과 보상금상당액의 차액을 지급할 것을 선(先)이행 또는 동시이행의 항변으로 주장할 수 있는지에 관하여 설명하시오.(10점)

목차

<물음1> 15점

I. 환매권의 의의, 취지, 근거 (「토지보상법」 제91조)

II. 환매권의 법적성질

1. 공권
 - 1)학설
 - 2)판례 및 검토
2. 형성권
3. 채권적 효력

III. 환매대금증액청구소송의 법적성질

1. 환매대금증액청구소송의 의의 (「토지보상법」 제91조)
2. 공법상 당사자소송 (「행정소송법」 제3조 제2호)
3. 관련 판례 (민사소송)
4. 소결

<물음2> 10점

I. 쟁점의 정리

II. 관련 규정 검토

1. 「토지보상법」 제91조 제4항(환매금액증감청구)
2. 「토지보상법 시행령」 제48조(현저한 변동의 의미)

III. 선이행 또는 동시이행의 항변 주장 가능성

1. 관련 판례
2. 소결

<물음1> 15점

I. 환매권의 의의, 취지, 근거 (「토지보상법」 제91조)

① 토지보상법상 환매권이란 공익사업에 필요하여 취득한 토지가 필요 없게 되거나 이용

되지 않는 경우에 원래의 토지 소유자가 일정한 요건 하에 원래의 토지를 취득할 수 있는 권리이다. ②피수용자의 감정 존중과 재산권 존속보장에 그 취지가 있다. ③이론적 근거로 피수용자의 감정 존중, 재산권 존속보장 등을, 법적 근거로 헌법 23조3항 및 토지보상법 91조를 들 수 있다.

II. 환매권의 법적성질

1. 공권

1)학설

①공법상 주체에 대해 사인이 가지는 공법상 권리로 보는 <공권설>, ②사업시행자가 사인과 평등한 지위에 있으며 그 목적이 사인의 이익을 위한 것이므로 사법상 권리로 보는 <사권설>이 있다.

2)판례 및 검토

①대법원과 헌법재판소는 환매권의 법적 성질을 사법상 권리로 보고, 사업시행자의 환매권 행사를 거부하는 의사표시는 공권력의 행사가 아니라고 판시한 바 있다. ②이론상으로 볼 때 사업시행자라는 공권력 주체에 대해 사인이 가지는 공법으로서 토지보상법 권리이므로 <공권>으로 봄이 타당하다.

2. 형성권

형성권이란 요건충족 시 일방적 의사표시로 형성적 효력이 발생하는 권리를 말하며 청구권과 달리 상대방이 동시이행 항변권을 주장하지 못하는 권리이다. 대법원은 환매권은 일종의 형성권으로서 재판상이든 재판외이든 그 기간 내에 행사하면 이로써 매매의 효력이 발생한다고 한다고 하여 일관되게 형성권으로 보고 있다.

3. 채권적 효력

토지를 환매할 수 있다는 의미에 대해 견해대립 있으나 소유권은 환매권자의 의사표시에 의해 소유권 이전이라는 물권적 효력을 발생한다고 보기 어려운바 소유권이전 등기청구권이라는 채권적 효력이 발생한다는 <채권적 효력설>이 타당하다. 판례도 같은 입장이며 이때 소송은 소유권이전등기청구소송 형태 취한다.

III. 환매대금증액청구소송의 법적성질

1. 환매대금증액청구소송의 의의 (「토지보상법」 제91조)

토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우 사업시행자와 환매권자가 환매금액에 대하여 서로 협의가 성립되지 아니할 때 사업시행자가 그 금액의 증액을 법원에 청구하는 소송을 의미한다.

2. 공법상 당사자소송 (「행정소송법」 제3조 제2호)

행정부의 처분 등을 원인으로 하는 법률관계나 그 밖에 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송이다. 구법과 종전판례에 의하면 환매대금증액청구소송은 공법상 당사자소송으로 보았다.

3. 관련 판례 (민사소송)

토지보상법 91조의 환매권은 형성권의 일종으로 규정에 따른 기간 내에 행사하면 매매의 효력이 생기는데, 환매금액의 증감을 구하는 소송 역시 민사소송에 해당한다.

4. 소결

공권력 주체에 대해 사인이 가지는 권리로 환매권을 <공권>으로 볼 수 있으며, 이에 따라 환매대금증액청구소송은 <공법상 당사자소송>으로 볼 것이다.

<물음2> 10점

I. 쟁점의 정리

해당 사안을 토지보상법 91조4항 및 시행령 48조, 판례를 중심으로 설명한다.

II. 관련 규정 검토

1. 「토지보상법」 제91조 제4항(환매대금증액청구)

토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우 사업시행자와 환매권자는 환매금액에 대하여 서로 협의하되, 협의가 성립되지 아니하면 그 금액의 증액을 법원에 청구할 수 있다.

2. 「토지보상법 시행령」 제48조(현저한 변동의 의미)

토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우는 환매권 행사 당시의 토지가격이 지급한 보상금에 환매 당시까지의 해당 사업과 관계없는 인근 유사토지의 지가변

동률을 곱한 금액보다 높은 경우로 한다.

Ⅲ. 선이행 또는 동시이행의 항변 주장 가능성

1. 관련 판례

환매권 행사로 인한 소유권이전등기 청구소송에서 환매대금 증액청구권을 내세워 증액된 환매대금과 보상금 상당액의 차액을 지급할 것을 선이행 또는 동시이행의 항변으로 주장할 수 없다.

2. 소결

환매권은 환매권자가 지급받은 보상액 상당액을 사업시행자에게 선지급하고 일방적 의사표시로 환매가 성립하는바, 환매대금 증액청구권을 내세워 증액된 환매대금과 보상금 상당액의 차액 지급을 선이행 또는 동시이행의 항변으로 주장할 수 없다.

<2편 손실보상-1장~3장 손실보상 일반론>

04. 재산권 가치보장과 존속보장에 관하여 서술하시오. (15점) [기출17회4]

목차
I. 재산권의 가치보장 1. 의의 2. 헌법적 근거 및 요건
II. 재산권의 존속보장 1. 의의 2. 헌법적 근거 및 내용과 한계 3. 실현제도
III. 결(가치보장과 존속보장의 관계)

I. 재산권의 가치보장

1. 의의

가치보장이란 공공필요에 따른 재산권의 공권적 침해가 있는 경우, 재산권의 가치를 보장하기 위해 보상 등으로 가치보장조치를 취하는 것을 말한다.

2. 헌법적 근거 및 요건

헌법 제23조 제3항은 공용침해 시 손실보상을 규정하고, 정당보상 원칙을 선언하고 있다. 가치보장의 요건으로, 공공필요에 따른 재산권의 공권적 침해로서 적법한 침해, 손실보상규정이 있을 것이 있다. 손실보상의 법률규정이 없는 경우는 별도의 견해대립이 있다.

II. 재산권의 존속보장

1. 의의

존속보장이란 재산권자가 재산권을 보유하고 향유하는 것을 보장하는 제도이다. 사유재산제 하에서 재산권은 배타적 권리이므로, 존속보장은 중요한 의미를 갖는다.

2. 헌법적 근거 및 내용과 한계

헌법 제23조 제1항은 재산권을 기본적으로 규정한다. 재산권의 내용은 사용권, 수익권, 처분권이다. 하지만 오늘날 재산권은 공공복리상 사회적 제약 하에 놓여 있고, 헌법 제23조 제2항은 이를 규정하고 있다. 헌법은 재산권보장을 원칙으로 규정하되, 그 내용과 한계는 법률로 정한다고 한다.

3. 실현제도

존속보장 실현제도로서, 공용침해 시 공공필요의 판단과정, 환매제도, 분리이론의 입장, 위법한 재산권 침해행위에 대한 취소소송 등이 존재한다.

III. 결(가치보장과 존속보장의 관계)

공공필요를 위한 공용침해가 있어 손실보상이 이루어지는 경우, 재산권의 존속보장은 가치보장제도인 손실보상으로 전환된다.

05. 손실보상에 있어서 사회적 제약과 특별한 희생의 구별기준에 관하여 경계이론과 분리이론의 입장을 설명하시오. (20점) [기출 14회 2]

목차
I. 개설 II. 경계-분리이론의 개관 1. 의의 2. 분리이론의 의의 III. 사회적 제약과 특별한 희생의 구별기준 1. 경계이론의 적용 2. 분리이론의 적용 IV. 결(분리이론의 도입에 대하여)

I. 개설

과거 독일의 연방통상최고법원의 판례를 통해 발전한 이론을 경계이론 또는 전환이론이라 한다. 한편, 독일의 연방헌법재판소는 1981년 자갈채취판결을 통해 헌법상 수용개념의 확대를 가져온 종래의 경계이론을 반박하고, 분리이론을 제시하였다. 양 이론은 사회적 제약과 특별한 희생에 대한 구별기준이 달라질 수 있는바, 논의 실익이 있다.

II. 경계-분리이론의 개관

1. 경계이론의 의의

경계이론은 사회적 제약과 공용침해는 별개의 제도가 아니라 침해의 정도에 따라 구별된다고 보고, 재산권의 내용과 한계규정이 특별한 희생을 야기하는 경우 수용이 된다고 보는 이론이다. 이 견해에 의하면 공공필요에 의한 재산권의 제약이 재산권에 내재하는 사회적 제약을 넘는 특별한 희생이 있는 경우 그에 대한 보상을 하여야 한다고 본다.

2. 분리이론의 의의

입법자의 의사에 따라 재산권에 대한 제한의 문제를 헌법 23조 1항 및 2항에 의한 재산권의 내용과 한계의 문제와 23조 3항의 공용침해와 손실보상의 문제로 구분하는 견해이다. 두 제도는 완전히 분리된 서로 다른 제도라고 본다.

III. 사회적 제약과 특별한 희생의 구별기준

1. 경계이론의 적용

이 이론의 핵심은 보상을 요하는 수용(특별한 희생)과 보상을 요하지 않는 사회적 제약 간의 경계설정, 즉 보상의무가 시작되는 경계선을 찾는 데 있다고 한다. 이러한 경계를 확정하는 기준으로는 형식적 기준설, 실질적 기준설, 그리고 절충설이 존재한다. 경계이론은 결과적으로 재산권보장의 의미를 가치보장으로 이해하는 것에 바탕을 두고 있다.

2. 분리이론의 적용

분리이론은 재산권자에게 과도한 부담을 주는 내용 및 한계규정도 수용으로 전환되지 않고 위헌적 내용 및 한계규정으로 남는다는 입장을 취한다. 재산관련 법률은 ① 재산권의 내용과 한계를 규정하는 법률, ② 직접적으로 공용수용을 규정하거나 행정행위를 통해 공용수용을 인정한 법률, ③ 독일기본법 제14조에 따른 재산권의 내용과 한계규정의 범위를 넘었으나 공용수용을 예견하지 않아 보상규정을 포함하지 않은 법률 3가지 경우로 구분된다. ③의 법률은 위헌이 되며 이에 기한 수용적 처분도 위법이나 보상규정이 없으므로 보상은 청구할 수 없고 수용적 행위의 취소를 행정법원에 청구할 수 있게 된다.

IV. 결(분리이론의 도입에 대하여)

분리이론은 독일 연방헌법재판소에서 취해진 이론인데, 이 이론에 대하여 찬성하는 견해는 존속보장을 강화하는 분리이론이 재산권보장에 기여할 수 있다고 한다. 도입에 반대하는 견해는 우리나라 헌법 제23조 제3항은 독일 기본법 제14조 제3항과 달리, 재산권의 수용뿐만 아니라 사용 및 제한도 규정하고 있기 때문에 공공필요에 의한 재산권의 제한은 공용제한과 손실보상의 문제로 보아야 한다고 주장한다.

06. 甲은 하천부지에 임시창고를 설치하기 위하여 관할청에 하천점용허가를 신청하였다. 이에 관할청은 허가기간 만료 시에 위 창고건물을 철거하여 원상복구할 것을 조건으로 이를 허가하였다. 甲은 창고건물철거에 따른 손실보상을 청구할 수 있는지 검토하시오. (10점) [기출20회 2-2]

목차
I. 논점의 정리
II. 특별한 희생의 판단기준
III. 관련판례
IV. 사안의 경우(甲의 손실보상 청구 불가능)

I. 논점의 정리

손실보상은 공공필요, 재산권에 대한 적법한 공권적 침해, 특별한 희생, 보상규정의 존재를 요건으로 한다. 하천의 원상회복은 공공필요가 인정되고, 관할청의 적법한 공권력 행사이며, 창고건물 철거 시 甲은 재산권에 대해 침해를 받는다. 손실보상 요건 중 철거에 따른 甲의 손실이 특별한 희생에 해당하는지 검토한다.

II. 특별한 희생의 판단기준

인적범위의 특징을 기준하는 <형식설>, 침해행위 성질과 정도를 기준으로 하는 <실질설>이 있다. <검토> 양자 타당한바, 상호 보완적으로 적용하는 <절충설>이 타당하다.

III. 관련판례

하천부지 점용허가를 하면서 점용기간 만료 또는 점용을 폐지하였을 때에는 즉시 원상복구할 것이라는 부관을 붙인 사안에서 이 부관의 의미는 하천부지에 대한 점용기간 만료 시 그에 관한 개간비보상청구권을 포기하는 것을 조건으로 본 사례가 있다.

IV. 사안의 경우(甲의 손실보상 청구 불가능)

甲은 자진철거를 하여 원상회복할 것을 조건으로 하천점용허가를 받은바, 허가기간 만료 시 철거로 인한 손실을 보호가치 있다거나 수인한도를 넘은 것이라고 보기 어렵다. 따라서 甲의 손실은 특별한 희생이 아니라고 판단한다. 甲손실은 특별한 희생이 아니므로, 甲은 창고건물철거에 따른 손실보상을 청구할 수 없다.

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 개별법 기본강의 6회

01. 택지개발사업이 시행되는 지역에 농지 4,000㎡를 소유하고 있던 甲은 보상금으로 사업주변지역에서 같은 면적의 농지를 대토하고자 하였다. 이 지역의 농지가격수준은 사업이 시행되기 이전만 하더라도 주변지역과 같게 형성되고 있었다. 그러나 해당 사업으로 인해 주변지역의 지가가 상승하여 甲은 보상금으로 3,000㎡밖에 매입할 수 없었다. (40점) [기출9회 1]

1) 甲이 받은 보상은 정당보상에 해당한다고 볼 수 있는가. (20점)

목차
I. 논점의 정리 II. 헌법 23조3항의 정당한 보상의 의미 1. 학설 2. 판례 3. 검토 III. 정당보상 여부의 검토 1. 공시지가기준 평가와 정당보상 1) 학설 2) 판례 3) 검토 2. 개발이익의 배제와 정당보상 1) 학설 2) 판례 3) 검토 IV. 사안의 해결

I. 논점의 정리

헌법 23조 3항은 공공필요에 의한 재산권의 수용, 사용 또는 제한은 법률로써 하되 정당한 보상을 지급하여야 한다고 규정하고 있으며, 정당한 보상의 의미가 문제된다.

II. 헌법 23조3항의 정당한 보상의 의미

1. 학설

손실보상은 ①공용침해로 발생한 피수용자의 재산권의 객관적 손실 전부를 보상하여야 한다는 <완전보상설>과 ②피침해 이익의 성질 및 강도와 함께 침해행위의 공공성을 고려하여 보상이 행하여 질 때의 사회통념에 비추어 객관적으로 타당하다고 여겨지는 보상을 의미하는 <상당보상설> 등의 견해대립이 있다.

2. 판례

판례는 손실보상액의 결정에 있어서 객관적 가치를 충분히 보상하여야 된다는 <완전보상설>의 입장을 취하며 나아가 보상의 시기, 방법 등에 있어서 어떠한 제한을 받아서는 아니 된다는 것을 의미한다고 판시하였다.

3. 검토

헌법 23조 3항의 정당한 보상이란 재산권 보장의 관점에서 볼 때 완전한 보상을 의미하는 것으로 보는 것이 피수용자의 권리구제 차원에서 타당하다고 본다.

III. 정당보상 여부의 검토

1. 공시지가기준 평가와 정당보상

1) 학설

①공시지가를 기준으로 보상액을 산정하는 것은 산정방법을 제한하는 것이며, 공시지가가 시가에 미달되어 보상액이 시가에 미달될 수 있으므로 공시지가 기준보상은 정당보상이 아니라고 보는 견해와, ②공시지가기준 평가는 개발이익의 배제를 위한 것으로 목적의 정당성이 있는바 정당보상에 합치한다는 견해의 대립이 있다.

2) 판례

판례는 수용대상토지의 적정가격을 정함에 있어 공시지가 기준보상이 위헌이라고 할 수 없다고 판시하였다.

3) 검토

공시지가는 토지의 특성상 가격형성요인이 복잡하여 적정가격을 판단하기 어렵고 왜곡되기 쉬운 문제점을 해결하고, 지가체계의 일원화를 위해 만든 제도이다. 따라서 공시지가가 시장 가격에 못 미친다고 하면 기타 요인 등을 통해서 완전보상에 이르게 하면 되고, 공시지가기준은 객관성이 있으므로 정정보상이 위배되는 것은 아니라고 봄이 타당하다.

2. 개발이익의 배제와 정정보상

1) 학설

①<합헌성>을 인정하는 견해는 개발이익은 국가 등의 투자에 의해 발생하는 것이고, 토지소유자 노력이나 투자에 의한 것이 아니므로 형평의 원칙상 개발이익은 토지소유자에게 귀속시켜서는 아니 되며 국민 모두에게 귀속되어야 할 것으로 본다. ②<위헌성>을 주장하는 견해는 개발이익이 배제된 보상금으로 종전과 같은 생활을 유지할 수 없고, 개발이익을 향유하는 사업주 주변 토지 소유자의 형평성도 맞지 아니하므로 헌법상 재산권 보장 및 평등원칙에 위배된다고 본다.

2) 판례

판례는 개발이익은 피수용자인 토지소유자의 노력이나 자본에 의하여 발생하는 것이 아니므로, 이러한 개발이익은 형평의 관념에 비추어 볼 때 개발이익의 배제는 정당한 보상 원칙에 위반되지 않는다고 판시하였다.

3) 검토

개발이익은 피수용자의 노력이나 자본투자에 의해 결정되는 것이 아니므로 토지소유자에게 귀속시키는 것은 타당하지 못하다.

IV. 사안의 해결

사안에서 甲에게 개발이익을 배제하고 보상하여 3천 제곱미터밖에 대토할 수 없더라도 정정보상의 원칙이 부정되었다고 할 수는 없을 것이고, 공시지가의 수준을 정정보상에 합치되도록 상향조정하는 것이 중요한 선택과제라고 할 수 있다.

02. 甲 소유의 토지를 포함하는 일단의 토지가 공공토지의 비축에 관한 법률에 따라 X읍-Y읍간 도로사업용지 비축사업(이하 '이 사건 비축사업'이라 함)지역으로 지정되었고, 한국토지주택공사를 사업시행자로 하여 2014. 3. 31. 이 사건 비축사업에 대하여 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 사업인정 고시가 있었다. 한편, 관할 도지사는 X읍-Y읍간 도로확포장공사와 관련하여 2016. 5. 1. 도로구역을 결정·고시하였는데, 甲의 토지는 도로확포장공사가 시행되는 도로구역 인근에 위치하고 있다. 이후 이 사건 비축사업을 위하여 甲 소유의 토지에 대해 2016. 7. 5. 관할 토지수용위원회의 수용재결이 있어는 바, 위 도로확포장공사로 인하여 상승된 토지가격이 반영되지 않는 감정평가가격으로 보상금이 결정되었다. 이에 甲은 도로확포장공사로 인한 개발이익이 배제된 보상금 결정은 위법하다고 주장하는 바, 甲의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. (10점) [기출28회 4]

개발이익 배제 논의 기출

토지보상법 제67조 및 제70조에서 규정하는 산정방법에 의하여 보상액을 산정하는 것이 정당보상에 합치되는지 논하시오. (10점) [기출12회1-3]

공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상 공시지가를 기초로 한 보상액 산정에 있어서 개발이익 배제 및 포함을 논하시오. (15점)[기출17회3]

목차

I. 논점의 정리

II. 개발이익 배제 원칙

III. 개발이익 배제의 근거 및 위헌여부

1. 법률적 근거
2. 판례 입장

IV. 사안 관련 판례

1. 개발이익 배제 대상인 공익사업
2. 개발이익 발생 시기

V. 甲주장의 타당성

I. 논점의 정리

개발이익 배제의 대상이 되는 사업의 의미 등을 검토하여 甲주장이 타당한지 본다.

II. 개발이익 배제 원칙

개발이익이란 공익사업 시행의 계획이나 시행이 공고·고시되어, 토지소유자의 노력과 관계없이 정상지가 상승분을 초과하여 증가된 부분을 말한다.

III. 개발이익 배제의 근거 및 위헌여부

1. 법률적 근거

토지보상법 67조 2항은 “보상액 산정 시 해당 공익사업으로 인하여 토지등의 가격이 변동되었을 때에는 이를 고려하지 아니한다.”라고 하여 개발이익 배제 원칙을 규정한다.

2. 판례 입장

헌법재판소는 개발이익 배제 원칙을 정한 토지보상법 규정이 헌법이 규정한 정당보상의 원리에 어긋나는 것이라고 할 수 없다고 판시하였으며, 대법원 또한 개발이익이 수용대상의 객관적 가치에 포함될 수 없다고 판시하였다.

IV. 사안 관련 판례

1. 개발이익 배제 대상인 공익사업

판례는 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 개발이익은 이를 고려함이 없이 적정가격을 정해야 하나, 관계없는 다른 사업으로 인한 개발이익은 이를 배제하지 아니한 가격으로 평가하여야 한다고 본다.

2. 개발이익 발생 시기

반영해야 할 개발이익이 해당 공익사업의 사업인정고시 이후 발생한 경우라도 마찬가지로

(개발이익을 반영해야 한다)라고 보았다.

V. 甲주장의 타당성

도로확포장공사는 이 사건 공익사업과 다른 공익사업이므로, 이에 따른 지가상승분은 반영되어 보상하여야 한다. 따라서 개발이익이 배제된 수용재결은 위법하고, 甲주장은 타당하다.

03. 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률에 규정되어 있는 손실 보상의 원칙을 약술하시오. (10점) [기출 15회 4]

목차
I. 개설 II. 토지보상법상 손실보상의 원칙 1. 사업시행자 보상(법61조) 2. 사전보상(법62) 3. 현금보상 등(법 63조) 4. 개인별 보상(법64) 5. 일괄보상(법65) 6. 사업시행 이익과의 상계금지(법66조) 7. 시가보상(법 67조1항) 및 개발이익의 배제(동조2항)

I. 개설

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)은 정당보상을 실현하기 위하여 61조 이하에서 손실보상의 원칙을 규정하고 있다.

II. 토지보상법상 손실보상의 원칙

1. 사업시행자 보상(법61조)

공익사업에 필요한 토지등의 취득 또는 사용으로 인하여 토지소유자나 관계인이 입은 손실은 사업시행자가 보상하여야 한다.

2. 사전보상(법62)

사업시행자는 해당 공익사업을 위한 공사에 착수하기 이전에 토지소유자와 관계인에게 보상액 전액(全額)을 지급하여야 한다. 다만, 제38조에 따른 천재지변 시의 토지 사용과 제39조에 따른 시급한 토지 사용의 경우 또는 토지소유자 및 관계인의 승낙이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 현금보상 등(법 63조)

손실보상은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 현금으로 지급하여야 한다.

4. 개인별 보상(법64)

손실보상은 토지소유자나 관계인에게 개인별로 하여야 한다. 다만, 개인별로 보상액을 산정할 수 없을 때에는 그러하지 아니하다.

5. 일괄보상(법65)

사업시행자는 동일한 사업지역에 보상시기를 달리하는 동일인 소유의 토지등이 여러 개 있는 경우 토지소유자나 관계인이 요구할 때에는 한꺼번에 보상금을 지급하도록 하여야 한다.

6. 사업시행 이익과의 상계금지(법66조)

사업시행자는 동일한 소유자에게 속하는 일단(一團)의 토지의 일부를 취득하거나 사용하는 경우 해당 공익사업의 시행으로 인하여 잔여지(殘餘地)의 가격이 증가하거나 그 밖의 이익이 발생한 경우에도 그 이익을 그 취득 또는 사용으로 인한 손실과 상계(相計)할 수 없다.

7. 시가보상(법 67조1항) 및 개발이익의 배제(동조2항)

① 보상액의 산정은 협의에 의한 경우에는 협의 성립 당시의 가격을, 재결에 의한 경우에는 수용 또는 사용의 재결 당시의 가격을 기준으로 한다.

② 보상액을 산정할 경우에 해당 공익사업으로 인하여 토지등의 가격이 변동되었을 때에는 이를 고려하지 아니한다.

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 개별법 기본강의 7회

<공법상 제한받는 토지~사용하는 토지에 대한 보상평가>

01. 甲은 S시에 600㎡의 토지를 소유하고 있다. S시장 乙은 2011년 5월 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의거하여 수립한 도시관리계획으로 甲의 토지가 포함된 일대에 대해 공원구역으로 지정하였다가 2006년 5월 민원에 따라 甲의 토지를 주거지역으로 변경지정하였다. 乙은 2010년 3월 정부의 녹색도시조성 정책에 부응하여 도시근린공원을 조성하고자 甲의 토지에 대해 녹지지역으로 재지정하였다. 乙은 공원조성사업을 추진하기 위하여 甲의 토지를 수용하였는데, 보상금산정시 녹지지역을 기준으로 감정평가한 금액을 적용하였다. 그 적법성 여부를 논하시오. (20점) [24회 1-2]

목차

I. 논점의 정리

II. 공법상 제한을 받는 토지의 의의

III. 공법상 제한을 받는 토지의 보상평가

1. 공법상 제한 반영여부(토지보상법 시행규칙 23조1항)
2. 당해 사업을 직접 목적으로 용도지역이 변경된 경우(동조 2항)
3. 관련 조문의 취지

IV. 관련 판례

V. 사안의 해결

I. 논점의 정리

乙이 주거지역이 아닌 녹지지역을 기준한 감정평가액을 기초로 보상금을 산정한 것이 적법한지 문제된다.

II. 공법상 제한을 받는 토지의 의의

공법상 제한을 받는 토지란 관계법령에 의하여 토지의 이용규제나 제한을 받는 토지를 말한다. 가장 대표적인 것이 국토계획법상 용도지역, 용도지구, 용도구역의 지정을 받은 토지이다. 공법상 제한은 다시 일반적 계획제한의 경우와 개별적 계획제한의 경우로 나뉜다.

III. 공법상 제한을 받는 토지의 보상평가

1. 공법상 제한 반영여부(토지보상법 시행규칙 23조1항)

공법상 제한을 받는 토지에 대해서는 제한받는 상태대로 평가하며, 다만, 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 공법상 제한이 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태를 상정하여 평가한다.

2. 당해 사업을 직접 목적으로 용도지역이 변경된 경우(동조 2항)

해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 등이 변경된 토지에 대해서는 변경되기 전의 용도지역 등을 기준한다.

3. 관련 조문의 취지

토지보상법 제67조 제2항의 개발이익 내지 손실을 제외하기 위함이며, 판례는 정당보상을 위한 조치라고 보았다.

IV. 관련 판례

판례는 공법상 제한을 받는 토지의 수용보상액을 산정함에 있어서 그 공법상 제한이 당해 공익사업 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우 그 제한을 받지 않은 상태대로 평가하여야 하고, 당해 공익사업 시행 이전에 당해 공익사업과 관계없이 이미 도시계획법에 의한 고시 등으로 일반적 계획제한이 가하여진 경우에는 그러한 제한을 받는 상태대로 평가하여야 한다고 보았다.

V. 사안의 해결

乙은 도시관리계획의 수립권자로서 甲토지를 2002년 5월 공원구역 지정, 2006년 5월 주거지역으로 변경, 2010년 3월 녹지지역으로 재지정 하였고, 녹지지역 재지정은 도시근린공원 조성사업을 직접 목적으로 하는 것으로 보상액 산정 시 재지정 전 용도지역인 주거지역을 기준하여야 한다. 따라서 보상금 산정 시 녹지지역을 기준으로 감정평가한 금액을 적용한 것은 적법하지 않다.

02. A시 시장 甲은 1990년에 자연공원법 에 의하여 A 시내 산지 일대 5 km²를 'X시립공원'으로 지정·고시한 다음, 1992년에 X시립공원 구역을 구분하여 용도지구를 지정하는 내용의 'X시립공원 기본계획'을 결정·공고하였다. 甲은 2017년에 X시립공원 구역 내 10,000 m² 부분에 다목적광장 및 휴양관(이하 '이 사건 시설'이라 한다)을 설치하는 내용의 'X시립공원 공원계획'을 결정·고시한 다음, 2018년에 甲이 사업시행자가 되어 이 사건 시설에 잔디광장, 휴양관, 도로, 주차장을 설치하는 내용의 'X시립공원 공원사업'(이하 '이 사건 시설 조성사업'이라 한다) 시행계획을 결정·고시하였다. 甲은 이 사건 시설 조성사업의 시행을 위하여 그 사업구역 내에 위치한 토지(이하 '이 사건 B토지'라 한다)를 소유한 乙과 손실보상에 관한 협의를 진행하였으나 협의가 성립하지 않자 수용재결을 신청하였다. 관할 지방토지수용위원회의 수용재결 및 중앙토지수용위원회의 이의재결에서 모두 이 사건 B토지의 손실보상금은 1990년의 X시립공원 지정 및 1992년의 X시립공원 용도지구 지정에 따른 계획제한을 받는 상태대로 감정평가한 금액을 기초로 산정되었다. 乙은 이 사건 B토지에 대한 보상평가는 1990년의 X시립공원 지정·고시 이전을 기준으로 하여야 한다고 주장한다. 乙의 주장은 타당한가? (10점)[31회1-2]

목차
I. 논점의 정리
II. 공법상 제한을 받는 토지의 평가(시행규칙 23조)
III. 판례
IV. 乙주장의 타당성

I. 논점의 정리

공법상 제한에 관한 시행규칙 제23조 등을 검토한다.

II. 공법상 제한을 받는 토지의 평가(시행규칙 23조)

공법상 제한을 받는 토지에 대하여는 제한받는 상태대로 평가하되, 그 공법상 제한이 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태를 상정하여 평가하고, 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 또는 용도지구 등이 변경된 토지에 대하여는 변경되기 전의 용도지역 또는 용도지구 등을 기준으로 평가하여야 한다.

III. 판례

자연공원법에 의한 '자연공원 지정' 및 '공원용도지구 계획에 따른 용도지구 지정'은, 그와 동시에 구체적인 공원시설을 설치·조성하는 내용의 '공원시설계획'이 이루어졌다는 특별한 사정이 없는 한, 그 이후에 별도의 '공원시설계획'에 의하여 시행 여부가 결정되는 구체적인 공원사업의 시행을 직접 목적으로 한 것이 아니므로 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙 제23조 제1항 본문에서 정한 '일반적 계획제한'에 해당한다고 판시하였다.

IV. 乙주장의 타당성

1990년경 있었던 X시립공원 지정고시에는 그와 동시에 구체적인 공원시설을 설치·조성하는 내용의 공원시설계획이 이루어지지 않았으므로, 사안의 공법상 제한은 일반적 계획제한으로 봄이 타당하다. 따라서 X시립공원 지정, 고시 이전(반영해서는 안된다)을 기준으로 해야 한다는 乙의 주장은 타당하지 않다.

03. 공부상 지목이 과수원(果)으로 되어 있는 토지의 소유자 甲은 토지상에 식재되어 있던 사과나무가 이미 폐목이 되어 과수농사를 할 수 없는 상태에서 사과나무를 베어내고 인삼밭(田)으로 사용하여 왔다. 또한 甲은 이 토지의 일부에 토지의 형질변경허가 및 건축허가를 받지 않고 2005년 8월 26일 임의로 지상 3층 건물을 건축하고, 영업허가 등의 절차 없이 식당을 운영하고 있다. 사안의 토지에 대한 보상평가기준에 대해 설명하시오. (10점)[18회3-2변형]

목차
I. 공시지가기준, 현황기준평가
II. 개발이익 배제
III. 불법형질변경 및 무허가건축물부지 평가(시행규칙 24조)
IV. 사안의 경우

I. 공시지가기준, 현황기준평가

토지는 표준지공시지가를 기준으로 보상하고(토지보상법 70조 1항) 가격시점에서 현실적 이용상황을 기준하되, 일시적 이용상황과 주관적 가치는 고려하지 않는다(제70조2항).

II. 개발이익 배제

당해 공익사업으로 토지 가격이 변동된 경우 이를 고려하지 않는다(제67조 제2항).

III. 불법형질변경 및 무허가건축물부지 평가(시행규칙 24조)

사안은 불법형질변경토지 및 무허가건축물부지를 포함한다. 토지보상법 시행규칙 제24조에 따라 평가해야 한다. 허가를 받거나 신고를 하여야 하나, 그러하지 아니하고 건축

또는 용도변경을 한 건축물의 부지나 형질변경을 한 토지는 건축 또는 용도변경될 당시 또는 형질변경 당시 이용상황을 상정한다. 다만, 무허가 건축물부지는 1989.1.24.이전에 건축된 경우, 불법형질변경토지는 1995.1.7.당시 공익사업 시행지구 편입된 경우라면 각 현황을 기준으로 평가한다.

IV. 사안의 경우

사안은 예외적 사유에 해당되지 않으며, 건축 당시 및 형질변경될 당시 이용상황을 상정하여 평가하여야 할 것이다. 현황기준평가의 예외에 해당한다.

04. 甲이 소유하고 있던 토지는 육군 제○○○○부대가 경기도 포천군수에게 토지에 대한 분할신고를 의뢰한 1982년을 전후하여 도로로 편입되었으나 그에 대한 보상이 이루어지지 아니한 채 사용되다가 동두천시 탑동동에서 포천시 가산면 마산리에 이르는 광암-마산간 도로확포장공사(이하 이 사건 사업)에 편입되었다. 이 사건 사업시행자는 해당 사업의 사업인정을 받고 甲과 협의하였으나 도로에 준하여 보상액을 산정하자, 협의 불성립되었다. 甲은 종전 공익사업에 편입될 당시의 이용상황인 '답'으로 상정하여 평가하여야 한다고 주장한다. 미지급용지의 판단기준 및 보상평가기준에 대해 설명하고, 甲주장의 타당성을 검토하시오. (20점)

목차
I. 미지급용지의 의의 및 취지(토지보상법 시행규칙 25조) II. 미지급용지의 판단기준 및 적용범위 1. 판단기준 2. 적용범위 III. 미지급용지의 보상평가기준 1. 평가기준 2. 가격시점 3. 공법상 제한 등 4. 개발이익의 배제 IV. 甲주장의 타당성

I. 미지급용지의 의의 및 취지(토지보상법 시행규칙 25조)

미지급용지란 종전에 시행된 공익사업의 부지로서 보상금이 지급되지 아니한 토지를 말한다. 피수용자 불이익 방지에 취지가 있다. 법70조 2항 현황평가의 예외이다.

II. 미지급용지의 판단기준 및 적용범위

1. 판단기준

미지급용지에 대한 개별적인 사례에 대해서는 사업시행자가 사실 관계를 조사하여 판단·결정할 사항이다. 예를 들어 도로의 경우 사업시행자가 도로의 개설 경위, 이용상황 등을 종합적으로 검토하여 판단할 사항으로 보고 있다. 미지급용지로 인정되려면 종전에 공익사업이 시행된 부지여야 하고, 종전의 공익사업은 적어도 당해 부지에 대하여 보상금이 지급될 필요가 있는 것이어야 한다.

2. 적용범위

종전의 공익사업으로 인해 지가가 상승하였을 때에도 미지급용지로 보아 평가해야 하는지 관련하여 견해가 나뉘나 판례는 종전의 공익사업의 시행으로 인하여 토지의 현실적인 이용상황을 변경시킴으로써 가격이 상승하였다면 미불용지에 포함되지 않는 것으로 보고 있다.

III. 미지급용지의 보상평가기준

1. 평가기준

원칙은 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다. 다만, 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 알 수 없는 경우에는 편입될 당시의 지목과 인근 토지의 이용상황 등을 참작하여 평가한다(칙 제25조 제1항). '종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황'을 상정하는 때에는 편입당시의 지목·실제 용도·지형·지세·면적 등의 개별요인을 고려하여야 한다. 인근지역의 표준적 이용상황이 변경된 경우는 가격시점에서의 인근토지의 표준적 이용상황을 기준으로 판단하되 그 형질변경에 드는 비용을 고려해야 한다. 대법원도 도로에 편입된 이후 대상토지의 위치나 주위 토지의 개발 및 이용상황 등에 비추어 도로가 개설되지 아니하였더라도 당해 토지의 현실적 이용상황이 주위 토지와 같이 변경되었을 것임이 객관적으로 명백하게 된 경우, 변경된 이용상황을 상정하여 토지가격을 감정평가해야 하는 것이 타당하다고 판시하고 있다.

2. 가격시점 및 공법상 제한, 개발이익의 배제 등

가격시점은 일반보상과 마찬가지로 계약체결 당시를 기준으로 한다. 용도지역 등이 종전 또는 새로운 공익사업과 관계없이 변경된 경우에는 가격시점에서의 용도지역 등을 기준으로 감정평가한다. 미지급용지의 평가시 종전 및 당해 공익사업으로 인한 가격변동이 포함되어 있는 경우 이를 모두 배제하고 평가한다.

IV. 甲주장의 타당성

甲이 소유하고 있던 토지는 육군 제○○○○부대가 경기도 포천군수에게 토지에 대한 분할신고를 의뢰한 1982년을 전후하여 도로로 편입되었으나 그에 대한 보상이 이루어지지 아니한 채 사용되던 토지로, 종전 도로편입 공사는 공익을 위한 특별한 희생으로 볼 수 있어 당해 부지에 대하여 보상금 지급 필요가 있는 것이다. 즉, 당해 토지는 미지급용지로 볼 수 있다. 따라서 종전 공익사업에 편입될 당시의 이용상황인 '답'을 상정하여 평가하여야 하는바, 甲 주장은 타당하다.

05. X는 도시 및 주거환경정비법 (이하 '도시정비법'이라 함)에 따른 재개발정비사업조합이고, 甲은 X의 조합원으로서, 해당 정비사업구역 내에 있는 A토지와 B토지의 소유자이다. A토지와 B토지는 연접하고 있고 그 지목이 모두 대(垓)에 해당하지만, A토지는 사도법 에 따른 사도가 아닌데도 불특정 다수인의 통행에 장기간 제공되어 왔고, B토지는 甲이 소유한 건축물의 부지로서 그 건축물의 일부에 임차인 乙이 거주하고 있다. X는 도시정비법 제72조 제1항에 따라 분양신청기간을 공고하였으나 甲은 그 기간 내에 분양신청을 하지 않았다. 이에 따라 X는 甲을 분양대상자에서 제외하고 관리처분계획을 수립하여 인가를 받았고, 그에 불복하는 행정심판이나 행정소송은 없었다. X는 도시정비법 제73조 제1항에 따른 甲과의 보상협의를 이루어지지 않자 A토지와 B토지에 관하여 관할 토지수용위원회에 수용재결을 신청하였고, 관할 토지수용위원회는 A토지와 B토지를 수용한다는 내용의 수용재결을 하였다. 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙 (이하 '토지보상법 시행규칙'이라 함) 제26조 제1항에 따른 '사실상의 사도'의 요건을 설명하고, 이에 따라 A토지가 사실상의 사도로 인정되는 경우와 그렇지 않은 경우에 보상기준이 어떻게 달라지는지 설명하시오. (10점)[기출33회 1-2]

목차

I. 사실상 사도의 요건

1. 의의, 취지 및 근거
2. 요건
3. A토지가 사실상 사도 요건을 갖추었는지

II. 보상기준

1. 사실상의 사도로 인정되는 경우
2. 사실상의 사도로 인정되지 않는 경우

I. 사실상 사도의 요건

1. 의의, 취지 및 근거

사실상의 사도란 그 효용은 사도법상 사도와 같으나 관할 시장 등의 허가를 받지 않고 개설하거나 형성된 도로를 말한다.

2. 요건

토지보상법 시행규칙 제26조 제1항에서는 ①도로개설당시의 토지소유자가 자기토지의 편익을 위하여 스스로 설치한 도로(1호), ②토지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없는 도로(2호), ③건축법 45조 규정에 의하여 건축허가권자가 그 위치를 지정, 공고한 도로(3호), ④도로개설당시의 토지 소유자가 대지 또는 공장용지 등을 조성하기 위하여 설치한 도로(4호)를 사실상의 사도 요건으로 정하고 있다.

3. 판례

판례는 1호 요건과 관련하여, 토지 소유자가 자기 소유 토지 중 일부에 도로를 설치한 결과 도로 부지로 제공된 부분으로 인하여 나머지 부분 토지의 편익이 증진되는 등으로 그 부분의 가치가 상승됨으로써 도로부지로 제공된 부분의 가치를 낮게 평가하여 보상 하더라도 전체적으로 정당보상의 원칙에 어긋나지 않는다고 볼 만한 객관적인 사유가 있다고 인정되어야 한다고 보았다.

4. A토지가 사실상 사도 요건을 갖추었는지

판례는 2호 요건과 관련하여 법률상 소유권을 행사하여 통행을 제한할 수 없는 경우뿐만 아니라 사실상 통행을 제한하는 것이 곤란하다고 보이는 경우도 해당한다고 할 것이나, 적어도 도로로의 이용상황이 고착화되어 당해 토지의 표준적 이용상황으로 원상회복하는 것이 용이하지 않은 상태에 이르러야 할 것이어서 단순히 당해 토지가 불특정 다수인의 통행에 장기간 제공되어 왔고 이를 소유자가 용인하여 왔다는 사정만으로는 사실상의 도로에 해당한다고 할 수 없다고 보았다. 따라서 A토지의 경우 “불특정 다수인의 통행에 장기간 제공”된 사정만으로는 칙26조 1항 2호 요건에 해당하지 않는다. “도로로의 이용상황이 고착화될 것 등”의 요건까지 갖추었다면, 사실상의 사도로 볼 수 있다.

II. 보상기준

1. 사실상의 사도로 인정되는 경우

인근토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내로 평가된다.

2. 사실상의 사도로 인정되지 않는 경우

사실상의 사도로 인정되지 않는다면, 3분의 1 이내로 감가되지 않고 형상 등의 가격형성요인은 개별요인에서 반영하여 평가한다.

06. 공공사업시행 시 잔여지 및 잔여건물 보상에 관하여 설명하시오. (20점) [13회4]

목차
I. 잔여지에 대한 보상 1. 잔여지의 의미 2. 잔여지의 가치하락 및 공사비 보상(법 제73조) 3. 잔여지 매수 및 수용청구(법 제74조) II. 잔여건축물에 대한 보상(법 제75조) 1. 잔여 건축물의 가치손실 보상과 보수비 보상 2. 잔여건축물의 매수 또는 수용청구(법 제75조의2 제2항) III. 결(잔여지수용청구에 대한 토지수용위원회의 재결에 불복)

I. 잔여지에 대한 보상

1. 잔여지의 의미

잔여지란 동일한 토지소유자에게 속하는 일단의 토지 중 일부만이 공익사업에 제공되고 남는 토지로서 종래의 목적이나 용도에 이용할 수 없게 되거나 다른 용도로 이용할 수 없게 된 토지를 말한다.

2. 잔여지의 가치하락 및 공사비 보상(법 제73조)

토지보상법 제 73조에 의거하여 잔여지의 가격이 감소하거나 그 밖에 손실이 있는 때 또는 잔여지에 공사가 필요한 때에는 국토교통부령이 정하는 바에 따라 그 손실이나 공사비를 보상하여야 한다. 잔여지 가격이 하락된 경우에는 편입되기 전 잔여지의 가격에서 편입 후 잔여지의 가격을 뺀 금액으로 평가하며 공사비는 공사에 필요한 비용으로 평가한다. 잔여지의 가치손실 또는 공사비의 보상은 해당 사업의 공사완료일부터 1년이 지난 후에는 청구할 수 없다.

3. 잔여지 매수 및 수용청구(법 제74조)

잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란할 때에는 해당 토지 소유자는 사업시행자에게 잔여지를 매수하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사업인정 이후에는 관할 토지수용위원회에 수용을 청구할 수 있다. 이 경우 수용의 청구는 매수에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우에만 할 수 있으며, 그 사업의 공사완료일까지 하여야 한다. 잔여지의 판단은 시행령 39조에 의거한다.

II. 잔여건축물에 대한 보상(법 제75조)

1. 잔여 건축물의 가치손실 보상과 보수비 보상

잔여 건축물의 가격이 감소되거나 그 밖의 손실이 있을 경우에는 그 손실을 보상하여야 한다. 보상액은 공익사업시행지구에 편입되기 전의 잔여 건축물의 가격에서 공익사업시행지구에 편입된 후의 잔여 건축무리의 가격을 뺀 금액으로 평가한다. 보수비는 건축물의 잔여부분을 종래의 목적대로 사용할 수 있도록 그 유용성을 동일하게 유지하는데 통상 필요하다고 볼 수 있는 공사에 사용되는 비용으로 평가한다.

2. 잔여건축물의 매수 또는 수용청구(법 제75조의2 제2항)

잔여지와 마찬가지로 사업시행자 및 관할 토지수용위원회를 상대로 매수청구가 가능하며, 사업인정 이후에는 관할 토지수용위원회에 수용을 청구할 수 있다. 이 경우 수용의 청구는 매수에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우에만 하되, 그 사업의 공사완료일까지 하여야 한다.

07. 한국수자원공사는 한국수자원공사법 제9조 및 제10조에 근거하여 수도권(首都圈) 광역상수도사업 실시계획을 수립하여 국토해양부장관의 승인을 얻은 후, 1필지인 甲의 토지 8,000㎡ 중 6,530㎡를 협의취득하였다. 협의취득 후 甲의 잔여지는 A지역 495㎡, B지역 490㎡, 그리고 C지역 485㎡로 산재(散在)하고 있다. (30점) [23회2]

1) 甲은 위 잔여지의 토지가격의 감소를 이유로 손실보상을 청구하려고 한다. 이 경우 잔여지의 가격감소에 대한 甲의 권리구제방법을 설명하시오. (15점)

2) 호텔을 건립하기 위해 부지를 조성하고 있던 甲은 자신의 잔여지를 더 이상 종래의 사용목적대로 사용할 수 없게 되자 사업시행자와 매수에 관한 협의를 하였으나, 협이가 성립되지 아니하였다. 이에 甲은 관할 토지수용위원회에 잔여지의 수용을 청구하였지만, 관할 토지수용위원회는 이를 받아들이지 않았다. 이 경우 잔여지수용청구의 요건과 甲이 제기할 수 있는 행정소송의 형식을 설명하시오. (15점)

목차
<물음1> 15점 I. 논점의 정리 II. 잔여지 가격감소에 대한 손실보상청구 1. 의의 및 취지 2. 甲의 잔여지에 가격감소가 발생하였는지 III. 잔여지의 가격감소에 대한 甲의 권리구제방법

1. 토지보상법 제73조
2. 한국수자원공사와의 협의
3. 협의 불성립 시 재결신청
4. 중앙토지수용위원회의 재결에 불복하는 경우 불복방법
 - 1) 학설
 - 2) 판례 및 검토

<물음2> 15점

I. 잔여지 수용청구의 의의 및 요건

1. 의의 및 취지
2. 잔여지수용청구의 요건
3. 판례
4. 사안의 경우

II. 甲이 제기할 수 있는 행정소송의 형식(보상금증감청구소송)

1. 학설
2. 판례
3. 사안의 경우

<물음1> 15점

I. 논점의 정리

甲의 잔여지에 가격감소가 발생하였는지 검토한 후 토지보상법 제73조 제4항에 근거하여 甲이 잔여지 가격감소에 대한 권리구제로서 협의 또는 손실보상의 재결신청 및 재결 불복 시 재결의 처분성에 따른 소송의 형식이 문제된다.

II. 잔여지 가격감소에 대한 손실보상청구

1. 의의 및 취지
- 통일한 소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 취득되어 잔여지의 가격이 감소한 경우 손실보상을 청구하는 것을 말한다. 이는 사업시행으로 인하여 발생한 부대적 손실의 보상으로 헌법 제23조 제3항의 완전보상 원칙 달성에 취지가 있다.

2. 甲의 잔여지에 가격감소가 발생하였는지
1필지인 甲ml 토지 8천제곱미터 중 그 일부가 취득되었고 잔여지는 각각 약 5백제곱미터의 소규모 필지로 A, B, C 지역별로 산재하게 되었다. 이로 인하여 토지의 효용이 감소되어 가격감소가 발생하였다고 판단된다.

Ⅲ. 잔여지의 가격감소에 대한 甲의 권리구제방법

1. 토지보상법 제73조
잔여지 가격감소 권리구제방법은 제9조 6, 7항을 준용한다. 즉, 그 손실의 보상은 사업시행자와 손실을 입은 자가 협의하여 결정하되, 협의가 성립되지 아니하면 사업시행자나 손실을 입은 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.

2. 한국수자원공사와의 협의
甲은 잔여지 가격감소에 따른 손실보상금을 한국 수자원 공사와 협의하여 결정할 수 있다.

3. 협의 불성립 시 재결신청
잔여지가 세 지역에 산재하는바, 甲의 토지는 둘 이상의 시도에 걸쳐있다고 보이며 토지보상법 51조 1항에 의거 관할 토지수용위원회는 중앙토지수용위원회로 판단된다. 甲은 한국수자원공사와 협의가 불성립된 경우 중앙토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.

4. 중앙토지수용위원회의 재결에 불복하는 경우 불복방법

1) 학설

손실보상금만의 재결의 처분성에 대하여 견해가 대립한다. 재결의 처부성을 인정하여 토지보상법 83조 및 85조에 다른 이의신청 및 보상금증액청구소송을 제기할 수 있다는 견해, 재결의 처분성을 부정하여 재결절차 없이도 행정소송법 3조 2호의 공법상 당사자소송을 곧바로 제기할 수 있다는 견해가 있다.

2) 판례 및 검토

판례는 소위 보상재결의 처분성을 긍정하며, 또한 재결절차를 반드시 거쳐 이의신청 및 행정소송을 제기할 수 있다고 보며, 이를 생략한 채 곧바로 사업시행자에게 손실보상을 청구할 수 없다고 본다. 생각건대, 보상재결 또한 국민의 권리의무에 직접 영향을 미치

는 ㄴ점에서 처분으로 봄이 타당하므로, 재결절차를 거쳐 이의신청, 행정소송을 권리구제방법으로 볼 수 있다.

<물음2> 15점

Ⅰ. 잔여지 수용청구의 의의 및 요건

1. 의의 및 취지

잔여지수용청구란 동일한 소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 매수, tndydehlamd로 인하여 잔여지를 종래목적에 사용하는 것이 현저히 곤란할 때 토지소유자가 관할 토지수용위원회에 그 토지의 수용을 청구하는 것을 말한다. 이는 수용목적물에 대한 최소침해원칙의 예외로서 토지소유자를 실질적으로 구제함에 그 취지가 있다.

2. 잔여지수용청구의 요건

청구인은 잔여지의 소유자이어야 한다. 청구기간은 사업의 공사완료일까지 하여야 한다. 청구절차는 사업인정 이후로서 사업시행자와 잔여지매수에 관한 협의가 성립되지 않아야 한다. 잔여지 요건으로서 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란하여야 한다.

3. 잔여지수용청구 요건에 관한 판례

대법원은 종래목적이란 수용당시의 이용상황을 사용이 현저히 곤란이란 물리적경제적사회적으로 사용하는 것이 곤란한 경우와 비용이 많이 소요되는 경우를 의미한다고 해석한다. 이와 관련하여 동법 시행령 39조는 잔여지 요건의 판단기준으로서 대지, 농지, 그 밖에 유사한 경우를 규정하고 있고 이를 판단할 때에는 위치 등을 고려한다고 규정한다.

4. 사안의 경우

해당 토지는 A, B, C지역으로 산재하게 되었고 면적이 감소하고 허상이 불리하게 되었으므로, 종래 호텔부지로 이용하는 것이 현저히 곤란하다고 판단된다. 잔여지수용청구요건을 충족한다.

Ⅱ. 甲이 제기할 수 있는 행정소송의 형식(보상금증감청구소송)

1. 학설

잔여지수용은 재결에 의해 수용하는 토지의 구역이고, 재결은 일정시기까지 보상금 지급이 행해지지 않으면 실효되는 점 등에 비추어 단순 보상의 문제가 아니므로, 보상원인이 되는 확장수용은 재결을 다투는 방법인 항고소송에 의해야 한다는 부정설, 확장수

용청구의 실질은 피수용자의 이익을 고려한 손실보상이고 손실범위에 따라 보상금 액수의 증감이 있으므로, 목적물 심리범위도 보상금증감청구소송으로 심리할 수 있다는 긍정설이 있다.

2. 판례

대법원은 잔여지수용청구권은 그 요건을 구비한 때에는 청구에 의하여 수용의 효과가 발생하는 형성권적 성질을 가지므로 재결에 불복하여 제기하는 소송은 보상금의 증감에 관한 소소에 해당한다고 한다.

3. 사안의 경우

생가건대, 보상금증감청구소송의 취지가 분쟁의 일회적 해결에 있고 손실범위에 따라 보상금액이 달라지므로 긍정설 입장이 타당하다. 결국, 甲은 보상금증액 청구소송의 형식으로 소송을 제기할 수 있다.

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 개별법 기본강의 8회

<이주대책>

01. A시는 도시개발사업을 하면서 주거를 상실하는 거주자에 대한 이주대책을 수립하였다. 이주대책의 주요내용은 다음과 같다. 이를 근거로 다음 물음에 답하시오.(45점)[기출 20회1]

- 기준일 이전부터 사업구역 내 자기 토지상 주택을 소유하고 협의 계약 체결일까지 당해 주택에 계속 거주한 자가 보상에 합의하고 자진 이주한 경우 사업구역 내 분양아파트를 공급한다.
- 분양아파트를 공급받지 않은 이주자에게는 이주정착금을 지급한다.
- 무허가건축물 대장에 등록된 건축물 소유자는 이주대책에서 제외한다.

- 1) 이주대책의 이론적 및 헌법적 근거를 설명하시오. (5점)
- 2) 주택 소유자 甲이 보상에 합의하고 자진 이주하지 아니한 경우에도 이주대책에 의한 분양아파트의 공급 혹은 이주정착금의 지급을 요구할 수 있는지의 여부를 검토하시오. (20점)
- 3) 89.1.24 이전은 무허가건축물의 소유자 乙이 당해 건축물이 무허가건축물이라는 이유로 분양신청을 하였음에도 이주대책에서 제외된 경우에 권리구제를 위하여 다룰 수 있는 근거와 소송방법에 관하여 검토하시오. (20점)

목차

<물음1>5

I. 이주대책의 의의

II. 이주대책의 이론적 근거

III. 이주대책의 헌법적 근거

1. 문제점
2. 학설
3. 판례 및 검토

<물음2>20

I. 논점의 정리

II. 甲이 이주대책 대상자인지

1. 토지보상법 요건
2. A시의 이주대책 대상자 규정의 법적성질
 - 1) 관련 판례
 - 2) A시 기준의 객관적 합리성·타당성 여부
3. 甲이 이주대책 대상자인지

III. 甲에게 수분양권이 있는지

1. 학설
2. 판례
3. 검토 및 사안의 경우

IV. 사례 해결

<물음3>20

I. 논점의 정리

II. 乙의 이주대책 대상자 여부

III. 乙의 권리구제를 위한 소송방법

1. 제외행위에 대한 취소소송
 - 1) 확인·결정행위 법적성질
 - 2) 제외행위의 법적성질
 - 3) 제외행위의 위법성 및 그 정도
 - 4) 사안의 경우
2. 수분양권 확인의 당사자 소송
 - 1) 수분양권이 공법상 권리인지
 - 2) 사안의 경우

<물음1>5

I. 이주대책의 의의

이주대책이란 공익사업 시행으로 인해 생활의 근거를 상실한 자에게 사업시행자가 기본적인 생활시설이 포함된 택지조성, 주택건설 공급, 인근 산업단지 공장에 입주 등을 하게 하는 생활보상을 의미한다.

II. 이주대책의 이론적 근거

원상회복, 생활보장, 생활안정, 감정존중 등의 근거를 들 수 있고, 판례는 이주자들에 대하여 종전의 생활 상태를 원상으로 회복시키는 동시에 인간다운 생활을 보장하여 주기 위한 생활보상의 일환으로 국가의 적극적이고 정책적인 배려라고 하였다.

III. 이주대책의 헌법적 근거

1. 문제점

생활보상이 정당보상의 범위에 포함되는가와 관련하여 헌법적 근거에 대하여 견해가 나뉘고 있다.

2. 학설

<헌법 34조 생존권설> 정당보상은 재산권의 객관적 가치를 지향하는바, 이주대책은 이에 포함되지 않아 사회권적 기본권 조항에서 도출된다고 한다. <제34조 및 제23조 통일설> 우리나라는 재산권보상을 대전제로 생활보상을 지향하는바, 헌법 제23조의 정당보상은 손실보상이 복리 국가적 관점에서 생활보상을 지향한다는 점을 근거로 한다.

3. 판례 및 검토

<헌법재판소>는 이주대책은 생활보호 차원에서 실시하는 시혜적 조치로서 헌법 제23조 제3항에 해당하지 않는다고 하였고, <대법원>은 인간다운 생활을 보장하기 위한 국가의 정책적 배려라고 하여 제34조설을 취하고 있다. <검토> 종전 생활을 회복시키는 불가결한 점을 고려하여 생활보상 역시 정당보상의 범위에 포함시키는 <통일설>이 타당하다.

<물음2>20

I. 논점의 정리

甲이 토지보상법상 이주대책대상자에 해당하는지, A이주대책기준의 대외적 구속력이 있는지, 수분양권 발생시기 등에 대한 판례 등을 검토하여 사안을 해결한다.

II. 甲이 이주대책 대상자인지

1. 토지보상법 요건

토지보상법 78조 1항 및 동법 시행령 40조 5항에 따르면, 이주대책 대상자는 주거용 건축물을 제공함에 따라 생활의 근거를 상실한 주거용 건축물의 소유자가 대상이다. 다만, ①무허가 건축물 등 소유자, ②관계법령에 따른 고시 등이 있는 날부터 계약체결일 또는 수용재결일까지 계속하여 거주하고 있지 아니한 자, ③타인소유 건축물의 세입자(다만, 해당 공익사업지구내 주거용 건축물을 소유한 자로서 타인소유 건축물에 거주하는 세입자는 제외)는 이주대책에서 제외한다.

2. A시의 이주대책 대상자 규정의 법적성질

1) 관련 판례

판례는 사업시행자의 이주대책 대상자를 정한 예규는 이주대책에 관한 행정기관 내부의 사무처리준칙을 정한 것에 불과하고, 대외적으로 국민이나 법원을 구속하는 효력이 없다고 보았으나, 사업시행자는 이주대책내용에 대해 재량을 가지므로, 그 기준이 객관적으로 합리적이지 않거나 타당하지 않다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 존중되어야 하며, 사업시행자의 이주대책기준이 규정한 전세대원의 사업구역 내 주택 외 무주택이라는 요건을 이주대책대상자 해당 여부를 결정하는 추가적인 요건으로 해석하여 이를 들어 대상자에서 제외시킬 수는 없다고 보았고, 사업시행자가 이주대책 대상자의 범위를 확대 수립·실시는 가능하나 반대로 범위 축소는 할 수 없다고 판시하였다.

2) A시 기준의 객관적 합리성·타당성 여부

공익사업의 시행으로 생활의 근거를 상실한 자에게 행하는 생활보상의 일환인 이주대책의 입법취지 및 목적을 고려할 때, 이주대책 대상자 요건을 정한 토지보상법 78조 1항 규정은 강행규정으로 봄이 타당하다. 따라서 이외 추가적 조건을 두는 것은 법적으로 타당하지 않다. 또한, 토지보상법은 보상에 합의하고 자진 이주한 경우만 공급을 하겠다는 취지의 규정을 두고 있지 않으며, 위 내용은 합리적이지도 타당하지도 않다.

3. 甲이 이주대책 대상자인지

甲은 토지보상법령에서 정한 요건을 충족하므로, 甲은 이주대책 대상자로 봄이 타당하다.

Ⅲ. 甲에게 수분양권이 있는지

1. 학설

①토지보상법 78조 및 동법 시행령 40조 요건을 충족하는 때에 실체적 권리인 수분양권이 발생한다는 <이주대책계획수립이전시설> ②토지보상법 규정에 의한 추상적·포괄적 권리가 사업시행자가 이주대책을 수립·실시한 때 구체적 권리인 수분양권으로 발생한다는 <이주대책계획수립시설>, ③이주대책 수립 이후 사업시행자의 확인·결정 시 수분양권이 발생한다는 <확인·결정시설>이 대립한다.

2. 판례

대법원 전원합의체 <다수의견>은 확인·결정시에 발생한다는 입장을 취하고 있으나, <반대의견>은 이주대책계획수립이전시설 입장이다. <반대보충의견>은 이주대책계획수립시설을 취하고 있다.

3. 검토 및 사안의 경우

이주자가 토지보상법 요건을 충족할 때는 이주대책대상자로서 지위를 가질 뿐 실체적 수분양권이 존재한다고 보기는 어렵다. 이주대책기준이 수립되면 추상적 권리가 구체적 권리로 전환된다고 볼 수 있으므로, 이주대책계획수립시설이 타당하다. 따라서 甲은 이주대책수립시에 수분양권을 취득하였다.

Ⅳ. 사례 해결

甲은 이주대책 대상자에 해당하고, 이주대책 수립에 따라 분양아파트 공급 또는 이주정착금 지급을 요구할 수 있는 구체적인 수분양권을 가지므로, 이를 요구할 수 있다.

<물음3>20

I. 논점의 정리

乙이 토지보상법상 이주대책 대상자인지, A시의 이주대책대상자 제외행위에 대한 乙의 소송방법으로서 취소소송과 당사자소송 가능성을 검토한다.

Ⅱ. 乙의 이주대책 대상자 여부

토지보상법 시행령 40조 3항은 무허가건축물 소유자를 이주대책대상자에서 제외하나, 시행령 부칙 6조에서는 1989.1.24. 현재 무허가건축물 소유자는 이에 불구하고 이주대상

자에 포함한다고 규정한다. 또한 무허가건축물대장의 등록이라는 요건 부분은 대외적 구속력이 없고, 이주대책 대상자 요건을 부당히 제한하는 것으로 강행규정인 토지보상법 78조 1항에 위배되므로, 乙은 이주대책 대상자에 해당한다.

Ⅲ. 乙의 권리구제를 위한 소송방법

1. 제외행위에 대한 취소소송

1) 확인·결정행위 법적성질

사업시행자의 이주대책대상자 확인·결정행위는 수분양권 발생에 대한 어떤 학설을 취하더라도 이주대책 대상자의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 행정쟁송법상 처분이다. <판례>역시 사업시행자가 행하는 행정작용으로서 공법상 처분에 해당하는 것으로 판시하였다. 계획수립시설에 따르면, 확인·결정행위는 수분양권을 확인해주는 기속행위에 해당한다.

2) 제외행위의 법적성질

토지보상법 및 이주대책 내용상 이주대책대상자에게는 분양신청권이 인정되고, 확인·결정행위는 처분으로서 공권력행사이다. 따라서 공권력행사의 거부로서 제외행위는 이주대책대상자의 권리·의무에 직접 영향을 미치는바, 항고소송의 대상이 되는 처분에 해당한다.

3) 제외행위의 위법성 및 그 정도

취소소송의 소적법성이 인정되는 것을 전제로 위법성을 검토한다. 乙의 건축물은 89.1.24 이전의 무허가건축물로서 토지보상법 시행규칙 부칙 5조에 의거 적법건축물로 보므로 乙은 이주대책대상자에 해당한다. 따라서, 乙이 이주대책대상자에 해당함에도 제외한 확인·결정행위는 토지보상법 78조 1항의 위반으로 위법하며, 그 하자의 정도는 중대하기는 하나 일반이 보기에 명백하다고 판단하기는 어려우나, 취소사유에 해당한다.

4) 사안의 경우

乙은 A시가 이주대책에서 乙을 제외시킨 행위에 대하여 항고소송 중 소송요건을 갖추어 취소소송을 제기할 수 있고, 제외행위에 취소사유가 존재하므로, 인용 받을 가능성이 있다.

2. 수분양권 확인의 당사자 소송

1) 수분양권이 공법상 권리인지

수분양권은 토지보상법인 공법에 근거하여 발생하는 권리인바, 공법상 권리로 보는 것이 타당하다. 대법원 역시 이주대책의 수립 및 집행은 공행정사무로 보아 수분양권을 공권으로 판시한바 있다.

2) 사안의 경우

乙은 토지보상법상 이주대책대상자로서, 이주대책계획수립시설에 따를 때, 수분양권을 취득하였다. 乙에 입장에서는 확인·결정 제외행위를 다투는 것이 가장 권리구제에 유리하다. 그러나 사업시행자에게 거부당할 것이 명백한 경우, 기타 확인판결로 권리구제가 가능한 경우 당사자소송으로 수분양권자의 지위 확인을 구할 수 있을 것이다.

<간접손실보상>

02. X군에 거주하는 어업인들을 조합원으로 하는 A수산업협동조합(이하 'A조합'이라 함)은 조합원들이 포획·채취한 수산물의 판매를 위탁받아 판매하는 B수산물 위탁판매장(이하 'B위탁판매장'이라 함)을 운영하여 왔다. 한편, B위탁판매장 운영에 대해서는 관계 법령에 따라 관할 지역에 대한 독점적 지위가 부여되어 있었으며, A조합은 B위탁판매장 판매액 중 일정비율의 수수료를 지급받아 왔다. 그런데, 한국농어촌공사는「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따라 X군 일대에 대한 공유수면매립면허를 받아 공유수면매립사업을 시행하였고, 해당 매립사업의 시행으로 인하여 사업대상지역에서 어업활동을 하던 A조합의 조합원들은 더 이상 조업을 할 수 없게 되었다. A조합은 위 공유수면매립사업지역 밖에서 운영하던 B위탁판매장에서의 위탁판매사업의 대부분을 중단하였고, 결국에는 B위탁판매장을 폐쇄하기에 이르렀다. 이에 따라 A조합은 공유수면매립사업으로 인한 위탁판매수수료 수입의 감소에 따른 영업손실의 보상을 청구하였으나, 한국농어촌공사는 B위탁판매장이 사업시행지 밖에서 운영되던 시설이었고「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」상 직접적인 보상 규정이 없음을 이유로 보상의 대상이 아니라고 주장한다. 한국농어촌공사의 주장은 타당한가? (20점) [기출 30회 3]

목차

I. 논점의 정리

II. 간접손실의 의의 및 취지

III. 간접손실의 요건

1. 일반적 요건
2. 특별한 희생
3. 보상규정의 존재

IV. 보상규정 흠결 시 간접보상 가능성

1. 학설
2. 판례
3. 검토 및 사안의 경우

V. 한국농어촌공사의 주장 타당성

I. 논점의 정리

간접손실보상의 요건 및 직접적인 손실보상 규정이 없는 경우 손실보상 가능성 등을 검토하여 사례를 해결한다.

II. 간접손실의 의의 및 취지

간접손실이란 공익사업으로 인해 해당 공익사업시행지구 밖의 재산권자에게 필연적으로 발생하는 재산상의 손실을 말한다. 간접손실은 공익사업의 시공 또는 완성 후의 시설이 사업시행지구 외에 미치는 손실이다. 손실의 발생은 직접 또는 간접적으로 발생할 수 있고, 손실은 재산가액의 감소는 물론 생활피해, 정신적 피해 등을 막론한다.

III. 간접손실의 요건

1. 일반적 요건

①공익사업의 시행에 수반된 사업지구 밖의 제3자가 입은 손실이 존재할 것, ②공익사업의 시행으로 손실이 발생하리라는 것을 예견할 수 있고, 그 손실의 범위도 구체적으로 특정할 수 있을 것이 요구된다. 더불어 특별한 희생, 보상규정의 존재라는 헌법 제23조 제3항의 손실보상의 일반적 요건도 필요하다.

2. 특별한 희생

특별한 희생은 피해인의 특정가능성, 침해의 범위, 재산권의 보호가치, 수인한도, 사적효용, 구체적 상황 등을 종합적으로, 즉 형식적, 실질적 기준설 모두 고려하여 판단하는 것이 타당하다. 사안은 손실이 특정가능하고 영업상 큰 손실로 폐업에 이르는 수인하기 어려운 재산권의 피해이므로, 특별한 희생에 해당한다.

3. 보상규정의 존재

직접적인 손실보상 규정이 없는 경우 토지보상법 제79조 제4항이 간접손실의 일반 보상규정으로 볼 수 있는지 견해가 대립된다. 일반근거조항설은 동법 제79조 제4항의 입법취지를 지나치게 확장한다는 점에서 개괄수권조항설이 타당하며, 위 규정을 직접적인 근거로 간접손실보상은 불가능하다. 이하에서 보상규정 결여 시 보상청구 가능한지 살펴본다.

IV. 보상규정 흠결 시 간접보상 가능성

1. 학설

명문의 근거 없는 손실은 보상의 대상이 되지 않는다는 견해와 손실보상을 긍정하되 그 근거에 대하여 ①헌법 23조3항 및 '토지보상법'상 간접손실보상을 유추적용하는 견해 ②헌법 23조 3항을 직접적용하는 견해 ③헌법 11조의 평등원칙 및 23조 1항을 직접적용하는 견해 ④수용적침해이론을 적용하는 견해 ⑤손실보상이 아닌 손해배상을 청구하여야 한다는 견해가 대립한다.

2. 판례

대법원은 ①공익사업지구 밖의 토지 등 소유자가 입은 손실에 대하여 ②손실발생을 예견할 수 있고, ③손실의 범위가 특정될 수 있으며 ④손실이 특별한 희생에 해당하는 경우에는 손실보상에 관하여 토지보상법상 관련규정들을 유추적용할 수 있다고 판시하였다.

3. 검토 및 사안의 경우

국민의 권익 보호 관점 및 헌법 23조 3항의 정당한 보상 규정 취지를 고려할 때, 손실보상의 범주에는 간접손실 보상도 당연히 포함되며 관련 규정을 유추적용하여 손실보상을 할 수 있다고 봄이 타당하다.

V. 한국농어촌공사의 주장 타당성

손실의 발생이 예견가능성이 있었고, 손실의 범위도 구체적으로 특정할 수 있으므로, 판례의 입장에 따라 토지보상법 시행규칙 64조 등을 유추적용할 수 있다고 봄이 타당하다. 따라서 한국농어촌공사의 주장은 타당하지 않다.

03. 공공사업의 시행으로 인하여 공공사업지구 밖에서 발생한 피해에 대한 보상의 이론적 근거, 실제유형과 보상의 한계에 대해 논술하시오. (20점)[11회 3]

목차
I. 개설
II. 간접손실보상의 의의 및 취지
III. 간접손실보상의 이론적 근거
IV. 간접손실보상의 실제 유형
1. 간접손실의 실제유형
2. 토지보상법상 간접손실보상의 유형
V. 간접손실 보상의 한계

I. 개설

공익사업으로 인하여 사업시행지 밖의 재산권자에게 가해지는 손실 중 공익사업으로 인하여 필연적으로 발생하는 손실이 간접손실이다. 간접손실은 공익사업의 시공 또는 완성 후의 시설이 사업시행지구 외에 미치는 손실이다. 손실의 발생은 직접 또는 간접적으로 발생할 수 있고, 손실은 재산가액의 감소는 물론 생활피해, 정신적 피해 등을 막론한다.

II. 간접손실보상의 의의

간접손실이란 공익사업으로 인해 해당 공익사업시행지구 밖의 재산권자에게 필연적으로 발생하는 재산상의 손실을 말한다. 실정법인 토지보상법은 '공익사업시행지구 밖의 토지 등의 보상'으로 규정하고 있다.

III. 간접손실보상의 이론적 근거

간접손실보상의 이론적 근거는 생활권보상에서 찾을 수 있다. 첫째, 공익사업이 시행됨으로 인하여 생활의 기반을 상실하게 될 때 종전과 같은 생활을 영위할 수 없는 것은

말할 것도 없고, 인간다운 생활을 유지할 수 없게 되는 경우도 있을 수 있다. 생활보상이 피수용자나 관계인의 인간다운 생활을 회복시켜 주기 위한 것이라면 간접손실도 마땅히 인간다운 생활을 보장하기 위해 보상되어야 하는 것이다. 둘째, 생활보상이 수용이 없었던 것과 같은 생활상태를 재현하는 것이라는 것을 전제하고 있다. 셋째, 종래와 같은 수준을 유지할 수 있을 정도의 생활안정을 위해 간접손실보상이 이루어져야 한다. 넷째, 생활보상은 지역 주민의 갈등을 해소하고, 사업의 원활한 시행에 협조를 구하는 수단이 될 수 있으므로, 이는 간접손실보상에도 타당한 것이므로 공익사업의 원활화를 위해 필요하다.

IV. 간접손실보상의 실제 유형

1. 간접손실의 실제유형

일반적으로 물리적·기술적 손실과 사회적·경제적 손실로 구분한다. 또한 공익사업의 시행시 발생하는 피해와 사업이 완료된 후 발생하는 피해로 구분할 수 있다. 사업시행시 발생하는 피해는 사업 과정 중의 소음·진동·먼지 등으로 인한 피해이고, 사업 완료 후 발생하는 손실은 토지와 건물의 경우 지가하락, 지반변동, 주거 및 생활의 불편, 영업 등의 영위 곤란, 전파수신장애, 지하수고갈, 소음·진동 등이 있다.

2. 토지보상법상 간접손실보상의 유형

토지보상법 79조 1항에서는 공익사업으로 인한 사업시행지구 밖의 토지에 통로, 도랑, 담장 등의 신설 그 밖의 공사가 필요한 경우 공사비 보상을 규정하고 있다. 동법 79조 2항 및 시행규칙 59조 내지 65조에서는 공익사업시행지구 밖의 대지, 건축물, 공작물 등에 대하여 손실보상 규정을 마련해두고 있다.

V. 간접손실 보상의 한계

종래 간접보상은 댐건설사업의 경우를 중심으로 규정을 두었으나, 지극히 제한적이었고, 현재 대규모 공익사업의 주변 지역에서는 피해의 양상이 다양하게 나타나고 있다. 이러한 손실에 대한 보상 확대가 당면 과제로 되고 있으나, 손실보상이 수용 손실의 보상을 중심으로 하고 있고, 일조 등에 의한 피해는 손해의 범위를 정하기 어렵고, 보상액이 과다하다는 한계를 지니고 있다. 이러한 점을 고려할 때 사업계획단계에서 간접손실의 발생을 미연에 방지하기 위한 조치의 강구가 요구된다. 수인 범위를 넘는 손실의 발생이 예측되는 경우 계획 및 공법 변경의 검토나 손실 발생이 명백한 경우 사전 보상조치의 강구가 필요하다. 그리고 사업과정에서 수인 범위를 넘는 피해가 발생할 때 응급조치를 강구하고 손해나 영향의 최소화를 위해 노력해야 할 것이다.

04. A도 도지사 甲은 도내의 심각한 주차난을 해결하기 위하여 A도내 B시 일대 40,000 m²(이하 '이 사건 공익사업구역'이라 함)를 공영주차장으로 사용하고자 사업계획을 수립하고 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '토지보상법'이라 함)에 따른 절차를 거쳐, 국토교통부장관의 사업인정을 받고 이를 고시하였다. 丙은 이 사건 공익사업구역 밖에서 음식점을 경영하고 있었는데, 이 사건 공익사업으로 인하여 자신의 음식점의 주출입로가 단절되어 일정 기간 휴업을 할 수 밖에 없게 되었다. 이때, 丙은 토지보상법령상 보상을 받을 수 있는가? (10점) [기출 29회 1-2]

목차
I. 논점의 정리
II. 간접손실보상의 의의
III. 관련규정 검토 (시행규칙 제64조)
IV. 간접손실보상의 요건
1. 일반적 요건
2. 특별한 희생
3. 보상규정의 존재
V. 소결

I. 논점의 정리

사안은 사업구역 밖의 손실보상, 즉 간접손실보상 문제로 토지보상법 시행규칙 64조에 따라 보상을 받을 수 있는지 검토한다.

II. 간접손실보상의 의의

간접손실이란 공익사업으로 인해 해당 공익사업시행지구 밖의 재산권자에게 필연적으로 발생하는 재산상의 손실을 말한다. 간접손실은 공익사업의 시공 또는 완성 후의 시설이 사업시행지구 외에 미치는 손실이다. 손실의 발생은 직접 또는 간접적으로 발생할 수

있고, 손실은 재산가액의 감소는 물론 생활피해, 정신적 피해 등을 막론한다.

III. 관련규정 검토 (시행규칙 제64조)

공익사업시행지구 밖에서 영업손실의 보상대상이 되는 영업을 하고 있는 자가 공익사업의 시행으로 인하여 ① 배후지의 3분의 2 이상이 상실되어 그 장소에서 영업을 계속할 수 없는 경우 또는 ② 진출입로의 단절, 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 일정한 기간 동안 휴업하는 것이 불가피한 경우의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 영업자의 청구에 의하여 당해 영업을 공익사업시행지구내 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다.

IV. 간접손실보상의 요건

1. 일반적 요건

①공익사업의 시행에 수반된 사업지구 밖의 제3자가 입은 손실이 존재할 것, ②공익사업의 시행으로 손실이 발생하리라는 것을 예견할 수 있고, 그 손실의 범위도 구체적으로 특정할 수 있을 것이 요구된다. 더불어 특별한 희생, 보상규정의 존재라는 손실보상의 일반적 요건도 필요하다.

2. 특별한 희생

특별한 희생은 피해인의 특정가능성, 침해의 범위, 재산권의 보호가치, 수인하도, 사적효용, 구체적 상황 등을 종합적으로, 즉 형식적, 실질적 기준설 모두 고려하여 판단하는 것이 타당하다. 사안은 손실은 특정가능하고 영업상 큰 손실로 폐업에 이르는 수인하기 어려운 재산권의 피해이므로, 특별한 희생에 해당한다.

3. 보상규정의 존재

토지보상법 시행규칙 64조에서는 배후지 2/3이상 상실 또는 진출입로의 단절 등으로 영업을 계속할 수 없는 경우를 영업손실보상 요건으로 정하고 있다. 사안에서 진출입로 단절은 위 규정 요건에 해당하므로, 보상규정이 존재한다고 볼 수 있다.

V. 소결

丙은 토지보상법 79조 2항, 시행규칙 64조 1항 2호(진출입로의 단절 부분)를 준용하여 손실보상을 받을 수 있다.

대법원 1994. 5. 24. 선고 92다35783 전원합의체 판결 판시사항 가. 공공용지의취득및손실보상에관한특례법 소정의 이주대책의 제도적 취지 나. 같은 법 제8조 제1항에 의하여 이주자에게 이주대책상의 택지분양권이나 아파트 입주권 등을 받을 수 있는 구체적인 권리(수분양권)가 직접 발생하는지 여부 다. 이주자의 이주대책대상자 선정신청에 대한 사업시행자의 확인·결정 및 사업시행자의 이주대책에 관한 처분의 법적 성질과 이에 대한 쟁송방법 라. 같은 법상의 이주대책에 의한 수분양권의 법적 성질과 민사소송이나 공법상 당사자소송으로 이주대책상의 수분양권의 확인을 구할 수 있는지 여부	판결요지 [다수의견] 가. 공공용지의취득및손실보상에관한특례법상의 이주대책은 공공사업의 시행에 필요한 토지 등을 제공함으로 인하여 생활의 근거를 상실하게 되는 이주자들을 위하여 사업시행자가 기본적인 생활 시설이 포함된 택지를 조성하거나 그 지상에 주택을 건설하여 이주자들에게 이를 그 투입비용 원가만의 부담하에 개별 공급하는 것으로서, 그 본래의 취지에 있어 이주자들에 대하여 종전의 생활상태를 원상으로 회복시키면서 동시에 인간다운 생활을 보장하여 주기 위한 이른바 생활보상의 일환으로 국가의 적극적이고 정책적인 배려에 의하여 마련된 제도이다. 나. 같은 법 제8조 제1항이 사업시행자에게 이주대책의 수립·실시의무를 부과하고 있다고 하여 그 규정 자체만에 의하여 이주자에게 사업시행자가 수립한 이주대책상의 택지분양권이나 아파트 입주권 등을 받을 수 있는 구체적인 권리(수분양권)가 직접 발생하는 것이라고는 도저히 볼 수 없으며, 사업시행자가 이주대책에 관한 구체적인 계획을 수립하여 이를 해당자에게 통지 내지 공고한 후, 이주자가 수분양권을 취득하기를 희망하여 이주대책에 정한 절차에 따라 사업시행자에게 이주대책대상자 선정신청을 하고 사업시행자가 이를 받아들여 이주대책대상자로 확인·결정하여야만 비로소 구체적인 수분양권이 발생하게 된다. 다. (1) 위와 같은 사업시행자가 하는 확인·결정은 곧 구체적인 이주대책상의 수분양권을 취득하기 위한 요건이 되는 행정작용으로서의 처분인 것이지, 결코 이를 단순히 절차상의 필요에 따른 사실행위에 불과한 것으로 평가할 수는 없다. 따라서 수분양권의 취득을 희망하는 이주자가 소정의 절차에 따라 이주대책대상자 선정신청을 한 데 대하여 사업시행자가 이주대책대상자가 아니라고 하여 위 확인·결정 등의 처분을 하지 않고 이를 제외시키거나 또는 거부조치한 경우에는, 이주자로서는 당연히 사업시행자를 상대로 항고소송에 의하여 그 제외처분 또는 거부처분의 취소를 구할 수 있다고 보아야 한다. (2) 사업시행자가 국가 또는 지방자치단체와 같은 행정기관이 아니고 이와는 독립하여 법률에 의
---	--

하여 특수한 존립목적을 부여받아 국가의 특별감독하에 그 존립목적인 공공사무를 행하는 공법인 이 관계법령에 따라 공공사업을 시행하면서 그에 따른 이주대책을 실시하는 경우에도, 그 이주대책에 관한 처분은 법률상 부여받은 행정작용권한을 행사하는 것으로서 항고소송의 대상이 되는 공법상 처분이 되므로, 그 처분이 위법부당한 것이라면 사업시행자인 당해 공법인을 상대로 그 취소소송을 제기할 수 있다.	라. 이러한 수분양권은 위와 같이 이주자가 이주대책을 수립·실시하는 사업시행자로부터 이주대책대상자로 확인·결정을 받음으로써 취득하게 되는 택지나 아파트 등을 분양받을 수 있는 공법상의 권리라고 할 것이므로, 이주자가 사업시행자에 대한 이주대책대상자 선정신청 및 이에 따른 확인·결정 등 절차를 밟지 아니하여 구체적인 수분양권을 아직 취득하지도 못한 상태에서 곧바로 분양 의무의 주체를 상대방으로 하여 민사소송이나 공법상 당사자소송으로 이주대책상의 수분양권의 확인 등을 구하는 것은 허용될 수 없고, 나아가 그 공급대상인 택지나 아파트 등의 특정부분에 관하여 그 수분양권의 확인을 소구하는 것은 더더욱 불가능하다고 보아야 한다.
[반대의견]	가. 공공용지의취득및손실보상에관한특례법에 의한 이주대책은 학설상 이른바 생활보상으로서 실체적 권리인 손실보상의 한 형태로 파악되고 있으며 대법원 판례도 이를 실체법상의 권리로 인정하여, 민사소송으로 이주대책에 의한 주택수분양권의 확인소송을 허용하였었다. 이주대책은 경우에 따라 택지 또는 주택의 분양이나 이주정착금으로 보상되는바, 이주정착금이 손실보상금의 일종이므로 통상의 각종 보상금처럼 실체적 권리가 되는 것을 부정할 수 없을 것이고, 그렇다면 같은 취지의 택지 또는 주택의 수분양권도 실체적인 권리로 봄이 마땅하며 / 가사 이를 권리로 보지 못한다 하더라도 적어도 확인소송의 대상이 되는 권리관계 또는 법률관계로는 보아야 한다. 나. 이주자가 분양신청을 하여 사업시행자로부터 분양처분을 받은 경우 이러한 사업시행자의 분양처분의 성질은 이주자에게 수분양권을 비로소 부여하는 처분이 아니라, 이미 이주자가 취득하고 있는 수분양권에 대하여 그의 의무를 이행한 일련의 이행처분에 불과하고, 이는 이주자가 이미 취득하고 있는 수분양권을 구체화 시켜주는 과정에 불과하다. 이를 실체적 권리로 인정해야 구체적 이주대책 이행을 신청하고 그 이행이 없을 때 부작위위법확인소송을 제기하여 그 권리구제를 받을 수 있고, 그 권리를 포기한 것으로 볼 수 없는 한 언제나 신청이 가능하고 구체적 이주대책이 종료한 경우에도 추가 이주대책을 요구할 수 있게 된다. 다. 이와 같이 이주대책에 의한 분양신청은 실체적 권리의 행사에 해당된다 할 것이므로 구체적 이주대책에서 제외된 이주대책대상자는 그 경위에 따라 분양신청을 하여 거부당한 경우 권리침해를 이유로 항고소송을 하거나 또는 자기 몫이 참칭 이주대책대상자에게 이미 분양되어 다시 분양신청을 하더라도 거부당할 것이 명백한 특수한 경우 등에는 이주대책대상자로서 분양받을 권리

또는 그 법률상 지위의 확인을 구할 수 있다고 보아야 하며, 이때에 확인소송은 확인소송의 보충성이라는 소송법의 일반법리에 따라 그 확인소송이 권리구제에 유효 적절한 수단이 될 때에 한하여 그 소의 이익이 허용되어야 함은 물론이다.

[반대의견에 대한 보충의견]

가. 공공용지의취득및손실보상에관한특례법 제8조 제1항의 이주대책은 사업시행자가 이주자에 대한 은혜적인 배려에서 임의적으로 수립 시행해 주는 것이 아니라 이주자에 대하여 종전의 재산상태가 아닌 생활상태로 원상회복시켜 주기 위한 생활보상의 일환으로 마련된 제도로서, 헌법 제23조 제3항이 규정하는 손실보상의 한 형태라고 보아야 한다.

나. (1) 같은 법상의 이주대책에 따른 사업시행자의 분양처분은 이주자가 공공사업의 시행에 필요한 토지 등을 제공하는 것을 원인으로 하여 같은 법에 따라 취득한 추상적인 권리나 이익을 이주대책을 수립하여 구체화시켜 주는 절차상의 이행적 처분이라고 보는 것이 상당하며, 이주자는 사업시행자가 수립 실시하여야 하는 이주대책에 따른 수분양권을 사업시행자의 분양처분을 기다리지 않고 같은 법에 근거하여 취득하는 것으로 보아야 한다.

(2) 사업시행자가 실제로 이주대책을 수립하기 이전에는 이주자의 수분양권은 아직 추상적인 권리나 법률상의 지위 내지 이익에 불과한 것이어서 이 단계에 있어서는 확인의 이익이 인정되지 아니하여 그 권리나 지위의 확인을 구할 수 없다고 할 것이나, 사업시행자가 이주대책을 수립 실시하지 아니하는 경우에는 사업시행자에게 이를 청구하여 거부되거나 방치되면 부작위위법확인을 소구할 수는 있다고 볼 것이다. 그러나 이주대책을 수립한 이후에는 이주자의 추상적인 수분양권이 그 이주대책이 정하는 바에 따라 구체적 권리로 바뀌게 되므로, 구체적 이주대책에서 제외된 이주자는 위와 같은 수분양권에 터잡은 분양신청(이른바 실체적 신청권의 행사)을 하여 거부당한 경우에는 이를 실체적 신청권을 침해하는 거부처분으로 보아 그 취소를 구하는 항고소송을 제기할 수 있을 것이고, 신청기간을 도과한 경우, 사업시행자가 미리 수분양권을 부정하거나 이주대책에 따른 분양절차가 종료되어 분양신청을 하더라도 거부당할 것이 명백한 경우, 또는 분양신청을 묵살당한 경우, 기타 확인판결을 얻음으로써 분쟁이 해결되고 권리구제가 가능하여 그 확인소송이 권리구제에 유효 적절한 수단이 될 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에는, 당사자소송으로 수분양권 또는 그 법률상의 지위의 확인을 구할 수 있다고 보아야 한다.

다. 현행 행정소송법은 항고소송과 당사자소송의 형태를 모두 규정하고 있으므로, 이제는 공법상의 권리관계의 분쟁에 있어서는 그 권리구제의 방법에 관하여 항고소송만에 의하도록 예정한 산업재해보상보험업무및심사에관한법률 제3조와 같은 규정이 있는 경우를 제외하고는, 소의 이익이 없는 등 특별한 사정이 없는 한 항고소송 외에 당사자소송도 허용하여야 할 것이고, 불필요하게 국민의 권리구제방법을 제한할 것은 아니다.

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 개별법 기본강의 9회

<주거이전비>

01. X는 도시 및 주거환경정비법 (이하 '도시정비법'이라 함)에 따른 재개발정비사업조합이고, 甲은 X의 조합원으로서, 해당 정비사업구역 내에 있는 A토지와 B토지의 소유자이다. A토지와 B토지는 연접하고 있고 그 지목이 모두 대(地)에 해당하지만, A토지는 사도법에 따른 사도가 아닌데도 불특정 다수인의 통행에 장기간 제공되어 왔고, B토지는 甲이 소유한 건축물의 부지로서 그 건축물의 일부에 임차인 乙이 거주하고 있다. X는 도시정비법 제72조 제1항에 따라 분양신청기간을 공고하였으나 甲은 그 기간 내에 분양신청을 하지 않았다. 이에 따라 X는 甲을 분양대상자에서 제외하고 관리처분계획을 수립하여 인가를 받았고, 그에 불복하는 행정심판이나 행정소송은 없었다. X는 도시정비법 제73조 제1항에 따른 甲과의 보상협의를 이루어지지 않자 A토지와 B토지에 관하여 관할 토지수용위원회에 수용재결을 신청하였고, 관할 토지수용위원회는 A토지와 B토지를 수용한다는 내용의 수용재결을 하였다. 주거이전비에 관하여 甲은 토지보상법 시행규칙 제54조 제1항에 따른 요건을 갖추고 있고, 乙은 같은 조 제2항에 따른 요건을 갖추고 있다. 관할토지수용위원회는 수용재결을 하면서 甲의 주거이전비에 관하여는 재결을 하였으나 乙의 주거이전비에 관하여는 재결을 하지 않았다. 甲은 주거이전비의 증액을 청구하고자 하고, 乙은 주거이전비의 지급을 청구하고자 한다. 甲과 乙의 권리구제에 적합한 소송을 설명하시오. (20점) [기출33회1-3]

목차

I. 논점의 정리

II. 주거이전비의 의의 및 취지, 근거

III. 주거이전비 지급청구권의 법적성질

IV. 권리구제에 관한 대법원 판례

V. 甲이 할 수 있는 소송방법

VI. 乙이 할 수 있는 소송방법

I. 논점의 정리

주거이전비에 대해 검토하고, 주거이전비의 법적성질과 관련 판례법리에 기초하여 사안을 해결한다.

II. 주거이전비의 의의 및 취지, 근거

주거이전비 보상은 재산권에 대한 대물보상과는 달리 생활권보상의 일종에 해당하는 것으로서 공익사업의 시행으로 생활 근거를 상실하게 되는 자를 위하여 종전의 생활상태를 원상으로 회복시키면서 동시에 인간다운 생활을 보장하여 주기 위한 이른바 생활보상의 일환으로 국가의 정책적 배려에 의해 마련된 제도이다. 소유자는 토지보상법 시행규칙 54조 1항에, 세입자는 같은 조 2항에 근거를 둔다.

III. 주거이전비 지급청구권의 법적성질

주거이전비 지급청구권이 공권인지, 사권인지 문제되며 그에 따라 관할 법원과 적용법을 등이 결정된다. 판례는 주거이전비 보상청구권이 공법상 권리라고 하여 그 보상을 둘러싼 쟁송은 민사소송이 아니라 행정소송에 의하여야 한다고 본다.

IV. 권리구제에 관한 대법원 판례

주거이전비 보상청구권은 그 요건을 충족하는 경우 당연히 발생하는 것이므로, 주거이전비 보상청구 소송은 행정소송법 3조 2호에 규정된 당사자소송에 의하여야 한다. 다만 세입자의 주거이전비 보상에 관하여 재결이 이루어진 다음 세입자가 보상금의 증감 부분을 다투는 경우에는 토지보상법 85조 2항에 규정된 행정소송에 따라, 보상금의 증감 이외의 부분을 다투는 경우에는 같은 조 1항에 규정된 행정소송에 따라 권리구제를 받

을 수 있다. 그리고 이러한 법리는 주거용 건축물의 소유자가 사업시행자를 상대로 이주정착금, 주거이전비 및 이사비의 보상을 구하는 경우에도 그대로 적용된다.

V. 甲이 할 수 있는 소송방법

甲의 주거이전비에 대한 수용재결이 있었으므로, 토지보상법 85조 2항의 보상금증감청구소송을 제기할 수 있다. 같은 법 83조 이의신청도 권리구제 수단으로 고려할 수 있다.

VI. 乙이 할 수 있는 소송방법

乙의 주거이전비에 대한 수용재결이 없었으므로, 乙은 공법상 당사자소송을 제기하여 사업시행자에게 주거이전비의 지급을 구할 수 있다.

02. A도 도지사 甲은 도내의 심각한 주차난을 해결하기 위하여 A도내 B시 일대 40,000 m²(이하 '이 사건 공익사업구역'이라 함)를 공영주차장으로 사용하고자 사업계획을 수립하고 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '토지보상법'이라 함)에 따른 절차를 거쳐, 국토교통부장관의 사업인정을 받고 이를 고시하였다. 이후 甲은 이 사건 공익사업구역 내 주택 세입자 乙등이 이 사건 공익사업이 시행되는 동안 임시로 거주할 수 있도록 B시에 임대아파트를 건립하여 세입자에게 제공하는 등 이주대책을 수립·시행하였다. 한편, 乙은 토지보상법 시행규칙 제54조 제2항에 해당하는 세입자이다. 乙은 토지보상법 시행규칙에 따른 주거이전비를 받을 수 있는 권리를 포기한다는 취지의 '임대아파트 입주에 따른 주거이전비 포기각서'를 甲에게 제출하고 위 임대아파트에 입주하였지만, 이후 관련 법령이 임대아파트와 같은 임시수용시설 등을 제공받는 자를 주거이전비 지급대상에서 배제하지 않고 있는 점을 알게 되었다. 이에 乙은 위 포기각서를 무시하고 토지보상법 시행규칙 상의 주거이전비를 청구하였다. 乙의 주거이전비 청구의 인용여부에 관하여 논하시오. (30점) [기출29회1-1]

목차

I. 논점의 정리

II. 주거이전비의 의의 및 취지

III. 주거이전비의 근거(토지보상법 78조 6항)

IV. 주거이전비 지급청구권의 법적성질

V. 乙의 주거이전비 청구 인용 여부

1. 요건 검토
2. 토지보상법 시행규칙 54조의 법적성질
3. 주거이전비 포기각서의 효력
4. 계속거주요건 여부
5. 소결

I. 논점의 정리

주거이전비에 대해 검토 후, 乙이 토지보상법 시행규칙 54조 2항에서 정한 요건을 갖추었는지, 포기각서의 효력 등을 검토하여 사례를 해결한다.

II. 주거이전비의 의의 및 취지

주거이전비란 당해 공익사업 시행지구 안에 거주하는 세입자들의 조기이주를 장려하여 사업추진을 원활하게 하려는 정책적인 목적과 주거이전으로 인하여 특별한 어려움을 겪게 될 주거용 건축물의 소유자나 세입자들을 대상으로 하는 사회보장적인 차원에서 지급하는 금원을 말한다. 생활보상의 성격을 가진다.

III. 주거이전비의 근거(토지보상법 78조 6항)

토지보상법 78조 6항은 주거용 건축물의 거주자에 대해 주거이전에 필요한 비용 등을 보상할 것을 규정하고, 시행규칙 54조 2항에서는 주거용 건축물 세입자에 대한 주거이전비 보상을 규정한다.

IV. 주거이전비 지급청구권의 법적성질

대등한 당사자 사이의 금전청구에 관한 법률관계로 사권이라는 견해, 공익사업이라는 공법상 원인행위로 발생한 공권이라는 견해가 있다. 판례는 사회보장적인 차원에서 지급하는 금원의 성격이라 하여 공법상 권리라 판시한 바 있다. 생각건대, 주거이전비는 공익사업이라는 공법상 원인으로 발생하였고, 사회보장적 차원의 금원으로 볼 수 있는 바, 공권설이 타당하다.

V. 乙의 주거이전비 청구 인용 여부

1. 요건 검토

토지보상법 시행규칙 54조 2항에 따르면, 세입자의 경우 사업인정고시일 등 당시 사업지구 내 3개월 이상 거주하여야 하며, 무허가건축물일 경우 1년 이상 거주하여야 한다. 사안의 경우 위 요건을 충족한 것으로 보인다. 다만, 포기각서가 유효한지 문제된다.

2. 토지보상법 시행규칙 54조의 법적성질

위 규정은 당사자의 합의 또는 사업시행자의 재량에 의해 적용을 배제할 수 없는 강행규정의 성격을 가진다. 판례 또한 같다.

3. 주거이전비 포기각서의 효력

토지보상법 시행규칙 54조는 강행규정이므로, 당사자는 합의로 배제할 수 없다. 乙이 '주거이전비 포기각서'를 甲에게 제출했다고 하더라도 이는 무효이며 당사자에게 구속력이 발생하지 않는다. 판례 또한 같다.

4. 계속거주요건 여부

세입자는 사업인정고시일 등 당시 공익사업지구 안에서 3월이상 거주한 자에 해당하면 그 이후 사업시행자의 주거이전비 산정통보일 또는 수용개시일까지 계속 거주할 것을 요함이 없이 사업인정고시일 등에 바로 주거이전비와 이사비 청구권을 취득한다. 따라서 계속거주요건은 필요하지 않다.

5. 소결

乙은 토지보상법 시행규칙 54조 2항의 요건을 갖추었고, 포기각서는 그 효력이 없으며, 세입자는 계속거주 요건이 필요 없으므로, 乙은 주거이전비 대상자이며, 乙의 청구는 인용될 것이다. 다만, 사업시행자가 거부할 경우 乙은 공법상 당사자가 소송을 제기할 수 있으며, 재결을 거친 경우라면, 토지보상법 85조 2항에 따른 보상금증액청구소송을 제기할 수 있다.

<표준지공시지가>

03.공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상 보상금 증액청구소송을 제기 하면서 해당 재결에 대한 선행처분으로서 수용대상 토지가격 산정의 기초가 된 표준지공시지가 결정이 위법함을 독립한 사유로 다룰 수 있는가에 관하여 논하시오. (10점) [기출24회 4번]

목차
I. 하자승계의 의의 및 취지
II. 하자승계의 전제 요건
III. 관련 판례
IV. 사안의 경우
1. 동일한 법률효과를 목적으로 하는지
2. 예측가능성 및 수인가능성의 검토
1) 예측가능성 충족여부
2) 수인가능성 충족여부
3. 결론

I. 하자승계의 의의 및 취지

하자승계란 둘 이상의 행정행위가 연속적으로 이루어지는 경우, 선행행위에 불가쟁력이 생겨 다룰 수 없는 경우에 후행행위를 다투면서 선행행위의 위법을 주장할 수 있는지의 문제이다. 이는 법적 안정성과 국민의 권리구제의 조화에 그 취지가 인정된다.

II. 하자승계의 전제 요건

① 선행 행정작용의 모두 처분에 해당하고 ② 선행 행정처분에 단순 취소사유의 위법이 존재하며 ③ 후행 행정처분 자체는 적법하고 ④ 선행 행정처분에 대한 불복기간이 도과하여 불가쟁력이 발생하여야 한다.

III. 관련 판례

판례는 전통적 견해에 따라 법률효과의 동일성 측면에서 하자승계를 인정하되, 예외적으로 국민의 예측가능성, 수인가능성을 고려하여 개별공시지가와 과세 처분 사이의 하자승계를 인정한 바 있고, 보상금증액 청구소송에서 수용재결의 선행처분이 표준지공시지가 결정의 위법함을 주장할 수 있다고 하였다.

IV. 사안의 경우

1. 동일한 법률효과를 목적으로 하는지

표준지공시지가 결정은 이를 기초로 한 수용재결 등과는 별개의 독립된 처분으로서 서로 독립하여 별개의 법률효과를 목적으로 한다.

2. 예측가능성 및 수인가능성의 검토

1) 예측가능성 충족여부

표준지공시지가는 이를 인근 토지의 소유자나 기타 이해관계인에게 개별적으로 고지하도록 되어 있는 것이 아니어서 인근 토지의 소유자 등에게 예측가능성이 인정되지 않는다.

2) 수인가능성 충족여부

① 표준지공시지가가 공시될 당시 보상금 산정의 기준이 되는 표준지의 인근 토지를 함께 공시하는 것이 아니어서 피수용자로 하여금 보상에 대비하여 항상 토지가격을 주시하도록 요구하는 것은 부당하게 높은 주의의무를 지우는 것이고, ② 위법한 표준지공시지가 결정에 대하여 시정요구가 없었다는 이유만으로 후행 행정처분에서 표준지공시지가결정의 위법을 주장할 수 없도록 하는 것은 수인가능성이 인정되지 않는다.

3. 결론

국민의 재산권과 재판받을 권리를 보장한 헌법의 이념에 비추어 표준지공시지가 결정이 위법한 경우에 수용보상금의 증액을 구하는 소송에서도 표준지공시지가 결정이 위법함을 독립한 사유로 주장할 수 있다고 판단된다.

<개별공시지가>

04. 甲은 A시에 토지를 소유하고 있다. A시장은 甲 토지의 비교표준지로 A시 소재 일정 토지(2020. 1. 1. 기준 공시지가가 1㎡당 1,000만원이다)를 선정하고, 甲 토지와 비교표준지의 토지가격비준표상 총 가격 배율을 1.00으로 조사함에 따라 甲의 토지가격을 1㎡당 1,000만원으로 산정하였다. A시장으로부터 산정된 가격의 검증을 의뢰받은 감정평가사 乙은 甲의 토지가 비교표준지와 비교하여 환경조건, 획지조건 및 기타조건에서 열세에 있고, 특히 기타조건과 관련하여 비교표준지는 개발을 위한 거래가 이어지고 있으나 甲의 토지 등은 개발 움직임이 없다는 점을 '장래의 동향'으로 반영하여 91%의 비율로 열세에 있다고 보아, 비교표준지의 공시지가를 약 83.9%의 비율로 감액한 1㎡당 839만원을 개별공시지가로 정함이 적정하다는 검증의견을 제시하였다. A시장은 A시부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이 검증의견을 그대로 받아들여 2020. 5. 20. 甲의 토지의 개별공시지가를 1㎡당 839만원으로 결정·공시하고, 甲에게 개별 통지하였다. 甲은 토지가격비준표에 제시된 토지특성에 기초한 가격배율을 무시하고 乙이 감정평가방식에 따라 독자적으로 지가를 산정하여 제시한 검증의견을 그대로 반영하여 개별공시지가를 결정한 것은 위법하다고 보아, 「부동산 가격공시에 관한 법률」제11조에 따라 2020. 6. 15. 이의신청을 제기하였고, 2020. 7. 10. 이의를 기각하는 내용의 이의신청결과가 甲에게 통지되었다. 甲은 2020. 9. 10. 개별공시지가결정에 대해 취소소송을 제기하였다. 甲이 제기한 취소소송은 제소기간을 준수하였는가?(10점) [기출32회 2번 1]

목차

I. 논점의 정리

II. 개별공시지가에 대한 이의신청

1. 의의 및 근거
2. 이의신청의 법적성질
 - 1) 학설
 - 2) 판례 및 검토

III. 행정기본법 36조 4항 검토

IV. 사안의 해결

I. 논점의 정리

행정기본법 36조 4항 및 이의신청에 대한 판례 등을 검토하여 제소기간 준수여부를 판단한다.

II. 개별공시지가에 대한 이의신청

1. 의의 및 근거

개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있으며, 시장 등은 이의신청 기간 만료일부터 30일 내 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지해야 한다. 이의신청은 부동산공시법 11조에 근거를 둔다.

2. 이의신청의 법적성질

1) 학설

이의신청의 실질적 내용에 비추어 특별행정심판 성격을 갖는다고 보는 견해, 이의신청은 표준지공시지가가 처분임을 전제한 권리구제는 아니고, 국민의 권리구제 확립을 위해 강학상 이의신청으로 보는 견해가 있으나 통설은 강학상 이의신청으로 본다.

2) 판례 및 검토

판례는 부동산공시법의 이의신청은 행정심판법 3조 1항에서 행정심판의 제기를 배제하는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에 해당한다고 볼 수 없다고 하여 강학상 이의신청으로 본다. 이의신청은 신청인에게 변론의 기회가 주어지지 않아 준사법절차로 보기 어려운 점을 감안할 때, 행정심판이 아니라 강학상 이의신청으로 봄이 타당하다.

Ⅲ. 행정기본법 36조 4항 검토

이의신청에 대한 결과를 통지받은 후 행정심판 또는 행정소송을 제기하려는 자는 그 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다. 이는 이의신청을 거친 후 제소기간이 도과하여 행정쟁송을 제기하지 못하는 등의 불이익을 방지하기 위해 마련된 규정이다.

Ⅳ. 사안의 해결

행정기본법 36조에 따라, 제소기간의 기산점은 이의신청 결과 통지일인 2020.7.10.로 보아야 하고, 9.10.은 위 날로부터 90일 이내이므로, 제소기간을 준수하였다.

<개별공시지가 정정제도>

04. 甲은 이의신청기간이 도과한 후에 이루어진 A시장의 개별공시지가 정정처분은 위법하다고 주장한다. 甲의 주장은 타당한가? (10점) [기출30회 1번 2]

목차
I. 논점의 정리 II. 개별공시지가에 대한 이의신청 1. 의의 및 근거 2. 이의신청의 법적성질 1) 학설 2) 판례 및 검토 III. 개별공시지가의 정정 IV. 이의신청과 정정의 관계 V. 甲 주장의 타당성

I. 논점의 정리

개별공시지가 이의신청의 법적성질(강학상 이의신청 여부)을 검토하여 이의신청 기간 도과 후 정정처분이 위법한지 살펴본다.

II. 개별공시지가에 대한 이의신청

1. 의의 및 근거

개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있으며, 시장 등은 이의신청 기간 만료일부터 30일 내 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지해야 한다.

2. 이의신청의 법적성질

1) 학설

이의신청의 실질적 내용에 비추어 특별행정심판 성격을 갖는다고 보는 견해와 이의신청은 표준지공시지가가 처분임을 전제한 권리구제는 아니고, 국민의 권리구제 확립을 위해 강학상 이의신청으로 보는 견해가 있다.

2) 판례 및 검토

판례는 부동산공시법이 이의신청에 관하여 규정하고 있다고 하여 이를 행정심판법 3조 1항에서 행정심판의 제기를 배제하는 다른법률에 특별한 규정이 있는 경우에 해당한다고 볼 수 없다고 하여 강학상 이의신청으로 본다. 이의신청은 신청인에게 변론의 기회가 주어지지 않아 준사법절차로 보기 어려운 점을 감안할 때, 행정심판이 아니라 강학상 이의신청으로 봄이 타당하다.

III. 개별공시지가의 정정

시장 등은 개별공시지가에 틀린 계산, 오기, 표준지 선정의 착오, 그 밖에 대통령령으로 정하는 명백한 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 하며, 이는 부동산공시법 12조에 근거를 둔다.

IV. 이의신청과 정정의 관계

이의신청과 정정은 근거 규정 및 사유 등이 다른 별도의 절차이다. 시장 등은 이의신청과 관계없으므로 이의신청 기간이 지나서도 직권 정정할 수 있다.

V. 甲 주장의 타당성

부동산공시법 12조의 정정은 이의신청 제도와는 별개의 제도이므로 이의신청기간이 도과하여도 A시장은 직권으로 개별공시지가를 정정하러 수 있다. 따라서 甲의 주장은 타당하지 않다.

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 개별법 기본강의 10회

<부동산 가격공시위원회>

01. 부동산 가격공시에 관한 법령상 중앙부동산가격공시위원회에 관하여 설명하시오.

(10점) [기출29회 4번]

IV. 심의의 효과

부동산가격의 결정 공시 과정에서 의결을 거치지 않은 경우 절차의 하자가 된다. 위원회의 의결에 반한 가격공시의 경우 법적 구속력이 없어 반드시 위법하게 되는 것은 아니다.

목차

I. 의의 및 근거

II. 구성

III. 법적지위(합의제 행정기관)

IV. 심의의 효과

I. 의의 및 근거

중앙부동산가격공시위원회는 부동산공시법 24조에 따라 표준지 선정 및 조사평가, 표준주택가격, 공동주택가격 등에 대한 심의를 담당한다.

II. 구성

위원회는 국토교통부 제1차관인 위원장과 중앙행정기관이 지명하는 6명 이내의 공무원, 국토교통부장관이 위촉하는 사람을 포함하여 20명 이내의 위원으로 구성된다. 공무원이 아닌 위원의 임기는 2년이며 한차례 연임할 수 있다.

III. 법적지위(합의제 행정기관)

위원회와 같은 심의 기관은 크게 의결기관과 자문기관으로 구분된다. 법령의 문언 및 위치, 업무의 성질을 고려할 때 중앙부동산가격공시위원회는 전문성을 바탕으로 심의 자문을 담당하는 자문기관의 지위를 지니는 것으로 봄이 타당하다.

<자격등록 갱신등록>

02. 감정평가업자 乙은 국토교통부장관에게 감정평가사 갱신등록을 신청하였으나 거부당하였다. 그런데 乙은 갱신등록거부처분에 앞서 거부사유와 법적 근거, 의견제출의 가능성 등을 통지받지 못하였다. 위 갱신등록 거부처분의 위법성 여부를 검토하시오. (10점) [기출22회2-2]

목차
I. 논점의 정리
II. 거부행위의 처분성
III. 거부처분의 사전통지 대상 여부
1. 문제점
2. 학설
3. 판례
4. 검토
IV. 사안의 경우 및 하자의 정도

I. 논점의 정리

갱신등록신청에 대한 거부행위가 처분인지 및 거부처분이 사전통지의 대상인 권익을 제한하는 처분인지 문제된다.

II. 거부행위의 처분성

乙은 감정평가법 17조 및 같은 법 시행령 17조 등에 의해 법규상·조리상 신청권이 있고, 갱신등록 거부행위는 행정청인 국토교통부장관의 공권력의 행사에 해당하며, 이로써 乙은 감정평가업무 수행이라는 법률관계에 직접 영향을 받게 된다. 따라서 당해 거부행위는 처분에 해당한다.

III. 거부처분의 사전통지 대상 여부

1. 문제점

사전통지는 행정절차법 21조에 따라 권익을 제한하는 처분에 행해지는데, 수익적 행정처분 발령에 대한 거부처분이 이에 포함되는지 문제된다.

2. 학설

당사자에게 아직 권익이 부여되지 아니하여 권익제한 처분이 아니라는 점에서 사전통지 대상이 아니라고 보는 부정설, 당사자는 신청에 따른 긍정적인 처분을 기대하기에 거부처분에도 사전통지가 필요하다는 필요설, 원칙적으로 부정하나, 갱신허가거부등 권익을 제한하는 처분에는 사전통지가 필요하다고 보는 제한적 긍정설이 있다.

3. 판례

판례는 수익적 처분이 행해지기 전에는 아직 당사자에게 권익이 부여되지 않았으므로, 거부처분은 당사자의 권익을 침해하는 처분이 아니라고 보아 사전통지의 대상이 아니라고 하여 부정설 입장이다.

4. 검토

특별한 기대이익이 인정되는 경우에는 기존의 권익이 존재한다고 볼 수 있는바, 제한적 긍정설이 타당하다.

IV. 사안의 경우 및 하자의 정도

甲은 기존의 자격등록에 대한 갱신이라는 특별한 기대이익이 있어 甲에 대해 거부사유, 법적근거 및 의견제출 가능성 등을 통지하지 않은 것은 행정절차법 제21조 규정 위반에 해당한다. 당해 하자는 절차적 하자에 해당하고 통설, 판례에 따를 때 독자적 위법성이 인정되며 중대명백설에 의할 때, 내용상 중대하나, 외견상 명백하지 않아 취소사유에 해당한다.

<사무소개설-기출34회4>

03. 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 제21조에 따른 '사무소 개설 등'에 관하여 설명하시오. (10점) [기출34회4]

과거 감정평가법 21조는 사무소 개설신고 규정을 두었으나, 불필요한 규제 개선을 취지로 신고 규정은 삭제되었고, 현재 위 신고 업무는 협회가 담당하고 있다.

목차
I. 감정평가법인등
II. 사무소 개설을 할 수 있는 자, 의무 등(법21조 1,4,5항)
III. 사무소 개설 결격 사유(2항)
IV. 합동사무소 개설 (3항)
V. 추가논의(신고규정 개정)

I. 감정평가법인등

감정평가법 21조에 따라 사무소를 개설한 감정평가사와 29조에 따라 인가를 받은 감정평가법인을 감정평가법인등이라고 하며, 이는 감정평가업을 영위하는 주체로서 의의가 있다.

II. 사무소 개설을 할 수 있는 자, 의무 등(법21조 1,4,5항)

등록을 한 감정평가사가 사무소 개설을 할 수 있고, 1개의 사무소만 개설할 수 있으며, 소속감정평가사를 둘 수 있다.

III. 사무소 개설 결격 사유(2항)

실무수습 또는 교육연수를 받지 아니한 경우, 등록이 취소된 후 3년이 지나지 아니한 경우, 업무정지기간이 도과하지 않은 경우 등에는 사무소 개설을 할 수 없다.

IV. 합동사무소 개설 (3항)

업무를 효율적으로 수행하고 공신력을 높이기 위하여 합동사무소를 설치할 수 있다.

V. 추가논의(신고규정 개정)

<고용인의 신고 등>

04. 감정평가법 21조의2 고용인의 신고의 법적성질에 대해 설명하시오.(10점)

목차
I. 신고의 의의, 종류 및 근거
II. 고용인 신고의 의의
III. 고용인 신고의 법적성질
1. 관련규정
2. 학설
3. 판례
4. 검토
5. 고용인 신고가 수리를 요하는 신고인지

I. 신고의 의의, 종류 및 근거

사인의 공법행위로서 신고는 사인이 행정기관에 일정한 사항을 알려야 하는 의무가 있는 경우 그것을 알리는 행위를 말한다. 수리를 요하는 신고와 수리를 요하지 않은 신고로 구분할 수 있으며, 거부행위의 처분성을 구별 실익으로 볼 수 있다. 행정기본법 제34조 등에 근거를 둔다.

II. 고용인 신고의 의의

감정평가법인등은 소속 감정평가사 또는 제24조에 따른 사무직원을 고용하거나 고용관계가 종료된 때에는 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.

III. 고용인 신고의 법적성질

1. 관련규정

행정기본법 제34조는 “법령등으로 정하는 바에 따라 행정청에 일정한 사항을 통지하여야 하는 신고로서 법률에 신고의 수리가 필요하다고 명시되어 있는 경우에는 행정청이 수리하여야 효력이 발생한다.”고 규정하고 있다.

2. 학설

당해 법령의 목적과 문언에 대한 합리적이고 유기적인 해석을 통해서 판단하는 법령해석기준설과 신고요건의 내용을 구별기준으로 하여 신고요건이 형식적 요건만인 경우에는 자기완결적 신고, 실질적 요건도 포함하는 경우 수리를 요하는 신고로 구별하는 신고요건기준설이 있다.

3. 판례

판례는 신고대상인 행위와 그 시설에 대해 관계법이 이를 허용하여 실질적 적법요건을 두지 않고 형식적 심사요건만을 규정하면 자기완결적 신고로 보고, 근거법에서 그 대상행위를 원칙적으로 금지하여 실질적 적법요건을 두고 있는 때에는 수리를 거부할 수 있다고 보아 수리를 요하는 신고로 본다. 구체적으로 건축신고는 자기완결적 신고로 보나, 인허가의 제 효과를 수반하는 건축신고에 대해서는 수리를 요하는 신고로 보았다.

4. 검토

일차적으로 법령의 목적을 기준으로 하되, 명확하지 않는 경우 신고요건의 내용에 실질적 요건이 포함되어 있는지를 판단기준으로 삼는 것이 타당하다. 자기완결적 신고의 대상이 되는 행위라 할지라도 타법상의 요건충족을 전제로 하는 경우나 그 신고가 인·허가의제의 효과를 갖는 경우에는 수리를 요하는 신고라고 봄이 타당하다.

5. 고용인 신고가 수리를 요하는 신고인지

감정평가법 제21조의2에는 수리가 필요하다고 명시되어 있지 않으나, 같은 법 시행규칙 제18조의2 제2항에서 결격사유 여부를 확인해야 한다고 규정하고 있으므로, 수리를 요하는 신고로 봄이 타당하다.

<손해배상책임-기출33회4, 12회4>

05. 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 상 감정평가법인등의 손해배상책임의 성립 요건에 관하여 설명하시오. (10점) [기출33회4]

목차
I. 의의 및 취지, 근거
II. 손해배상책임의 성립요건
III. 관련판례
IV. 관련문제(민법 750조와의 관계)

I. 의의 및 취지, 근거

손해배상이란 법률이 규정하는 일정한 경우 불법한 원인으로 발생한 손해를 피해자 이외의 자가 전보하는 것을 말한다. 감정평가법에서 손해배상책임을 규정하고 있는 것은 감정평가 법인등의 성실한 감정평가를 유도하고, 감정평가법인등의 불법행위로 인해 선의의 평가 의뢰인 등이 입은 손해 구제에 그 취지가 있다. 감정평가법 28조 1항에 근거를 둔다.

II. 손해배상책임의 성립요건

①타인의 의뢰에 의해 감정평가를 하는 경우일 것, ②고의 또는 과실이 있을 것, ③적정가격과 현저한 차이가 있거나 감정평가가 서류에 거짓을 기록함으로써 부당한 감정평가를 하였을 것, ④의뢰인 또는 선의의 제3자에게 손해가 발생하였을 것, ⑤상당 인과관계가 있을 것을 요건으로 한다.

III. 관련판례

판례는 임대차관계에 대한 사실조사의 잘못에 대해서도 손해배상책임을 인정한 바 있으며, 적정가격과의 현저한 차이에 대해 1.3배가 유일한 기준이 될 수 없고, 부당 감정에 이르게 된 감정평가법인등의 귀책사유가 무엇인가 하는 점을 고려하여 사회통념에 따라 탄력적으로 판단하여야 한다고 보았다.

IV. 관련문제(민법 750조와의 관계)

감정평가법 28조 1항이 민법 750조의 특칙인지에 대해 견해가 대립하나, 판례는 법정책임 설을 취하여 특칙이 아니라고 본 바 있다.

<징계의 공고-기출34회3변형>

06. 국토교통부장관은 A법인에 근무하는 B감정평가사가 표준지공시지가를 기준으로 토지를 평가하지 않았다는 이유로 감정평가관리징계위원회에 징계의결을 요구하였고, 위원회는 1개월 업무정지를 의결하였으며, 국토교통부장관은 위원회의결에 따라 1개월 업무정지처분을 결정하여 A법인과 B, 협회에게 위 징계사실을 통보하였다. 이후 국토교통부장관이 취해야할 조치의 법적성질과 권리구제 방법에 대해 설명하시오. (10점) [기출34회3변형-행정법 복습]

목차
I. 쟁점의 정리(감정평가법 제39조의2 징계의 공고)
II. 명단의 공표의 의의
III. 명단의 공표의 법적성질
IV. 명단의 공표의 권리구제

I. 쟁점의 정리(감정평가법 제39조의2 징계의 공고)

국토교통부장관은 감정평가법 징계절차에 따라 징계를 한 때에는 당사자 및 협회에 통보하고 해당 내용을 관보 등에 공고한다. 징계의 공고는 행정의 실효성 확보수단 중 '명단의 공표'에 해당하느바, 이하 명단공표의 법적성질과 권리구제 방법에 대해 검토한다.

II. 명단의 공표의 의의

명단의 공표란 행정법상 의무의 위반 또는 불이행이 있는 경우에 그 위반자의 성명, 위반 사실 등을 일반에게 공개하여 명예 또는 신용에 침해를 가하여 행정법상 의무를 이행하도록 심리적 압박을 가하는 간접강제수단을 말한다. 명단의 공표는 개인의 명예와 신용의 침해를 초래하므로 법에 근거가 있는 경우에 한하여 가능하다. 감정평가법 제39조의2에서 징계의 공고가 명단의 공표에 해당한다.

III. 명단의 공표의 법적성질

명단의 공표는 불명예 또는 영업상 불이익이라는 간접적·심리적 강제에 의해 행정상 의무이행을 확보하려는 것으로 사실 행위이지 의사표시를 요소로 하는 법적 행위는 아니다. 따라서 법적 효과가 발생하지 않으므로 비권력적 사실행위로 보는 것이 일반적이다. 다만, 판례는 공표의 내용이 처분의 실질을 담고 있는 경우에는 항고소송의 대상이 된다고 판시한 바 있다.

IV. 명단의 공표의 권리구제

1. 행정쟁송(처분성 여부)

1)학설

학설은 ① 명단의 공표를 비권력적 사실행위로 보아 처분성을 부정하는 견해, ② 비권력적 사실행위로 보면서도 형식적 행정행위 관념을 전제로 처분성을 긍정하는 견해, ③ 권력적 사실행위로 보아 처분성을 긍정하는 견해 등이 있다.

2)판례

판례는 명단공표를 공권력 행사로 보면서도 공개라는 사실행위는 행정결정의 집행행위로 보고 있는 점에서 명단공표를 사실행위로 보지 않고 행정행위(일반처분)으로 보고 있는 것으로 보인다.

3)검토

공표는 순수한 사실행위일 뿐이며 수인의무를 수반하는 권력적 사실행위로 보기는 어렵다. 따라서 행정쟁송의 대상에 해당한다고 볼 수 없으나, 예외적으로 공표의 내용이 처분의 실질을 담고 있다면 처분성을 긍정하여 행정쟁송으로 다룰 수 있게 함이 타당하다.

2. 손해배상청구 등

위법한 공표에 대해 손해배상청구가 가능하며, 손해배상청구는 명단 공표에 대한 취소소송과 관련청구소송으로서 병합하여 제기 할 수 있다(행정소송법 제10조 제2항). 또한 공표철회, 정정요구 등 시정조치를 구하는 이행소송을 공법상 당사자소송으로 제기할 수 있으나, 판례는 이를 인정하지 않는다.

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 개별법 기본강의 11회

<감정평가기준 및 타당성조사-기출31회4, 기출26회4>

01. 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에 따른 감정평가의 기준 및 감정평가 타당성 조사에 관하여 각각 설명하시오. (10점) [기출31회4]

목차
I. 감정평가의 기준(감정평가법 3조)
II. 감정평가의 타당성 조사(감정평가법 8조)
1. 의의
2. 의견진술기회
3. 절차 등

I. 감정평가의 기준(감정평가법 3조)

감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 부동산가격공시에 관한 법률에 따른 표준지공시지가를 기준으로 하여야 한다. 다만, 적정한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수 있다. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따른 재무제표 작성 등 기업의 재무제표 작성에 필요한 감정평가와 담보권의 설정경매 등 대통령령으로 정하는 감정평가를 할 때에는 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가를 할 수 있다.

II. 감정평가의 타당성 조사(감정평가법 8조)

1. 의의

국토교통부장관은 감정평가서가 발급된 후 해당 감정평가가 감정평가법 등의 절차와 방법 등에 따라 타당하게 이루어졌는지를 직권으로 또는 관계 기관 등의 요청에 따라 조사할 수 있다. 이를 타당성 조사라 한다.

2. 의견진술기회

타당성조사를 할 경우에는 해당 감정평가법인등 및 이해관계인에게 의견진술기회를 주어야 한다.

3. 절차 등

관계기관, 이해관계인이 조사를 요청하는 경우 등 타당성 조사를 할 수 있으며, 재판 또는 수사 중인 경우에는 타당성 조사를 하지 않을 수 있다. 국토교통부장관은 타당성조사에 착수한 경우 10일 이내 감정평가법인등에게 타당성조사의 사유 등을 알려야 하며, 감정평가법인등은 통지받고 10일 내 의견을 제출할 수 있으며, 국토교통부 장관은 타당성조사를 완료한 경우 지체없이 그 결과를 통지해야 한다.

<과징금-기출32회3-1, 기출21회3>

02. 감정평가업자 P와 건설업자 Q는 평소에 친밀한 관계를 유지하고 있다. P는 Q의 토지를 평가함에 있어 친분관계를 고려하여 Q에게 유리하게 평가하였다. 국토교통부장관은 P의 행위가 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률을 위반하였다고 판단하여 과징금, 벌금 또는 과태료의 부과를 검토하고 있다. (30점) [기출21회3]

1) 과징금, 벌금, 과태료의 법적 성질을 비교하여 설명하시오. (20점)

2) 국토교통부장관은 과징금과 벌금을 중복하여 부과하고자 한다. 중복부과처분의 적법성에 관하여 판단하시오. (10점)

목차

<물음1> 20

I. 과징금

1. 의의, 성격
2. 근거(감정평가법 41조)
3. 목적 및 취지

II. 벌금

1. 의의, 성격
2. 근거(감정평가법 48조 내지 51조)
3. 목적 및 취지

III. 과태료

1. 의의, 성격
2. 근거(감정평가법52조)
3. 목적 및 취지

IV. 각 법적성질의 비교

1. 침익적 행위
2. 기속재량행위 여부

<물음2>10

I. 논점의 정리

II. 과징금과 벌금의 중복부과 처분의 가능성

1. 학설
2. 판례
3. 검토
4. 사안의 경우

<물음1> 20

I. 과징금

1. 의의, 성격

과징금이란 행정법 위반으로 경제상 이익을 얻는 경우 위반으로 인한 경제적 이익을 박탈하기 위한 행정상 제재금이다. 감정평가법상 과징금은 변형된 과징금이며, 행정상 제재로서 형벌이 아니다.

2. 근거(감정평가법 41조)

국토교통부장관은 표준지공시지가 고잇 등 업무의 정상적 수행에 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우 업무정지처분에 갈음하여 5천만 원(법인의 경우 5억 원)이하의 과징금을 부과할 수 있다. 과징금 부과 시 위반행위의 내용과 정도, 위반행위의 기관과 위반횟수, 위반행위로 취득한 이익의 규모 등을 고려하여야 한다.

3. 목적 및 취지

감정평가법인등이 업무정지처분을 받게 되는 경우 공익과 관련성이 큰 감정평가에 지장이 있게 되므로, 시민의 불편 및 국민경제에 줄 공익침해 등을 방지하기 위함이다.

II. 벌금

1. 의의, 성격

벌금이란 형법상 형벌의 종류 중 하나로서 행정형벌에 해당한다. 행정형벌이란 행정법규 위반에 대하여 형법상의 형벌을 과하는 행정형벌이다.

2. 근거(감정평가법 48조 내지 51조)

감정평가법 48조 내지 51조는 징역 및 벌금 처벌규정을 둔다.

3. 목적 및 취지

행정형벌은 행정목적은 직접적으로 침해하는 행위에 대하여 과해진다. 즉, 과거 의무위반에 대한 제재로서, 처벌을 내용으로 하여 행정규범의 실효성 확보에 취지가 있다. 감정평가법상 벌칙 규정은 감정평가업계의 공신력, 질서유지 등의 목적을 달성하여 궁극적으로 감정평가의 적정성, 신뢰성 확보를 통해 공익에 기여함을 목적으로 한다.

III. 과태료

1. 의의, 성격

과태료란 행정벌 중 행정질서로서, 신고의무 위반과 같이 행정목적은 간접적으로 침해하는 행위에 대하여 과해지는 행정의 실효성 확보수단이다.

2. 근거(감정평가법52조)

감정평가법 52조에서는 일정한 사유 위반 시 500만 원 이하의 과태료를 부과하도록 규정을 두고 있다. 질서위반행위규제법은 동법에 따른 질서 위반행위를 한 자에 대한 과태료 부과 규정을 둔 법률이다.

3. 목적 및 취지

행정질서벌인 과태료 부과는 과거 의무위반에 대한 제재로서, 형법에 형명이 없는 과태료가 가해지는 행정벌이다. 간접적으로 행정목적 달성에 장애를 미칠 위험이 있는 행위에 부과한다. 감정평가법상 과태료 규정은 감정평가업계의 공신력, 질서유지 등의 목적을 달성하여 궁극적으로 감정평가의 적정성, 신뢰성 확보를 통해 공익에 기여함을 목적으로 한다.

IV. 각 법적성질의 비교

1. 침익적 행위

과징금은 국토교통부장관이 발령하는 급부하명이고, 벌금은 형사소송절차에 따라 과해지는 사업행위의 성질, 과태료는 국토교통부장관이 발령하는 급부하명으로 모두 침익적 행위이다.

2. 기속재량행위 여부

과징금은 업무정지처분과 과징금 중 선택 가능하고, 시행령 43조에 따라 그 액수에도 재량

이 있는바, 재량행위에 해당한다. 벌금은 그 내용은 형사소송절차에 따라 과해지는 행위이며, 문언상 벌금에 처한다 등으로 되어 있는 점을 볼 때 위반사유 발생 시 국토교통부장관이 고발하는 점에 기속적 성질을 갖는다고 볼 것이다. 과태료 역시 52조 문언상 과태료를 부과한다라고 되어 있어 위반사유 발생 시 국토교통부장관이 부과해야하는 기속행위로 봄이 타당하다.

<물음2>10

I. 논점의 정리

감정평가법상 행정상 제재금인 과징금과 행정형벌인 벌금을 병과하는 것이 이중처벌금지원칙(헌법 13조)에 반하는 것인지 판단하여 중복 부과처분의 적법성을 검토한다.

II. 과징금과 벌금의 중복부과 처분의 가능성

1. 학설

양자는 모두 넓은 의미의 행정의 실효성 확보수단으로서, 동일한 법규위반에 대하여 양자를 병과할 수 없다는 견해, 양자는 목적과 성질이 다르므로 이중처벌은 아니므로 병과가능하다는 견해가 있다.

2. 판례

헌법재판소는 과징금은 행정상 제재금으로서, 범죄에 대한 국가의 형벌권 실행상 과벌이 아니므로, 행정법규 위반에 대하여 벌금 이외 과징금을 부과하는 것은 이중처벌금지원칙에 반하지 않는다고 보아야 한다고 하였다.

3. 검토

과징금과 벌금은 목적과 성질이 다르므로, 동일한 법규위반에 대하여 중복구과할 수 있다고 봄이 타당하다.

4. 사안의 경우

감정평가법상 과징금은 업무정지처분을 받을 자가 업무정지로 인해 표준지공지가 등 업무를 못함으로써 해하게 될 공익 등의 경우에 행해지는 행정상 제재이고, 벌금은 감정평가법상 일정한 사유(48조 내지 51조) 발생 시 행정법규 위반에 대한 처벌로서 행해지는 형법이 적용되는 행정형벌로서 양자는 목적과 성질이 다르다. 따라서 국토교통부장관은 P에게 동일한 법규위반을 이유로 과징금과 벌금을 중복 부과처분할 수 있다.